

제8장 집행공탁

제8장 집행공탁

제1절 서설

집행공탁이란, 민사집행법상의 강제집행이나 보전집행절차의 어느 단계에서 집행기관이나 집행당사자 또는 제3채무자가 강제집행법상의 권리·의무로써 집행의 목적물을 공탁소¹⁾에 맡겨 그 목적물의 관리와 집행당사자에의 교부를 공탁절차에 따라 행하도록 하기 위한 공탁을 말한다.

이는 본질적으로는 집행목적물을 공탁케 하여 목적물의 보관을 확실하게 하고, 집행채권자에의 교부를 공탁절차를 통하여 행하게 하는 등 집행절차의 일단을 담당함으로써 집행제도에 협력하는 것이며, 따라서 위 규정에 의한 공탁절차는 이후 행해질 배당등 절차의 진행을 전제로 하여 구성되어 있는 것이다. 그러므로 이를 간단히 「집행 목적물의 공탁」이라고도 말할 수 있고, 당해 집행절차를 원활히 하는 기능을 가지고 있는 것이다.^{2) 3)}

- 1) 공탁사무는 법원이 관장하며(법원조직법 제2조), 구체적으로는 각 지방법원 또는 지방법원 지원이나 시법원 또는 군법원의 공탁관이 공탁사무를 처리한다(공탁법 제2조 참조). 공탁사무를 처리하는 기관을 공탁소라 하는데, 이는 공탁법상 기관의 명칭일 뿐이고 국가행정조직상 공탁소라는 명칭의 관서가 존재하는 것은 아니다.
- 2) 일반적으로 공탁이란, 어떤 사람(공탁자)이 법령의 규정(공탁근거법령)에 따른 일정한 원인(공탁원인사실)에 의하여 공탁물(금전, 유가증권, 기타의 물품 등)을 국가기관(공탁소)에 맡김으로써(임치) 일정한 법률상의 목적을 달성하려고 하는 제도 또는 절차를 말한다. 공탁절차에 있어서 공탁당사자인 공탁자·피공탁자와 공탁소의 법률관계를 어떻게 볼 것인가의 문제에 관하여는 사법관계설, 공법관계설 및 병존설 등의 견해가 나오고 있으나, 대법원(대법원 1991. 7. 12. 선고 91다 15447 판결; 대법원 1992. 7. 28. 선고 92다13011 판결 등)은 “채권자(피공탁자)를 불확시로 한 공탁의 경우 공탁금을 지급받기 위하여는 먼저 공탁법과 공탁규칙이 정하고 있는 절차에 따라 공탁공무원에게 공탁물출급청구를 하고 그에 대한 공탁공무원의 불수리처분 등에 관하여 불복이 있는 때에는 공탁법 소정의 항고 및 재항고절차를 통하여 다투어야 하며 이러한 절차를 거침이 없이 국가를 상대로 직접 민사소송으로서 공탁금지급청구를 함은 허용되지 아니한다 할 것인 바...”라고 판시하여 이를 공법관계로 해석하고 있다. 또한 공탁은 그 목적 내지 기능에 따라 변제공탁(채무의 목적물의 공탁), 담보공탁 또는 보증공탁(담보 또는 보증의 목적물의 공탁), 보관공탁(보관의 목적물의 공탁), 물취공탁(물취의 목적물의 공탁) 및 집행공탁으로 분류할 수 있다.
- 3) 집행공탁과 관련하여 이후로 필연적으로 계속 언급될 것은 변제공탁이다. 쉽게 말하여 집행 목적물의 공탁을 말하는 집행공탁은 변제 목적물의 공탁인 변제공탁과 달리, 공탁에 있어서 피공탁자가 정해지지 않는 것이 원칙이고(나중에 배당등 집행절차에 의해 확정되게 된다), 공탁금에 대한 관리를 공탁소가 아닌 집행법원이 행하며, 또한 그 지급절차에 있어서도 집행법원의 지급위탁에 의해서만 공탁금을 지급하게 되어 있다. 그리고 집행공탁에 있어서는 원칙적으로 공탁자의 공탁금회수청구권이 인정되지 않는다(물론, 예외는 있음)는 등의 특징이 있다.

이러한 집행공탁의 종류에는 민사집행법상 여러 가지가 규정되어 있으나,⁴⁾ 채권 집행 또는 채권배당과 관련되어 중요한 의미를 가지는 것은 민사집행법 제248조 규정에 따른 제3채무자의 공탁과 제236조 제2항에 따른 추심채권자의 공탁이다. 이러한 공탁에 의하여 비로소 채권배당절차가 시작된다고 할 수 있으므로 위와 같은 공탁이 채권배당의 기초가 된다고 할 수 있는바(민집 제252조 제2호), 이하에서는 집행공탁 중 위 두 가지를 중심으로만 논의해 나가기로 한다.

4) 이에에는 매각허가 여부에 대한 항고보증공탁(민집 제130조 제3항), 긴급매각에 의한 공탁(민집 제198조 제4항), 매각대금공탁(민집 제222조 제1항), 추심채권자의 공탁(민집 제236조 제2항), 제3채무자의 공탁(민집 제248조 제1항, 제2항, 제3항), 배당금의 공탁(민집 제256조), 부동산인도 시 동산매각대금 공탁(민집 제258조 제6항, 민집규 제142조 제3항), 해방공탁(민집 제282조), 가압류 강제관리인의 공탁(민집 제294조), 가압류된 금전 또는 동산매각대금의 공탁(민집 제296조 제4항, 제5항), 집행정지 중의 자동차매각대금의 공탁(민집규 제126조 제5항), 강제관리인의 공탁(민집규 제88조 제2항) 등에 의한 집행공탁이 있다.

제2절 제3채무자의 공탁

(민집 제248조, 제291조, 제297조)

I. 연혁적 고찰

1. 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전면 개정되기 전의 것, 이하 구 민소법이라고 한다) 제581조 제1항은 “금전채권에 관하여 배당요구의 송달을 받은 경우 제3채무자는 그 채무액을 공탁할 권리가 있다.”라고 규정(구 민소법상의 권리공탁)하고, 제2항은 다시 “제3채무자는 배당에 참가한 채권자의 청구가 있는 때에는 채무액을 공탁할 의무가 있다.”라고 규정(구 민소법상의 의무공탁)하고 있었다.

이는 압류된 금전채권에 대하여 다른 채권자의 배당요구가 있는 경우에는 위 제1항에 따라 제3채무자에게 당해 채무액을 공탁할 수 있는 권리를 줌과 동시에, 그 배당에 참가한 채권자의 청구가 있는 때에는 제3채무자에게 채무액을 공탁할 의무를 부과하고 있었던 것이다.

2. 위 제581조 제1항의 규정은 제3채무자가 각 채권자의 변제수령권의 유무나 채무액의 배분 등에 있어서 판단을 잘못함으로써 이중변제의 책임을 지게 되는 위험을 제거하고 집행절차의 적정을 도모하자는 데에 그 취지가 있는 것이었다.⁵⁾ 또한 이러한 제3채무자 보호 및 집행절차의 적정이라는 이념은 중복압류(가압류 포함) 등에 의하여 채권자가 경합된 경우에도 역시 요청되는 것이므로 위 규정은 이와 같은 경우에도 유추적용되는 것으로 해석되었다.⁶⁾

5) 대법원 1989. 1. 31. 선고 88다카42 판결【판결요지】[2] 민사소송법 제581조 제1항에서 제3채무자에게 채무액을 공탁할 수 있는 권리를 인정한 이유는, 채권에 대한 강제집행절차에서 피압류채권에 대하여 권리를 주장하는 자가 다수 있고 위 채권액이 모든 자에게 만족을 줄 수 없는 경우에 제3채무자에게 배당요구 또는 중복압류의 유무 및 각 압류의 적부를 심사하게 하고 그 진실한 권리자 또는 우선권자에게 적절한 배당을 하게 하는 것은 제3채무자에게 극히 무거운 부담을 주고 또 강제집행절차의 적정도 해할 우려가 있기 때문에 그 피해를 제거하려고 하는 데 있다.

6) 대법원 1996. 11. 11.자 95마252 결정【결정요지】[2] 압류된 금전채권에 대하여 배당요구가 있어 채권자가 경합하게 된 경우에 제3채무자가 그 권리로서 채무액을 공탁할 수 있음을 규정한 민사소송법 제581조 제1항은 제3채무자가 각 채권자의 변제수령권의 유무나 채무액의 배분 등에 있어서 판단을 잘못함으로써 이중변제의 책임을 지게 되는 위험을 제거하고 집행절차의 적정을 도모하는 데 그 취지가 있으며, 그와 같은 제3채무자 보호 및 집행절차의 적정이라는 이념은 중복압류(가압류를 포함한다)에 의하여 채권자가 경합된 경우에도 역시 요청되는 것이므로 제3채무자가 그 권리로서 채무액을 공탁할 수 있음을 규정한 민사소송법 제581조 제1항은 중복압류의 경우에도 유추 적용된다.

따라서 공동압류·이중압류·배당요구·교부청구 기타 배당요구의 효력을 가지는 신청으로 2인 이상의 채권자가 경합하는 경우에는 위 구 민소법 제581조 제1항이 적용되어 집행공탁이 가능하였고, 이때 말하는 압류에는 가압류도 포함되지만, 적어도 그 가운데에는 압류나 배당요구 등이 1개는 있어야 했기 때문에, 그러한 이유로 단일 또는 복수의 가압류채권자만이 있는 경우, 단일의 압류인 경우, 그리고 압류의 경합이 없는 복수의 압류의 경우(복수의 압류명령이 있지만 각 압류의 법률적 성질상 압류액의 총액이 피압류채권액을 초과하지 아니하여 본래적 의미에 있어서는 압류의 경합으로 볼 수 없는 경우) 등에 있어서는 위와 같은 집행공탁이 인정되지 아니하였다.

3. 그러나 집행공탁이 인정되지 않는 위의 것들 중 대표적으로 채권이 가압류된 경우를 볼 때에, 채권의 가압류는 제3채무자에 대하여 채무자에게 지급하는 것을 금지하는 데 그칠 뿐 채무 그 자체를 면하게 하는 것이 아니고, 가압류가 있다 하여도 그 채권의 이행기가 도래한 때에는 제3채무자는 그 지체책임을 면할 수 없는 것이므로 그 후에는 지연손해금을 지급해야 한다.⁷⁾ 제3채무자로서는 이러한 지체책임을 면하기 위해 이행기가 도래하면 자신의 채권자인 집행채무자에게 변제를 하여야 할 것인데, 위 가압류에 불구하고 이러한 변제는 나중에 이중으로 변제해야 할 위험을 그 자체로 내포하고 있는 것이어서 제3채무자는 결국 자신의 의지와 관계없이 이리지도 저리지도 못하게 되는 불이익하고 불안한 입장에 처하게 되고 마는 것이다.

7) 대법원 1994. 12. 13. 선고 93다951 판결 [판결요지][1] 채권의 가압류는 제3채무자에 대하여 채무자에게 지급하는 것을 금지하는 데 그칠 뿐 채무 그 자체를 면하게 하는 것이 아니고, 가압류가 있다 하여도 그 채권의 이행기가 도래한 때에는 제3채무자는 그 지체책임을 면할 수 없다고 보아야 할 것이다. [2] '가'항의 경우 가압류에 불구하고 제3채무자가 채무자에게 변제를 한 때에는 나중에 채권자에게 이중으로 변제하여야 할 위험을 부담하게 되므로 제3채무자로서는 민법 제487조의 규정에 의하여 공탁을 함으로써 이중변제의 위험에서 벗어나고 이행지체의 책임도 면할 수 있다고 보아야 할 것이다. 왜냐하면 민법상의 변제공탁은 채무를 변제할 의사와 능력이 있는 채무자로 하여금 채권자의 사정으로 채무관계에서 벗어나지 못하는 경우를 대비할 수 있도록 마련된 제도로서 그 제487조 소정의 변제공탁의 요건인 "채권자가 변제를 받을 수 없는 때"의 변제라 함은 채무자로 하여금 종국적으로 채무를 면하게 하는 효과를 가져다 주는 변제를 의미하는 것이므로 채권이 가압류된 경우와 같이 형식적으로는 채권자가 변제를 받을 수 있다고 하더라도 채무자에게 여전히 이중변제의 위험부담이 남는 경우에는 마찬가지로 "채권자가 변제를 받을 수 없는 때"에 해당한다고 보아야 할 것이기 때문이다. 그리고 제3채무자가 이와 같이 채권의 가압류를 이유로 변제공탁을 한 때에는 그 가압류의 효력은 채무자의 공탁금출급청구권에 대하여 존속한다고 할 것이므로 그로 인하여 가압류 채권자에게 어떤 불이익이 있다고도 할 수 없다. [3] '가'항과 '나'항의 법리는 부당이득반환채권이 가압류된 후에 제3채무자가 악의로 되어 그 받은 이익에 덧붙여 반환하여야 할 이자지급책임을 면하기 위한 경우에도 마찬가지로 할 것이고, 또 채권자의 소재가 불명한 경우에도 채무자로서는 변제공탁을 하지 않는 한 그 이행지체의 책임 내지 부당이득에 대한 이자의 배상책임을 면할 수 없음은 물론이다.

4. 이러한 제3채무자의 불안한 지위를 구제하고자 나타난 판결이 바로 대법원 1994. 12. 13. 선고 93다951 판결인바, 이는 “...의 경우 가압류에 불구하고 제3채무자가 채무자에게 변제를 한 때에는 나중에 채권자에게 이중으로 변제하여야 할 위험을 부담하게 되므로 제3채무자로서는 민법 제487조의 규정에 의하여(변제)공탁을 함으로써 이중변제의 위험에서 벗어나고 이행지체의 책임도 면할 수 있다고 보아야 할 것이다. 왜냐하면 민법상의 변제공탁은 채무를 변제할 의사와 능력이 있는 채무자로 하여금 채권자의 사정으로 채무관계에서 벗어나지 못하는 경우를 대비할 수 있도록 마련된 제도로서 그 제487조 소정의 변제공탁의 요건인 「채권자가 변제를 받을 수 없는 때」의 변제라 함은 채무자로 하여금 종국적으로 채무를 면하게 하는 효과를 가져다주는 변제를 의미하는 것이므로 채권이 가압류된 경우와 같이 형식적으로는 채권자가 변제를 받을 수 있다고 하더라도 채무자에게 여전히 이중변제의 위험부담이 남는 경우에는 마찬가지로 「채권자가 변제를 받을 수 없는 때」에 해당한다고 보아야 할 것이기 때문이다. 그리고 제3채무자가 이와 같이 채권의 가압류를 이유로 변제공탁을 한 때에는 그 가압류의 효력은 채무자의 공탁금출급청구권에 대하여 존속한다고 할 것이므로 그로 인하여 가압류 채권자에게 어떤 불이익이 있다고도 할 수 없다.”라고 판시함으로써 채권가압류에 있어서 제3채무자가 민법 제487조에 따라 변제공탁을 하는 방법에 의하여 이중변제의 위험에서 벗어나고 이행지체 책임도 면할 수 있는 길을 열어 주었던 것이다.

5. 이러한 대법원의 판결이 있게 되자, 위 구 민소법 제581조 제1항에 해당되지 않거나 또는 압류가 경합된 경우가 아니어서 집행공탁을 할 수 없었던 제3채무자를 구제하기 위한 법원의 조치는 급물살을 타게 되었고, 그 결과 그 후 곧 제정된 것이 바로 「채권가압류시 제3채무자의 공탁방법 및 처리절차」에 관한 대법원 행정예규 제232호였다.

위 예규는 그 속에 「① 채권이 가압류된 경우 제3채무자는 민법 제487조 소정의 변제공탁요건인 “채권자가 변제를 받을 수 없는 때”를 원인으로 하여 변제공탁을 함으로써 이행지체의 책임을 면할 수 있고, 이때 가압류의 효력은 채무자의 공탁금 출급청구권에 대하여 존속한다. ② 위 제1항의 규정은 단일의 가압류뿐만 아니라 복수의 가압류, 단일압류, 압류의 경합이 없는 복수의 압류 등 민사소송법 제581조⁸⁾에

8) 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전부개정되기 전의 것) 제581조를 말함.

의한 집행공탁이 불가능한 경우(이하, 가압류라 한다)에 적용된다. ③ 채권가압류로 인한 공탁시 변제공탁의 일반적인 요건(이행기의 도래 등)을 갖추어야 하며 가압류채무자를 피공탁자로 하는 확지공탁을 하여야 한다.」 등을 규정하였고, 그 외에는 신청 절차 및 통지절차 등에 관하여 내용을 두고 있었다.⁹⁾

6. 그리고 나아가 대법원은 그 후에 다시 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결에서, 동일한 채권에 대하여 복수의 압류명령이 있지만 그 압류액의 총액이 피압류채권액을 초과하지 아니하여 본래적 의미에 있어서는 압류의 경합으로 볼 수 없는 경우(압류의 경합이 없는 복수의 압류)에 관하여, “민사소송법 제581조 제1항의 입법취지에 비추어, 이러한 경우라도 제3채무자의 입장에서 보아 그 우선순위의 판단에 문제가 있는 등 압류의 경합이 있는지 여부에 대한 판단이 곤란하다고 보이는 객관적 사정이 있는 경우에는 위 규정을 유추적용하여 제3채무자에게 그에 따른 집행공탁에 의한 면책을 인정할 수 있다.”고 판시함으로써, 위 대법원 예규에 따라 이미 이러한 경우에 제3채무자가 변제공탁할 수 있음에도 불구하고 다시 이에 대해 집행공탁을 할 수도 있다는 또 하나의 방법을 제시해 주기도 하였다.

7. 그러나 위와 같은 판례의 해석에 대해서는 채권의 가압류 또는 압류 등에 있어서 강제집행에 필요한 공탁을 민법상의 변제공탁으로 해결하는 것에 관하여 의문이 있고, 변제공탁으로 처리할 경우 배당가입차단효가 발생하지 않아 채권자를 확정하기 어려운 점, 그리고 어떤 경우에는 위와 같이 가압류권자 등에 대하여 변제공탁을 인정함에 따라 일반채권자 중 어느 채권자에 대한 부분은 변제공탁부분이 되고, 다른 채권자에 대한 부분은 집행공탁부분이 되거나 혹은 아예 모두 변제공탁부분이 될 수도 있는데, 이러한 때에 그 중 변제공탁부분에 대해 이론상 집행법원이 배당절차를 진행할 수 있는지, 그에 따라 지급위탁을 할 수 있는지 또는 그 부분에 대하여 다른 채권자들이 배당이의 등으로 이를 다룰 수 있는 것인지 여부 등이 문제될 수 있었던 바,¹⁰⁾ 이러한 문제점을 불식시키고 집행에 필요한 공탁을 집행법의 영역으로 끌어들

9) 대법원 행정예규 제232호는 민사집행법의 제정으로 제248조 제1항이 신설되자 2002. 6. 29. 대법원 행정예규 제481호로 폐지되었다. 위 예규가 폐지되었다 하더라도 채권이 가압류된 경우 등에 관해서 변제공탁을 인정한 위 대법원 93다951 판결이 여전히 그 효력을 미치고 있기 때문에 민사집행법 시행 이후에도 채권가압류 등에 있어서 변제공탁은 가능하다고 본다. 하지만 실무는 새 민사집행법 시행일인 2002. 7. 1.부터는 이에 관하여 위 민사집행법 제248조의 규정에 따라 일을 처리하고 있는 것으로 보인다.

10) 급여 등 계속적 법률관계를 목적으로 하는 채권을 피압류채권으로 한 경우에 이러한 문제가 생길 수 있다.

이는 것이 바람직하므로 이를 위하여 관련 법규정을 정비할 필요성을 가지고 있었다.

8. 여기에 민사집행법은 제3채무자의 이러한 불안한 지위를 구제하고, 또 법리적인 문제를 해결하기 위한 수단으로서 구 민사소송법과 달리 제248조 제1항에서 채권자 경합의 발생 여부와 관계없이 제3채무자에게 압류에 관련된 채권 전액을 공탁할 수 있도록 규정함으로써 제3채무자에게 이른바 「권리공탁」을 인정하였다.

그리고 앞서 본 구 민소법 제581조 제1항과 제2항의 규정은 위 제1항에서 제3채무자에게 권리로써 공탁할 수 있도록 한 부분만 제외한 채 이를 통합하여 제248조 제2항에서 한꺼번에 규정하고, 제248조 제3항에서는 기존의 판례가 위 구 민사소송법 제581조 제1항 등이 유추적용된다고 해석하고 있었던 중복압류 등 압류의 경합에 있어서 제2항과 마찬가지로 채권자의 청구에 따른 제3채무자의 공탁의무를 인정하는 규정을 두게 된 것이다.

9. 위와 같은 권리공탁과 의무공탁은 어느 것이나 집행절차의 일환으로서 행해지는 집행목적물의 공탁이므로 공탁절차상 집행공탁이라고 분류되는 것이다.

10. 공탁은 공탁자가 자기의 책임과 판단하에 하는 것으로서 공탁자는 나름대로 누구에게 변제하여야 할 것인지를 판단하여 그에 따라 변제공탁이나 집행공탁 또는 혼합공탁을 선택하여 할 수 있다고 보아야 한다. 따라서 제3채무자가 변제공탁을 한 것인지, 집행공탁을 한 것인지 아니면 혼합공탁을 한 것인지는 피공탁자의 지정 여부, 공탁의 근거조문, 공탁사유, 공탁사유신고 등을 종합적·합리적으로 고려하여 판단하는 수밖에 없다.¹¹⁾

11. 공탁은 반드시 법령에 근거하여야 하고 당사자가 임의로 할 수 없는 것이므로, 금전채권의 채무자가 공탁의 방법에 의한 채무의 지급을 약속하더라도 채권자가 채무자에게 이러한 약정에 기하여 공탁할 것을 청구하는 것은 허용되지 않는다. 이러한 법리는 채무자에게 민사집행법 제248조에서 정한 집행공탁의 요건이 갖추어져 있는 경우라도 다르지 않다.¹²⁾

11) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결; 2012. 1. 12. 선고 2011다84076 판결; 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013다75830 판결

12) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다52526 판결

II. 제3채무자에 의한 공탁제도의 존재의의

1. 채권집행에 있어서는, 앞서 본대로 압류명령에 있어서 제3채무자는 채무자에 의 변제가 금지되고(민집 제227조 제1항), 압류채권자가 이후 추심명령 등을 얻어 추심권 등을 취득하여 추심청구 등을 할 때에 이에 응하여 변제를 하면 집행채권은 만족되고, 이로써 채권집행의 절차는 압류채권자와 제3채무자의 자주적 행동에 의해 집행법원의 관여 없이 종료하게 된다.

2. 그러나 압류의 경합이나 배당요구 등에 의해 채권자가 경합하고, 피압류채권의 액이 채권자의 채권 모두를 만족시키기에 부족한 경우에는 제3채무자에게 자주적으로 변제시키는 것으로 하면 제3채무자로서는 변제에 있어서 중복압류의 유무, 각 채권의 우열, 누가 정당한 수령권자인가 등에 대하여 적정한 판단을 할 필요가 생기지만, 이와 같이 제3채무자의 책임하에 변제를 시키는 것은 제3채무자에게 매우 중대한 절차상의 부담을 지우게 됨과 동시에 제3채무자를 이중변제의 위험에 두게 되는 결과가 된다. 또 집행절차의 적정한 확보의 면에서 보아도 압류채권자가 경합하는 경우에 그 1인에게 피압류채권 전액이 변제되면 다른 채권자への 공평한 변제를 위한 재단의 확보가 불가능 또는 곤란하게 될 우려가 있다(제3채무자가 이중변제의 의무를 부담해도, 당해 변제에 의해 자력을 잃으면 현실적으로는 다른 압류채권자의 채권의 만족을 도모하는 것은 불가능하게 된다).

그래서 이와 같은 경우에는 압류 등 채권자 혹은 배당에 참가한 채권자의 공탁청구가 있으면 피압류채권의 변제를 제3채무자의 자주적인 행동에 맡기지 않은 채, 제3채무자에 대하여 집행채권자에게 직접 변제하는 것을 금지하고 변제에 대신하여 피압류채권의 액에 상당하는 금전을 제공시킨 다음 이것을 집행법원의 지배하에 놓은 후, 집행법원의 배당절차에 의하여 이것을 각 채권자에게 공평하게 분배할 필요가 있다.

3. 그리고 이와 같이 채무자에 대하여 바로 채권자에게 변제를 시키는 것이 적당하지 않은 경우에 변제의 목적물을 확실하게 보관하기 위한 제도로써 공탁제도가 존재하므로 제3채무자에 대하여 변제에 대신하여 금전을 제공시키는 경우에는 공탁제도를 이용시키는 것이 적당하다고 생각된다.

또한 채권자가 경합하지 않는 경우에 있어서도 제3채무자는 자기의 의사와는 무

관하게 집행채권자와 집행채무자 사이의 집행절차에 말려들어 채무자예의 변제의 금지 기타 절차상의 제약을 받게 되고, 또 적절한 변제를 하기 위해서는 압류의 효력발생시기, 채권자의 경합 유무, 집행정지나 집행취소의 유무 등에 대하여 적절한 판단을 할 필요가 있으며, 그 판단을 잘못된 경우에는 이중변제의 의무를 부담할 위험이 생긴다.

4. 나아가 압류채권자가 추심권을 취득하였음에도 불구하고 추심을 하지 않는 경우, 강제집행의 정지 등 때문에 추심권의 행사가 제한되어 있는 경우 등에 있어서는 제3채무자로서는 압류채권자, 집행채무자의 어느 쪽에도 변제하는 것이 불가능한 상황에 빠져서 변제에 의해 면책을 얻을 기회가 없음에도 불구하고 헛되이 지연손해금의 부담이 증가해간다는 불합리한 결과가 생긴다.

그래서 채무자가 경합하지 않는 경우에 있어서도 집행절차에 말려들게 되어 발생하는 제3채무자의 불이익을 구제한다는 의미에서 제3채무자에 대하여 변제에 대신하여 공탁할 권리를 부여하고, 집행절차에 있어서 제3채무자의 지위로부터 이탈하는 것을 인정함이 적당하다.

또 이와 같이 제3채무자에게 공탁을 인정하면 공탁금이 집행법원의 지배하에 놓여지고, 집행채권자로서는 이것을 자기 채권의 만족에 충당하기 위해서는 집행법원의 지급위탁을 얻은 다음 공탁절차에 쫓아 출급청구를 해야 한다는 절차상의 제약을 받는 것으로 되지만, 이 점은 자신의 의도와 관계없이 집행절차에 끌려들어감으로써 발생하게 되는 제3채무자의 불이익과 비교교량하면 부득이한 것이라고 하지 않을 수 없다.

5. 제3채무자가 채권양도 등과 압류경합 등을 이유로 공탁한 경우, 집행공탁의 경우에는 배당절차에서 배당이 완결되어야 피공탁자가 비로소 확정되고, 공탁 당시에는 피공탁자의 개념이 관념적으로만 존재할 뿐이므로 공탁 당시에 피공탁자를 지정하지 아니하였더라도 공탁이 무효라고 볼 수 없으나, 변제공탁은 집행법원의 집행절차를 거치지 아니하고 피공탁자의 동일성에 관한 공탁관의 형식적 심사에 의하여 공탁금이 출급되므로 피공탁자가 반드시 지정되어야 하며, 또한 변제공탁이나 집행공탁은 공탁근거조문이나 공탁사유, 나아가 공탁사유신고의 유무에 있어서도 차이가 있으므로 제3채무자가 채권양도 등과 압류경합 등을 이유로 공탁한 경우에 제3채무자가 변제공탁을 한 것인지, 집행공탁을 한 것인지, 아니면 혼합공탁을 한 것인지는 피공탁자의 지정 여부, 공탁의 근거조문, 공탁사유, 공탁사유신고 등을 종합적·합리적으로

고려하여 판단하는 수밖에 없다.¹³⁾

Ⅲ. 권리공탁(민집 제248조 제1항, 제291조, 제297조)

1. 의의 및 성질

민사집행법 제248조 제1항은 “제3채무자는 압류에 관련된 금전채권 전액을 공탁할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 앞서 보았듯이 이는 제3채무자로 하여금 채권자의 공탁청구, 추심청구, 경합 여부 등을 따질 필요 없이 당해 압류에 관련된 채권 전액을 공탁함으로써 채무를 면할 수 있는 권한을 인정한 것이어서 이 조항을 권리공탁규정이라고 할 수 있는 것이다.

이 경우 공탁은 제3채무자가 권리로서 공탁하는 것이므로 형식적으로는 집행절차상의 집행공탁이지만 그 실질상 변제공탁의 성질을 가지는 것이므로, 제3채무자는 공탁에 의해서 자기 본래의 채권자인 압류채무자(집행채무자)와의 관계에 있어서 채무의 변제로서의 효과가 생기고, 또한 그 효과를 압류채권자 등에 대항하는 것이 가능하다.¹⁴⁾

이와 같이 실질적으로는 변제공탁의 성질을 가지고 있는 것이므로 통상의 채권이 변제기 전에 변제를 강요받지 않는 것과 동일하게, 압류된 채권에 지급기가 정해져 있는 때는 지급기 도래 후에 공탁하면 된다.¹⁵⁾

채권 일부를 압류하였는데 제3채무자가 채권 전액을 공탁한 경우는, 규정상 명확하지 않지만, 압류에 관계된 부분에 한하여 배당등을 실시해야 하는 것으로 해석되므로 그 한도에서 배당재단이 형성되고, 공탁금 속에 원래 압류의 효력이 미치지 않는 부분은 순전히 변제공탁의 성질을 가지는 것이어서 이 부분의 공탁금은 집행법원의 지배하에 들어오지 않게 된다.

따라서 실질적으로 말하면, 압류된 부분에 대하여는 집행공탁, 압류의 효력이 미치지 않는 부분에 대하여는 변제공탁의 성질을 가지는 공탁이라고 생각하는 것이 적절하고, 그 성질상의 차이로 인해 이후의 출급절차 등에 있어서도 차이가 생기게 된다.

금전채권에 관하여 배당요구의 송달을 받은 제3채무자의 경우 채무액을 공탁할

13) 대법원 2005. 5. 26. 선고 2003다12311 판결

14) 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 법원행정처(2014), 354.

15) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 354. 참조

권리가 있는바(구 민소 제518조 제1항, 민집 제248조 제2항 참조), 이와 같이 제3채무자에게 집행공탁을 할 수 있는 권리를 인정한 이유가, 채권에 대한 강제집행절차에서 피압류채권에 대하여 권리를 주장하는 자가 다수 있고 위 채권액이 모든 자에게 만족을 줄 수 없는 경우에 제3채무자에게 배당요구 또는 중복압류의 유무 및 각 압류의 적부를 심사하게 하고 그 진실한 권리자 또는 우선권자에게 적절한 배당을 하게 하는 것이 제3채무자에게 부담을 주고 강제집행절차의 적정을 해할 우려가 있기 때문인 점에 비추어 볼 때, 특별한 사정이 없는 한 제3채무자가 집행공탁을 함에 있어서 그 채무에 관련된 채권자들에게 배당요구의 방법 등을 알려 줄 의무를 부담한다고 보기는 어렵다.¹⁶⁾

2. 권리공탁이 가능한 경우

이 규정에 따라 권리공탁이 인정되는 경우는 ① 구 민소법 제581조 제1항, 제2항이 규정하고 있었던 것으로서 압류된 채권에 대하여 배당요구가 있는 경우(현행 민사집행법 제248조 제2항) ② 위 규정이 포섭하지 못하고 있어서 변제공탁으로 공탁의 문제를 해결하였던 것들, 즉 ㉠ 단일 또는 복수의 가압류집행만이 있는 경우, ㉡ 단일의 압류만 있는 경우, ㉢ 압류가 경합되지 않는 복수의 압류 등을 들 수 있다. 그리고 나아가 ③ 구 민소법 제581조 제1항, 제2항이 유추적용되는 것으로 해석되고 있던, 압류가 중복되어 있고 또한 각 채권자들의 청구채권의 합계액이 피압류채권액을 넘어서고 있는 압류 경합의 경우(현행 민사집행법 제248조 제3항) 등에 있어서도 제3채무자는 위 규정에 따라 공탁할 수 있다.¹⁷⁾

다만 압류된 채권에 압류의 효력이 생기기 전에 질권이 설정되어 있는 때에는 질권자에 의한 채권압류 또는 민법 제353조제 3항에 따른 공탁청구가 없는 한 공탁할 수 없다.¹⁸⁾ 또 체납처분에 의한 압류만 있는 경우에도 그 자체만을 이유로 집행공탁을 할 수는 없다.¹⁹⁾

16) 대법원 2004. 4. 9. 선고 2002다10691 판결

17) 다만 ① 채권자의 경합이 없어서 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁한 경우와 ② 채권자의 경합이 있음에도 불구하고 위 규정에 따라 공탁하는 경우에 있어서 제3채무자는 집행법원 등에 대하여 사유신고를 하여야 하고, 그 신고서에는 민사집행법 제248조 제4항, 민사집행규칙 제172조 제1항에 따라 ㉠ 사건의 표시 ㉡ 채권자·채무자 및 제3채무자의 이름 ㉢ 공탁사유와 공탁한 금액 등의 내용을 포함하도록 작성되어야 하지만, 그 신고의 방식과 절차가 약간은 다르다. 이는 제4절에서 「사유신고」를 설명할 때에 보기로 한다.

18) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 351.

19) 대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다203833 판결

3. 공탁하여야 하는 금액

가. 채권 전액이 압류된 경우

예컨대, 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 임차보증금채권에 대하여 丙이 甲에 대한 700만 원의 대여금채권을 가지고 압류 범위를 제한하지 않은 채 전액을 압류한 경우는 乙은 압류된 채권 전액(1,000만 원)을 공탁해야 한다(민집 제248조 제1항).²⁰⁾

다만 丙은 甲이 乙에 대해 1,000만 원의 보증금채권을 가지고 있는 줄 알고 그 전액에 대해 압류를 하였으나, 실제 甲이 乙에 대해 700만 원의 채권밖에 가지고 있지 않았던 경우나 또는 일부 양도 혹은 제3채무자의 상계권에 의해 1,000만 원의 채권이 700만 원으로 되었던 경우에는 乙로서는 그 700만 원만 공탁하면 된다.

나. 채권 일부가 압류된 경우

예를 들어, 甲의 乙에 대한 위 채권에 대하여 丙이 700만 원만 특정하여 압류하였다면,²¹⁾ 제3채무자인 乙은 압류에 관계된 채권 전액(1,000만 원)을 공탁할 수도 있고, 압류 금액(700만 원)만을 공탁할 수도 있다.

이와 같이 피압류채권액이 집행채권액을 초과하는 경우에는 본래 그 공탁금액은 압류에 의하여 구속을 받는 부분에만 한정하는 것이 맞고, 그 나머지 부분은 특별히 공탁에 의한 면책을 받을 필요가 없는 것이지만, 그리 되면 압류된 부분만 공탁한 경우에 나머지 부분은 다시 본래의 채권자에게 변제하여야 하는 것이고, 그럴 경우 권리공탁이 인정된 제3채무자가 번거로운 집행관계로부터 벗어나기 어렵게 되므로 이를 인정함으로써 제3채무자의 위와 같은 불이익을 피하기 위하여 그 선택권을 제3채무자에게 부여해준 것이다.

이러한 취지로부터 본다면 제3채무자가 그 불이익을 감수하고자 한다면 일부 압류의 경우에 피압류부분만 공탁해도 무방할 것이다(그러나 제3채무자가 공탁할 수 있는 것은 압류된 금액 아니면 채권 전액이어야 하고, 압류된 금액과 채권 전액 사이의

20) 일부가 압류되었다가 다른 채권자의 압류로 인한 압류 경합으로 모든 압류의 효력이 피압류채권의 전부에 미치게 되는 경우에도 집행공탁을 하는 제3채무자가 채무를 면하기 위해 공탁할 채무액은 제3채무자가 부담하고 있는 채무 전액이다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2002다22700 판결 참조).

21) 이는 보통 청구금액을 700만 원으로 하고, 피압류채권의 특정을 “甲이 을에 대하여 가지는 1,000만 원의 임차보증금반환채권 중 위 청구금액”이라는 방법으로 압류의 범위를 제한하는 형태를 취한다.

임의의 금액을 선택하여 공탁할 수는 없다).

다만 이와 같이 채권 일부가 압류되었는데도 피압류채권 전액을 공탁한 경우에 있어서 압류의 효력이 미치지 않는 부분(300만 원 부분)의 공탁은 변제공탁으로서의 성질을 가지고 있는 것이기 때문에,²²⁾ 제3채무자인 乙은 다음에서 보듯이 민법 제 488조 제3항에 따라 지체 없이 자신의 채권자인 甲에게 공탁통지를 하여야 한다.

다. 이자, 지연손해금 등

압류명령의 효력은 압류명령 송달 후에 발생하는 이자, 손해금 등에 미치는 것으로 되어 있으므로 압류채권에 대한 압류명령송달 후의 이자 또는 손해금을 포함하여 공탁해야 한다.²³⁾

따라서 공탁함에 있어서 변제기로부터 공탁일까지의 지연손해금(이자가 생기는 채권에 대하여는 변제기로부터 공탁일까지의 이자를 합쳐서)을 덧붙일 것이 필요하다.

다만 실제법상 이행지체가 없으면 이를 부가할 필요가 없다. 또한 변제기 전에 있어서도 공탁서에 기한의 이익을 포기한 뜻이 기재되고, 변제기까지의 이자를 덧붙인 합계액을 공탁금액으로 한 경우에는 공탁하는 것이 인정된다.

4. 수인의 공탁자가 하나의 공탁금액을 기재하여 공탁한 경우

공탁자가 공탁한 내용은 공탁의 기재에 의하여 형식적으로 결정된다. 따라서 수인의 공탁자가 공탁하면서 각자의 공탁금액을 나누어 기재하지 않고 공동으로 하나의 공탁금액을 기재한 경우에 공탁자들은 균등한 비율로 공탁한 것으로 보아야 한다. 공탁자들 내부의 실질적인 분담금액이 다르다고 하더라도 이는 공탁자들 내부 사이에 별도로 해결하여야 할 문제이다.

이러한 법리는 강제집행정지의 담보를 위하여 공동 명의로 공탁한 경우 담보취소에 따른 공탁금회수청구권의 귀속과 비율에 관하여도 마찬가지로 적용된다. 따라서 제3자가 다른 공동공탁자의 공탁금회수청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 한 경우에 압류 및 추심명령은 공탁자 간 균등한 비율에 의한 공탁금액의 한도 내에서 효력이 있고, 공동공탁자들 중 실제로 담보공탁금을 전액 출연한 공탁자가 있다 하더라도 이는 공동공탁자들 사이의 내부관계에서만 주장할 수 있는 사유에 불과하여 담보공탁

22) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결

23) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 353.

금을 전액 출연한 공탁자는 압류채권자에 대하여 자금 부담의 실질관계를 이유로 대항할 수 없다.²⁴⁾

5. 권리공탁에 관한 업무처리절차

이에 관해서는 대법원 행정예규 제1018호 「제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차」가 이를 규정하고 있으므로 이를 중심으로 보기로 한다.

가. 금전채권에 관하여 압류가 있는 경우

1) 일부가 압류된 경우

가) 이때, 앞서 본 것처럼 제3채무자는 압류된 채권액 또는 압류와 관련된 금전채권액 전액을 공탁할 수 있는데, 이러한 공탁을 한 후에는 즉시 공탁서를 첨부하여 그 내용을 서면으로 집행법원²⁵⁾에 사유신고하여야 한다(공탁근거 법령조항은 민사집행법 제248조 제1항).

제3채무자는 공탁신청시 압류결정문 사본을 첨부하여야 한다. 이 경우 압류채권자는 집행법원의 지급위탁²⁶⁾에 의하여 공탁금의 출급을 청구할 수 있다.

나) 제3채무자가 압류된 채권액에 대하여만 공탁한 경우에는 공탁서의 피공탁자란은 기재하지 아니한다.

다) 그리고 제3채무자가 압류와 관련된 금전채권액 전액을 공탁할 경우는 공탁서의 피공탁자란에 압류명령의 채무자를 기재하고, 공탁규칙 제23조에서 정한 공탁통지서 및 우표를 붙인 봉투를 첨부하여야 한다. 그러면, 공탁관은 민법 제488조 제3항에 따라 피공탁자(압류채무자)에게 위 공탁통지서를 발송하여야 한다.²⁷⁾

라) 이 경우 압류의 효력이 미치는 부분에 대하여는 압류채권자가 집행법원의 지급위탁에 의하여 공탁금의 출급을 청구할 수 있고, 압류의 효력이 미치지 않는 부분에 대하여는 변제공탁의 예에 따라 피공탁자(압류채무자)가 공탁을 수락하고 출급을 청구할 수 있으며, 나아가 공탁자도 회수청구할 수 있는데, 이러한 회수청구에는 집행법원으로부터 공탁서를 보관하고 있다는 사실을 증명하는 서면을 교부받아 이를 공

24) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2014다29971 판결

25) 당해 압류명령을 발령한 법원을 말한다.

26) 현행 민사집행법은 공탁금의 지급위탁절차를 법원사무관등의 이름으로 실시하도록 규정하고 있으므로(민집규 제185조, 제82조), 이하에서 「집행법원의 지급위탁」이라고 해도 이는 법원사무관등이 행하는 지급위탁을 말하는 것이라고 보면 될 것이다.

27) 따라서 변제공탁의 경우에 공탁규칙에 따라 행하는 공탁통지서의 송달과 집행공탁의 경우에 행하는 공탁사실의 통지를 구분해야 한다.

탁금회수청구서에 첨부하여야 한다.

마) 둘 이상의 채권압류(가압류를 포함)가 있으나 압류된 채권액의 합계가 압류와 관련된 금전채권액보다 적은 경우라면, 제3채무자는 당해 압류·가압류된 채권액의 합계액 또는 압류·가압류와 관련된 금전채권 전액을 위와 같은 예에 따라 공탁할 수 있고, 이때 사유신고는 먼저 송달된 압류명령의 발령법원에 하여야 한다(다만 가압류 후에 본압류가 있는 경우와 같이 가압류가 다른 본압류에 앞서는 때에는 가압류가 아닌 본압류 중에서 가장 먼저 송달된 압류명령의 발령법원에 사유신고를 해야 한다고 해석하는 것이 타당하다).²⁸⁾

2) 전부가 압류되거나 압류의 경합이 있는 경우

이 경우 제3채무자는 압류된 채권 전액을 공탁할 수 있고, 공탁을 한 후 공탁서를 첨부하여 그 내용을 서면으로 집행법원에 신고하여야 한다(공탁근거법령은 민사집행법 제248조 제1항).

그리고 공탁신청시 압류결정문 사본을 첨부하고, 공탁규칙 제23조에서 정한 공탁통지서 송달과 위 예규에서 정한 공탁사실 통지를 위한 우표를 납부하여야 한다.

공탁을 수리한 공탁관은 원표에 압류사실을 기재하고, 공탁서의 피공탁자란은 기재하지 않으며, 압류채권자와 채무자에게 [8-1] 공탁사실통지서²⁹⁾에 따라 그 사실을 통지해야 한다. 이때 압류채권자는 집행법원의 지급위탁에 의하여 공탁금의 출급을 청구할 수 있다.

또한 압류의 경합을 이유로 한 공탁의 경우에는 먼저 송달된 압류명령의 발령법원에 사유신고를 하여야 한다.

나. 금전채권에 관하여 가압류가 있는 경우

1) 공탁 등 절차

이 경우 제3채무자는 가압류된 채권액 또는 가압류와 관련된 금전채권액 전액을 공탁할 수 있고, 공탁을 한 다음 즉시 공탁서를 첨부하여 그 내용을 서면으로 가압류 발령법원에 신고하여야 한다. 이때 공탁서의 피공탁자란에는 가압류채무자를 기재하고, 공탁근거 법령조항은 민사집행법 제291조 및 제248조 제1항으로 한다.

제3채무자는 공탁신청시 가압류결정문사본과 공탁규칙 제23조에서 정한 공탁통지서를 첨부하여야 하고, 위 공탁통지서의 발송과 피공탁자(가압류채무자) 또는 가압

28) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355. 참조

29) 별지서식 [8-1] 공탁사실통지서 참조(제8장 말미 수록)

류채권자에 대한 공탁사실 통지를 위해 필요한 우표를 납부해야 한다.

공탁을 수리한 공탁관은 원표에 가압류 사실을 기재하고 공탁금출급청구권에 대한 가압류가 있는 경우(민집 제297조)에 준하여 처리하여야 하며, 피공탁자(가압류채무자)에게 공탁통지서를 발송하고, 가압류채권자에게는 별지서식 [8-1] 공탁사실통지서에 따라 공탁사실을 통지하여야 한다.

둘 이상의 가압류가 있는 경우에는 제3채무자가 가압류된 채권액의 합계액 또는 가압류와 관련된 금전채권액 전액을 공탁할 수 있고, 공탁 후에는 공탁서를 첨부하여 그 내용을 서면으로 가압류발령법원에 신고하여야 하나, 이때에 신고는 먼저 송달된 가압류명령의 발령법원에 하여야 한다.

이 예규는 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 의하여 제3채무자가 공탁을 한 후 그 신고서를 제출하는 경우에 접수, 기록송부 및 보관 등의 절차를 규정함을 목적으로 한다.

가압류를 이유로 제3채무자로부터 공탁서가 첨부된 공탁신고서가 제출되면 가압류법원은 이를 문건으로 전산입력한 후 가압류사건 기록에 가철하고, 기록표지의 우측 상단에 신고서가 접수된 날짜를 기재한다. 그 후 배당법원으로부터 기록송부 촉탁이 있는 경우 가압류법원은 공탁신고서 등본을 포함한 가압류사건 기록의 등본을 조제하여 배당법원으로 송부하고, 공탁신고서 접수 기재 부분 하단에 기록등본을 송부한 날짜를 기재한다. 가압류사건 기록의 등본을 송부받은 배당법원은 이를 배당절차 기록에 첨철하고,³⁰⁾ 배당절차가 종료한 이후에도 가압류사건 기록의 등본은 반환하지 않고 배당절차기록과 함께 보존한다.³¹⁾

2) 공탁금의 출급 등

가) 제3채무자가 가압류된 채권액에 대하여만 공탁한 경우 : 이때 피공탁자(채무자)는 가압류가 실효되지 않는 한 공탁금의 출급을 청구할 수 없고, 가압류채권자는 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령을 얻은 후 집행법원의 지급위탁에 의하여 공탁금의 출급을 청구할 수 있다.

나) 제3채무자가 가압류에 관련된 금전채권 전액을 공탁한 경우 : 이 경우 공탁금 중에서 가압류의 효력이 미치는 부분에 대하여는 가압류채권자가 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령을 얻은 후 집행법원의 지급위탁에 의하여 공탁금의 출급을 청구

30) 이 경우에는 기록편성의 편의상 첨철하는 것이므로 별도의 사전번호를 부여하지 아니한다.

31) 재판예규 제950호, “채권가압류를 원인으로 한 제3채무자의 권리공탁에 따른 공탁신고서의 접수 및 기록송부절차 등에 관한 처리지침(재민 2004-1)” 참조

할 수 있다. 또한 가압류의 효력이 미치지 않는 부분에 대하여는 변제공탁의 예에 따라 피공탁자(가압류채무자)가 출금을 청구할 수 있으며, 공탁자도 회수청구를 할 수 있는데, 이때에는 압류의 경우와 마찬가지로 집행법원으로부터 공탁서를 보관하고 있다는 사실을 증명하는 서면을 교부받아 이를 공탁금회수청구서에 첨부하여야 한다.

다. 제3채무자의 공탁 후 압류 또는 가압류가 실효된 경우

1) 압류가 실효된 경우

금전채권에 대한 압류를 이유로 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 의하여 공탁한 후에 압류명령이 취소되거나 신청의 취하 등으로 인하여 압류가 실효된 경우, 공탁에 의해 제3채무자에게 생긴 면책의 효과는 확정적으로 생긴 것이라고 해석되므로 압류명령이 실효했어도 그 효과는 실효되지 않고(압류가 되어 있지 않으면 집행채무자가 제3채무자로부터 지급을 받았을 것임), 공탁원인 소멸에 의한 제3채무자의 회수는 문제로 될 여지가 없다. 따라서 채무자는 압류된 채권액에 대해 집행법원의 지급위탁에 의하여 공탁금의 출금을 청구할 수 있다.

2) 가압류가 실효된 경우

금전채권에 대한 가압류를 이유로 제3채무자가 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따라 공탁한 후에 가압류명령이 취소되거나 신청의 취하 등으로 인하여 가압류가 실효된 경우, 가압류채무자(피공탁자)는 공탁통지서와 가압류가 실효되었음을 증명하는 서면을 첨부하여 공탁관에게 출금을 청구할 수 있다.

금전채권에 대하여 2개 이상의 가압류가 경합되었음을 이유로 제3채무자가 민사집행법 제291조 및 제248조 제1항에 의하여 권리공탁을 한 후, 가압류채무자(피공탁자)가 그 중 1개의 가압류에 대하여 해방공탁을 하여 그 가압류집행이 취소된 경우도, 가압류채무자(피공탁자)는 집행공탁금 중 집행취소되지 않은 나머지 가압류사건의 가압류청구금액을 초과하는 공탁금에 대하여 공탁통지서, 가압류집행취소결정정보, 송달증서를 첨부하여 출금청구할 수 있다.³²⁾

라. 제3채무자가 공탁관인 경우

공탁물의 출금 또는 회수청구권에 대하여 압류 또는 가압류가 되었으나 압류의 경

32) 공탁선례 200610-2(2006.10.17 제정), “2개 이상의 가압류가 경합되었음을 이유로 제3채무자가 권리공탁을 한 후, 그 중 1개의 가압류가 집행이 취소된 경우, 나머지 가압류사건의 청구금액을 초과하는 공탁금에 대하여 출금청구할 수 있는지 여부(적극)” 참조

합이 성립하지 않는 경우, 공탁관은 위 규정에 따른 공탁 및 사유신고를 하지 않는다.³³⁾

금전채권에 대한 가압류를 원인으로 제3채무자가 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 의하여 공탁한 후에 피공탁자(가압류채무자)의 공탁금출급청구권에 대한 압류가 이루어져 압류의 경합이 성립하거나 공탁사유인 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 있는 경우에는, 공탁관은 즉시 먼저 송달된 압류명령의 발령법원에 그 사유를 신고하여야 한다.³⁴⁾

IV. 의무공탁(민집 제248조 제2항, 제3항)

1. 의의

금전채권에 관하여 배당요구서를 송달받은 제3채무자는 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다(민집 제248조 제2항).

여기서 배당에 참가한 채권자라 함은 집행력 있는 정본에 의한 채권자이든 우선 변제청구권이 있는 채권자이든 묻지 않으며 배당요구채권자 이외에 배당요구와 동일한 효력을 가지는 중복압류채권자나 교부청구채권자를 포함하는 것이다.

또한 금전채권 중 압류되지 아니한 부분을 초과하여 거듭 압류명령 또는 가압류 명령이 내려져 그 명령을 송달받은 경우에 압류채권자나 가압류채권자의 청구가 있으면 그 채권의 전액에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다(민집 제248조 제3항). 즉 채권자가 경합하는 경우에도 채권자가 경합하는 것만으로 공탁의무가 생기는 것은 아니고 위와 같은 배당을 받을 채권자의 청구가 있는 때에만 공탁의무가 생기는 것이다.

그러나 압류가 중복하여 경합하는 경우에도 경합한 집행채권의 합계액보다 피압류채권의 총액이 더 많은 때에는 민사집행법 제248조 제3항에서 말하는 압류의 경합

33) 대법원 행정예규 제481호, “제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차”는 공탁공무원이 제3채무자인 경우 민사집행법 제248조 제1항에 의한 공탁할 것인지 여부에 관하여, “공탁물 출급·회수 청구권에 대하여 압류 또는 가압류가 되었으나 압류의 경합이 성립하지 않는 경우 공탁공무원은 민사집행법 제248조 제1항에 의한 공탁을 하지 아니한다.”라고 규정함으로써, 마치 압류의 경합이 발생하면 공탁관이 위 규정에 따라 권리공탁할 수 있는 것처럼 되어 있었다. 그러나 제3채무자가 국가이고 그 소관이 공탁공무원인 때에는 압류의 경합이 발생하더라도 이미 공탁된 금원에 대하여 재공탁을 하지 않고 종전의 공탁을 그대로 유지한 채 배당절차의 진행을 위한 사유신고만을 하는 것이기 때문에 위 규정은 그 표현이 다소 적절하지 못한 면이 있었는바, 대법원 행정예규 제528호가 이를 개정한 것이다.

34) 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다118785 판결; 대법원 행정예규 제1018호(제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차)

이 아니므로 채권자의 청구가 있더라도 공탁할 의무가 없다.

그리고 추심소송에서 추심채권자에게 채무액을 직접 지급하라는 판결이 있는 뒤에 중복압류나 배당요구를 한 다른 채권자도 채무액의 공탁을 청구할 수 있다.

이와 같이, 의무공탁은 압류된 금전채권에 대하여 배당요구가 있거나 또는 압류의 경합이 있는 등 채권자의 집행이 경합하는 경우에 인정되는 것인바, 이러한 「집행의 경합」에 관해서는 제6장에서 그 내용을 살펴본 바 있다.

2. 공탁의무의 성격 등

가. 여기서 「공탁하여야 한다」라는 것은 공탁의 방법에 의하지 않고서는 면책받을 수 없다는 것이므로 그렇지 않고 그 중 1인의 채권자에게 변제한 경우에는 제3채무자는 이중지급의 위험을 부담한다. 따라서 공탁의무가 있는데도 불구하고 제3채무자가 추심채권자에게 변제한 경우에는 공탁청구한 채권자에 대한 관계에서는 채무의 소멸을 주장할 수 없고 이중지급의 위험을 부담하게 되는 것이다.³⁵⁾

이러한 공탁의무는 민사집행제도의 목적에서 생기는 제3채무자의 절차협력의무이고, 제3채무자의 실체법상 지위를 변경하는 것이 아니므로 제3채무자가 채무자에 대하여 기한미도래, 동시이행, 선이행의 항변 등 지급거절사유를 갖는 때에는 집행의 경합이 있더라도 공탁의무를 부담하지 아니한다. 또한 어음·수표채권에 대하여는 그 제시가 없는 한 공탁의무가 없다.

나. 제3채무자가 배당요구채권자의 공탁청구³⁶⁾에도 불구하고 공탁의무를 이행하지 않을 때에는 제249조 제1항에 따라 소로써 공탁을 명하는 추심소송을 제기할 수 있지만, 이 규정에 따라 추심의 소에 의해 공탁을 구하려면 이 소는 추심명령의 실행을 위한 추심의 소이므로 추심명령을 받은 경우에 한하여 이를 제기할 수 있는 것이고, 추심명령을 받지 아니한 상태에서는 이를 제기할 원고 적격이 없으므로,³⁷⁾ 배당

35) 대법원 2012. 2. 9. 선고 2009다88129 판결. 다만 공탁의무를 부담하는 제3채무자가 추심채권자 중 1인에게 임의로 변제하거나 일부 채권자가 강제집행절차 등에 의하여 추심한 경우에도 제3채무자는 공탁청구한 채권자 외의 다른 채권자에 대한 관계에서는 여전히 채무의 소멸을 주장할 수 있다.

36) 채권자의 공탁청구는 일종의 최고로서 집행법원에 대하여 하는 것이 아니고, 특별한 형식도 필요한 것이 아니지만 나중에 증명을 쉽게 하기 위해 내용증명우편 등을 이용함이 바람직하다.

37) 대법원 1979. 7. 24. 선고 79다1023 판결 【판결요지】민사소송법 제581조에 의하면 배당참가채권자는 제3채무자에 대하여 채무액의 공탁을 청구할 권리가 있으나 추심명령을 받은 압류채권자에 한하여 위 공탁 청구의 소를 제기할 수 있고 추심명령을 받지 아니한 압류채권자는 위 소를 제기할 원고 적격이 없다.

요구채권자 또는 압류채권자는 압류된 채권에 대하여 추심명령을 받은 다음에 제3채무자에게 공탁을 명하는 취지의 추심소송을 제기하여 그 판결에 기초한 강제집행으로 공탁을 강제할 수 있으며, 그 공탁이 이루어져 사유신고가 있을 때에 배당요구의 종기에 이르게 되는 것이다(민집 제247조 제1항 제2호).³⁸⁾ 위 공탁판결에 기초하여 강제집행을 한 후 집행기관이 배당등을 받아 그것을 공탁하게 될 것이다.

다. 한편 공탁의무의 범위와 관련하여, 추심채권자 甲의 공탁청구에 따라 민사집행법 제248조 제3항의 공탁의무를 부담하게 된 제3채무자 乙이 공탁청구에 응하지 않고 있다가 다른 추심채권자 丙이 추심채권을 청구채권으로 하여 乙의 채권을 가압류하자 채권가압류 해방공탁금을 공탁하여 丙 등 다른 추심채권자가 변제를 받은 사안에서, 위 가압류 해방공탁은 민사집행법 제248조 제3항에서 정한 공탁이라고 할 수 없으므로, 丙 등 다른 추심채권자가 해방공탁금에 대한 배당절차에서 변제를 받았다 하더라도 乙은 공탁청구한 채권자 甲에게 채무소멸을 주장할 수 없고, 다만 甲은 乙이 추심채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 배당받을 수 있었던 금액 범위 내에서만 乙을 상대로 추심할 수 있는데도, 이와 달리 甲이 乙을 상대로 제기하여 승소 확정된 추심금 판결에서 지급을 명한 금액 전부를 추심할 수 있다고 본 원심판결에 민사집행법 제248조 제3항에서 정한 공탁의무 위반의 효과에 관한 법리오해의 위법이 있다고 한 판례³⁹⁾가 있고, 결국 위 판례는 위와 같은 경우 제3채무자는 '제3채무자가 공탁청구에 따라 그 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구한 추심채권자에게 배당될 수 있었던 금액'만 지급한다면 제3채무자가 면책될 수 있는 취지라고 볼 수 있으나, 이는 잘못된 것이다.

우선 위 판례는 압류채권자가 추심명령을 받은 상태에서 민사집행법 제248조 제3항에 따라 공탁청구를 한 경우 제3채무자는 당해 조항에 의해 공탁의무를 부담하고 또 그와 같이 공탁에 의해서만 채무를 면하게 되는 것일 뿐이며, 그러한 공탁청구를 했다고 해서 추심채권자의 지위가 바뀌는 것이 아닌데도 아무 근거 없이 이를 달리 취급하고 있다.⁴⁰⁾

38) 공탁을 구하는 추심소송의 판결주문은 「피고는 원고에게 금 1,000만 원을 지급하라. 위 금원의 지급은 공탁의 방법으로 하여야 한다.」 또는 「피고는 원고에게 금 1,000만 원을 공탁의 방법으로 지급하라.」는 형식이 될 수 있을 것이다.

39) 대법원 2012. 2. 9. 선고 2009다88129 판결

40) 즉 공탁청구를 한 추심채권자이든 공탁청구를 하지 않은 추심채권자이든, 추심채권자의 지위는 아무런 소장(消長)이 없는 것이며, 그 추심권의 범위에도 차이가 있지 아니하다.

둘째로, 위 판례는 배당의 범위와 추심의 범위가 다른 것인데, 이를 동일시하고 있는 오류를 범하고 있다. 위 판례의 사례에서 설사 추심채권자가 위 판례의 실시처럼 '제3채무자가 공탁청구에 따라 그 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액'을 추심하였다고 하더라도 이는 배당절차에서 배당받은 금액이 아니고 단지 추심한 금액에 불과하다. 우리 집행법의 경우 추심채권자는 압류가 경합된 상태에서는 어떠한 경우에도 독점적 이익을 얻지 못하며, 설사 위 판례와 같이 공탁청구한 추심채권자의 추심권의 범위가 '제3채무자가 공탁청구에 따라 그 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액 범위'로 제한된다고 하더라도 그 돈은 채권자의 추심 후 민사집행법 제236조 제1항에 따라 추심신고를 해야 하는 것이고 또한 압류가 경합되어 있으므로 다시 제236조 제2항에 따라 추심공탁 및 사유신고하여 결국 배당절차로 진행되어야 되는 것이며, 그 후 다른 채권자들과 함께 배당절차에서 안분배당받게 될 뿐인 것이다.

셋째로, 민사집행법상 추심권의 범위는 압류된 채권 전액에 미치는 것이고(제232조 제1항), 압류 경합에 의해 압류의 효력이 확장되면 추심권의 범위도 압류 효력이 확장된 만큼 확장되는 것이므로 추심채권자는 압류된 채권 전액을 추심할 수 있는 것이고, 제3채무자로서는 민사집행법 제248조 제3항에 따라 압류된 채권 전액을 공탁하여야만 면책될 수 있는 것이며, '제3채무자가 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액'을 공탁한다고 해서 면책될 수 있는 것이 아니다.⁴¹⁾ 따라서 이와 같은 경우 추심채권자가 압류된 채권 중 일부(위 판례에서 말하는 '제3채무자가 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액' 상당)만 추심하여야 한다거나 제3채무자가 그 금액만 공탁해도 면책될 수 있다는 것 등은 우리 민사집행법이 예정하고 있는 바가 전혀 아니다. 물론 추심채권자가 스스로 압류된 채권의 일부에 한하여 추심명령을 신청하여 이를 행사할 수도 있는 것이나, 이는 그의 의사에 따른 것이므로 다른 문제이다. 즉 추심채권자는 이 경우 압류된 금액 중 일부를 추심할 수도 있고, 그 전액을 추심할 수도 있으며 그 추심한 것을 추심신고, 추심공탁 및 사유신고 후 배당절차를 진행하는 방법(민집 제236조 참조)으로 채권자평등주의를 구현하고 있는 것이다.

41) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2002다22700 판결

넷째로, 위 판례는 공탁청구에 응하지 않고 공탁의무를 부담한 제3채무자가 이 중지급의 위험을 부담하는 것은 당연한 것인데도 이를 간과하고 있다.

끝으로 위 판례는, 실제상으로 보더라도 이와 같은 경우 과연 추심채권자 뿐만 아니라 제3채무자로 하여금 이후 예정된 배당절차를 감안하여 그로부터 추심채권자가 배당받을 금액을 산정하도록 하여 그 금액만을 추심할 수 있도록 하거나 또는 그 금액만을 추심채권자에게 지급하도록 하는 것이 현실적으로 가능한지, 제3채무자에게 위와 같은 산정의 부담을 지울 수 있는 것인지(또는 제3채무자에게 그러한 권한이 주어져 있는지), 왜 집행기관이 해야 할 일을 사인인 제3채무자가 처리하고 금액 산정의 오류 등 그에 따른 위험을 채권자가 부담해야 하는지, 위 판례는 제3채무자가 '제3채무자가 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액'을 추심채권자에게 지급해야 하고, 그 금액에 이의가 있을 경우 채권자로 하여금 손해배상소송을 따로 제기해야 한다는 전제하에 실시하고 있는바, 그와 같이 진행될 경우 도대체 집행절차는 언제 종료하는 것인지, 또 채권자는 무슨 이유로 제3채무자가 임의로 계산한 위 금액에 대하여 승복해야 하는 것인지, 그에 대하여 불복할 경우 왜 정당한 집행권원을 얻은 후 이에 기해 압류명령과 추심명령을 받아 추심권을 행사한 채권자가 또다시 손해배상소송을 제기해야만 자신의 권리를 행사할 수 있게 되는 것인지 등 수많은 의문점을 만들어놓고 있다.

위 판례는 압류가 경합하는 경우에 있어서 추심명령의 효력과 추심채권자의 추심권의 범위, 제3채무자의 면책 등에 관하여 기존의 법이론에 전혀 맞지 않는 많은 문제점을 안고 있으므로 향후 곧 재고되어야 할 것이다.

3. 공탁하여야 할 금액

가. 민사집행법 제248조 제2항에 따른 배당요구의 경우에는 배당요구 자체에 압류 경합의 경우와 달리 압류의 확장효과 없으므로⁴²⁾ 공탁의무의 대상이 되는 것은 당초 압류된 부분에 해당하는 금전이다.

즉 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 대여금채권에 대하여 甲의 채권자 丙이 600만 원의 채권으로써 압류의 범위를 제한하여 압류한 이후에 甲의 다른 채권자 丁이 500만 원의 채권을 가지고 배당요구한 다음 제3채무자 乙에게 공탁을 청구하였다면, 乙로서는 당초 압류된 금액인 600만 원만 공탁하면 된다.

42) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 432.

그런데 만일 위 丙이 600만 원의 채권을 가지고 압류의 효력범위를 집행채권액 등으로 제한하지 않은 채 압류를 하였다면 그 압류의 효력은 압류할 시점에 현실로 존재하는 목적채권의 전부에 미치고,⁴³⁾ 민사집행법 제248조 제2항의 「압류된 부분에 해당하는 금액」이란 집행채권액이 아닌 압류의 효력이 미치는 피압류채권액을 의미하므로 제3채무자인 乙로서는 위 예에서 1,000만 원 모두를 공탁하여야 한다.

나. 또한 제248조 제3항에 따른 압류 경합의 경우에는 각각 압류의 효력이 채권 전액으로 확장되므로(민집 제235조), 그 채권 전액을 공탁하여야 한다.

즉 위의 예에서 丁이 압류채권자라면 丙과 압류의 경합이 있는 것이어서 丙의 600만 원에 대한 압류도 피압류채권 전액으로 그 효력이 확장되고, 丁의 500만 원에 대한 압류도 그 전액으로 효력이 확장되므로 채권자 중 1인인 丁이 공탁을 청구하면 제3채무자인 乙은 피압류채권 전액인 1,000만 원을 공탁해야 하는 것이다.⁴⁴⁾

또한 경합 후에 일방의 채권압류명령이 취하·취소 등으로 인하여 압류의 경합이 해소되더라도 압류의 효력은 확장된 채로 남아 있게 되므로(확장유지설),⁴⁵⁾ 이때에도 제3채무자는 채권 전액을 공탁하여야 한다.

압류경합상태에 있는 피압류채권 중 일부에 관하여 일부 압류채권자가 추심명령에 기해 추심금 승소 확정판결을 받은 경우, 제3채무자가 위 확정판결에 기한 강제집행을 저지하기 위하여 집행공탁을 할 때 공탁하여야 할 금액 또한 채무 전액이다.⁴⁶⁾

43) 대법원 1973. 1. 24. 자 72마1548 결정; 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 323.; 이재성, “채권압류의 경합과 전부명령”, 이재성판례평석집 3(1982), 196. 이하

44) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2002다22700 판결【판결요지】구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제 6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제581조 제1항에 기한 제3채무자의 집행공탁은 피압류채권에 대한 압류경합을 요건으로 하는 것으로서, 이 경우 제3채무자가 위 법 규정에 따라 공탁하여야 할 금액은 채무 전액이라고 할 것이고, 이러한 법리는 압류경합상태에 있는 피압류채권 중 일부에 관하여 일부 압류채권자가 추심명령을 얻은 후 추심금청구소송을 제기하여 승소확정된 경우 제3채무자가 그 추심금청구 사건의 확정판결에 기한 강제집행을 저지하기 위하여 위 법 규정에 따라 집행공탁하는 경우에도 달리 볼 것이 아니다.

45) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 423.

46) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2002다22700 판결【판결요지】구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제 6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제581조 제1항에 기한 제3채무자의 집행공탁은 피압류채권에 대한 압류경합을 요건으로 하는 것으로서, 이 경우 제3채무자가 위 법 규정에 따라 공탁하여야 할 금액은 채무 전액이라고 할 것이고, 이러한 법리는 압류경합상태에 있는 피압류채권 중 일부에 관하여 일부 압류채권자가 추심명령을 얻은 후 추심금청구소송을 제기하여 승소확정된 경우 제3채무자가 그 추심금청구 사건의 확정판결에 기한 강제집행을 저지하기 위하여 위 법 규정에 따라 집행공탁하는 경우에도 달리 볼 것이 아니다.

다. 그리고 압류명령의 효력은 압류명령 송달 후에 발생하는 이자, 손해금에 미치는 것으로 되어 있으므로 피압류채권에 대한 압류명령 송달 후의 이자 또는 손해금을 포함하여 공탁해야 한다.

따라서 피압류채권의 변제기 도래 후에 공탁하는 경우는, 변제기(공탁의무가 발생한 때로부터가 아닌 것에 대해 주의)로부터 공탁일까지의 지연손해금(이자)가 생기는 채권에 대하여는 변제기로부터 공탁일까지의 이자를 합하여)을 덧붙여 공탁해야 한다.

다만 실제법상 이행지체가 없으면 지연손해금을 덧붙일 필요가 없는 점, 또 변제기 전이어도 공탁서에 기한의 이익을 포기한 뜻을 기재하고 변제기까지의 이자를 덧붙인 합계금액을 공탁하면 가능하다는 점 등에 대하여는 권리공탁에서 말한 대로이다.

또 압류명령의 송달 전에 이미 발생하고 있는 이자에 대하여도 전술한 권리공탁의 취지에 비추어 보아 이를 합하여 공탁하는 것이 가능하겠지만, 이 경우 공탁의 근거법령조항은 제248조 제1항 및 제248조 제2항으로 될 것이다.

4. 공탁 법원, 효과 등

제3채무자는 채권자나 채무자의 보통재판적이 있는 집행법원에 공탁할 수 있다(민집 제19조 제1항).

그리고 공탁하기 위해서 본래의 채무이행의 경우에 비하여 더 많은 여비, 일당 등이 필요하더라도 공탁하여야 할 금액에서 그 비용액을 빼고 공탁하는 것을 예정하고 있지는 않다. 그러나 제3채무자에게 공탁의무를 부담하게 하면서 이러한 불이익을 받도록 하는 것은 타당하지 않으므로 제3채무자는 공탁신고서를 낼 때까지 집행법원에 청구하면 공탁금 중에서 지급을 받을 수 있다[민사소송비용법 제10조의 2, 그런데 현행 실무는 의무공탁의 경우뿐만 아니라 권리공탁의 경우에도 제3채무자가 비용을 공제하고 난 후 공탁하는 것을 용인하고 있다고 보여지는데, 이 민사소송비용법 제10조의 2는 그 성질상 의무공탁의 경우에만 적용된다고 할 것이므로(권리공탁은 제3채무자의 채무변제행위에 불과하다), 실무는 이에 맞추어 권리공탁의 경우에는 비용 공제를 허용해서는 안 되리라고 본다.⁴⁷⁾ 이에 대하여는 제7장 집행공탁 제7절 IV. 및

47) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 510-511. 참조; 제3채무자로부터 사유신고서를 제출할 때까지 이러한 비용의 계산서가 제출되면, 집행법원은 그 내용을 심사하여 정당하다고 인정하는 때에는 지급결정을 하고 배당순위에 관계없이 공탁금으로부터 집행비용에 우선하여 법원사무관등이 지급위탁의 방법에 의하여 지급하게 될 것이지만, 이 비용만을 먼저 지급하게 되면 배당재단을 알기 어렵게 되고 공탁금의 지급절차가 번잡해질 수 있으므로 배당절차 중에서 지급하는 것도 무방하다고 본다.

제10장 배당등 절차 제7절 Ⅱ.에서 다시 논하기로 한다].

제3채무자는 공탁사실을 채무자에게 통지할 필요는 없다.

공탁으로 인해 변제의 효과가 생기므로 공탁한 금액은 확정적으로 공탁자인 제3채무자의 재산으로부터 분리되고, 제3채무자는 이를 회수할 수 없다. 제3채무자가 자신의 채무액보다 더 많이 공탁한 경우에는 배당에 참가한 채권자에게 부당이득반환청구를 할 수 있다.

V. 제3채무자에 의한 상계와 공탁

1. 압류명령을 송달받은 제3채무자는 그 뒤에 취득한 채권에 의한 상계로 그 명령을 신청한 채권자에게 대항하지 못한다(민법 제498조).

예컨대, 甲의 乙에 대한 채권이 甲의 채권자 丙에 의해 압류된 때에는, 제3채무자 乙은 압류 전부터 甲에 대하여 채권을 가지는 때에는 이를 자동채권으로 하여 상계할 수 있으나, 압류 후에 채권을 취득하여도 그 채권으로 상계하지 못하는 것이다.

이러한 제한을 둔 것은, 乙이 압류 전부터 甲에 대하여 반대채권을 가지고 있는 때에는 甲에 대한 자기의 채무는 상계로 청산할 수 있다는 기대(상계권)를 가지고 있는 것이 보통이므로 그러한 기대를 보호하기 위한 것이며, 또한 압류 후에 취득한 채권을 가지고 상계하지 못하는 것으로 한 것은, 이 경우라면 위와 같은 합리적인 기대가 없을 뿐만 아니라, 이를 허용하면 그러한 압류가 있는 때에는 언제나 반대채권을 만들어서 압류의 효력을 없게 함으로써 압류채권자를 해하게 되기 때문이다.

2. 위 민법 제498조를 적용함에 있어서는, 수동채권(압류된 채권) 및 자동채권의 변제기와 압류의 시기와의 관계가 문제로 되는바, 즉 자동채권, 수동채권의 변제기와 관련하여 압류명령의 송달을 받기 이전에 상계적상에 있어야 하는가, 특히 자동채권의 변제기가 도래하고 있어야 하느냐에 대하여 견해가 나뉘어지는 것이다.

이에 관하여 다수설⁴⁸⁾은 압류 전에 취득한 채권이라면 압류할 때 상계적상에 있든 없었던 묻지 아니하고 상계적상시에 상계할 수 있다는 입장이다.

48) 이영섭 편집대표, 주석강제집행법(중), 한국사법행정학회(1984), 79.; 兼子一, 增補強制執行法, 酒井書店(1979), 209.; 稻葉威雄, 注解強制執行法(2), 303.; 日最判 昭和 45(1970). 6. 24.(民集 24-6, 587)

그리고 종전의 판례⁴⁹⁾는 이에 대해 상계적상에 있어야 한다는 취지였으나, 현재에는 압류명령이 송달될 당시 제3채무자가 채무자에 대하여 가지는 채권(자동채권)과 압류된 채권(수동채권)이 모두 변제기에 도래하여 상계적상에 있었던 경우는 물론 상계적상에 있지 아니한 경우에도 자동채권만이 변제기가 지났거나, 또는 두 채권 모두 변제기가 지나지 않았더라도 자동채권이 먼저 또는 압류된 채권과 동시에 변제기에 도달할 경우에는 제3채무자의 상계를 허용하고 있다.⁵⁰⁾

3. 이와 같이 제3채무자가 채무자와의 사이에 상계권이 인정되는 경우에는 그 금액을 상계한 나머지 금액을 공탁할 수 있으며, 다만 이러한 때에는 공탁원인사실란에 위 상계의 의사표시 및 상계되는 금액을 명시하여 두는 것이 바람직하다.

VI. 담보권의 실행 등을 위한 압류와 일반채권에 기한 압류가 경합된 경우

1. 의의

민사집행법 제248조는 채권자들 사이에 우열의 순위가 없고, 평등배당을 전제로 하는 경우에 관한 규정이다.

이와 달리, 채권에 대한 담보권(질권 등)의 실행이나 물상대위권(민법 제342조, 제355조, 제370조, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제47조 등)의 행사의 경우에도 채권에 대한 강제집행의 규정이 준용되므로(민집 제273조 제3항), 이러한 경우의 압류와 채권에 대한 일반채권에 기한 압류 사이에도 경합의 문제

49) 대법원 1980. 9. 9. 선고 80다939 판결【판결요지】① 채권압류 및 전부명령에 있어 제3채무자는 그 명령이 송달되기 이전에 채무자에 대하여 상계적상에 있었던 반대채권을 가지고 그 명령이 송달될 이후에 상계로서 전부채권자에게 대항할 수 있다. ② 이 경우의 상계적상이라 함은 양 채권이 모두 그 변제기가 도래한 경우와 그 수동채권의 변제기가 도래하지 아니하였다 하더라도 그 기한의 이익을 포기할 수 있는 경우를 포함하지만 자동채권의 변제기가 위 명령송달 이전에 도래하지 아니한 경우는 상계적상에 있는 것이라고 할 수 없다.

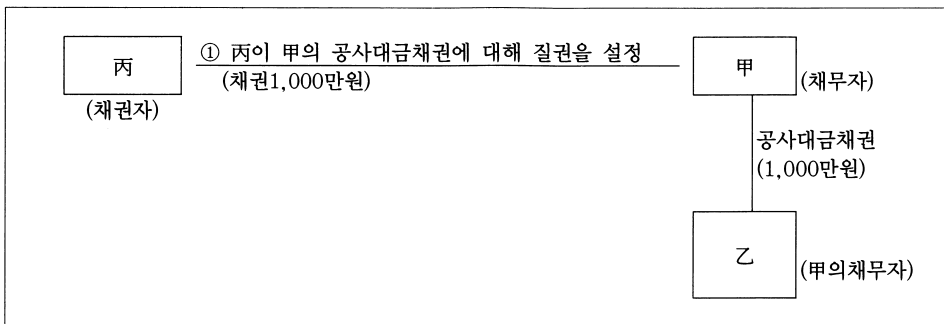
50) 대법원 1973. 11. 13. 선고 73다518 전원합의체 판결; 대법원 1982. 6. 22. 선고 82다카200 판결【판결요지】가압류 명령을 받은 제3채무자가 가압류채무자에 대한 반대채권을 가지고 있는 경우에 상계로써 가압류채권자에게 대항하기 위하여는 가압류의 효력발생 당시에 양 채권이 상계적상에 있거나, 반대채권이 압류 당시 변제기에 이르지 않는 경우에는 피압류 채권인 수동채권의 변제기와 동시에 또는 보다 먼저 변제기에 도달하는 경우이어야 된다.; 대법원 1989. 9. 12. 선고 88다카25120 판결【판결요지】채권가압류명령을 받은 제3채무자는 그 후에 취득한 채권에 의한 상계로 그 가압류채권자에게 대항하지 못하지만 수동채권이 가압류될 당시 자동채권과 수동채권이 상계적상에 있거나 자동채권의 변제기가 수동채권의 그것과 동시 또는 그보다 먼저 도래하는 경우에는 제3채무자는 자동채권에 의한 상계로 가압류채권자에게 대항할 수 있다.

가 발생할 수 있고, 그 때에는 전자가 후자에 비하여 우선권이 있어 채권자평등의 원칙이 적용되지 아니하므로 일반채권자들 사이에 압류가 경합하는 경우와는 약간 다르게 해석될 수밖에 없다.⁵¹⁾

2. 질권실행을 위한 압류 이전인 경우

가. 질권자의 직접청구권 및 공탁청구권

[사례1]



이 경우, 丙에 의한 채권질권의 효력은 입질된 채권의 원본이나 이자 등 모두에 미치고(민법 제334조), 질권자는 입질된 채권에 관하여 다른 채권자에 우선하여 자기 채권의 변제를 받을 수가 있으며(민법 제329조), 후행의 압류에 불구하고 질권의 목적인 된 채권을 직접 청구할 수 있다(민법 제353조 제1항).

여기에서 ‘직접 청구할 수 있다’는 의미는 제3채무자에 대하여 채무명의, 법원에 의한 청구권의 부여, 질권설정자의 추심위임 등을 요하지 않는다는 것을 의미한다.⁵²⁾

51) 민법 기타 특별법(민법 제342조, 제355조, 제370조, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제47조)에 담보권의 내용으로서 질권, 저당권 등의 목적물이 멸실, 훼손, 공용징수로 인하여 담보권설정자가 받게 될 금전 기타 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다는 규정을 둔 경우(담보권자의 물상대위권이 인정되는 경우) 그 행사에 있어서도 권리질권 실행의 방법이 그대로 적용된다(민집 제273조). 다만 직접 추심권을 인정한 민법 제353조는 그 적용이 없다. 따라서 권리질권의 실행에 있어서는 압류만 하고 따로 추심명령 등을 받을 필요가 없으나, 물상대위에 의한 경우는 추심명령, 전부명령 등의 현금화절차가 필요하다. 그밖에 순위 또는 효력 등에 있어서는 그 차이가 없으므로 여기서는 질권의 실행에 관해서만 설명하기로 한다.

52) 박윤직 편집대표, 위 민법주해(Ⅶ), 440.; 대법원 1960. 9. 1. 선고 4292민상937 판결 “지명채권을 질권의 목적으로 제공한 경우 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있고, 민사소송법에 규정된 집행방법으로 질권을 실행할 수 있다.”

질권설정자로부터 질권설정의 뜻을 통지받거나 입질을 승낙한 제3채무자는 질권설정자에 대하여 입질채권의 변제를 할 수 없다는 구속을 받게 되고(질권의 제3채무자에 대한 구속력),⁵³⁾ 또한 공탁에 의해서도 채무를 면할 수 없다. 제3채무자의 변제는 질권의 입질채권에 대한 배타적인 지배권능을 해하므로 이를 할 수 없다고 보는 것이고, 또한 질권자인 丙이 당해 채권을 직접 청구하거나(민법 제353조 제1항), 또는 채권을 압류한 후 이에 대해 추심 및 전부명령을 얻어 우선변제를 받을 수 있기 때문에 질권자의 승낙이 없는 한 공탁할 수 없게 하는 것이다.⁵⁴⁾

다만 제3채무자가 질권설정에도 불구하고 질권설정자에게 변제하였다면 이는 절대무효는 아니고, 그 효과를 가지고 질권자에게는 대항할 수 없을 뿐이다(제3채무자와 질권설정자 사이에는 효력이 있음). 따라서 질권자로서는 입질채권이 아직 존재하는 것으로 보아 제3채무자에 대하여 그 변제를 다시 청구할 수 있게 된다.⁵⁵⁾

질권자가 그 추심권(민법 제353조 제1항)을 행사할 수 있으려면, 자기의 질권설정자에 대한 채권(피담보채권) 및 입질채권의 변제기가 도래되어 있을 필요가 있다. 따라서 피담보채권의 변제기가 도래하기 전에 입질채권의 변제기가 먼저 도래한 경우라면 질권자로서는 제3채무자에게 직접적으로 추심하지 못하고 그렇다고 하여 제3채무자가 질권설정자에게 변제하는 것이 가능하다고 하면 그로 인해서 질권자를 해할 염려가 있다. 그래서 이러한 경우를 대비하여 민법은 질권자로 하여금 제3채무자에게 변제금액의 공탁을 청구할 수 있는 것으로 규정하였다(민법 제353조 제3항 전단).⁵⁶⁾

이러한 질권자의 공탁청구를 받은 제3채무자는 당연히 채무액을 공탁하여야 한다.⁵⁷⁾ 이 공탁은 그 실질이 변제공탁이므로 채무이행지 공탁소에 공탁하여야 하고(민

53) 박윤직 대표, 위 민법주해(Ⅵ), 437.

54) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 351, 490, 등

55) 박윤직 대표, 위 민법주해(Ⅵ), 437.

56) 만일 피담보채권과 입질채권의 변제기가 동시에 모두 도래하였거나 또는 피담보채권의 변제기가 먼저 도래하였다면 민법 제353조 제3항에 따른 공탁을 할 수는 없고, 이 경우에는 민법 제353조 제2항, 제1항이 적용되어 질권의 직접청구가 가능하므로, 제3채무자는 질권자의 청구(추심권 행사)가 있는 경우에는 질권자에게 변제를 하여야 하고, 질권자의 청구가 없는 때에는 변제제공을 하여 질권자의 수령거절사유가 있는 경우 민법 제487조에 의한 변제공탁을 할 수 있을 것이다(이 경우 피공탁자는 질권설정자가 아니라 '질권자'이다). 그리고 후행하여 다른 채권자에 의한 압류가 있다고 하더라도 그를 이유로 민사집행법 제248조 제1항을 추가한 혼합공탁을 할 수는 없다. 이 때에는 공탁할 당시 질권자가 압류채권자보다 실체법상 우선적 효력이 있고, 피담보채권의 변제기가 도래함으로써 인하여 그 우선적 효력을 확정적으로 취득하여 압류채권자로서는 후순위권자로서 의미가 없게 되기 때문이다.

57) 그리고 입질채권의 변제기가 도래하기 전에도 제3채무자는 스스로 기한의 이익을 포기하고 공탁할 수 있는 것은 당연하다.

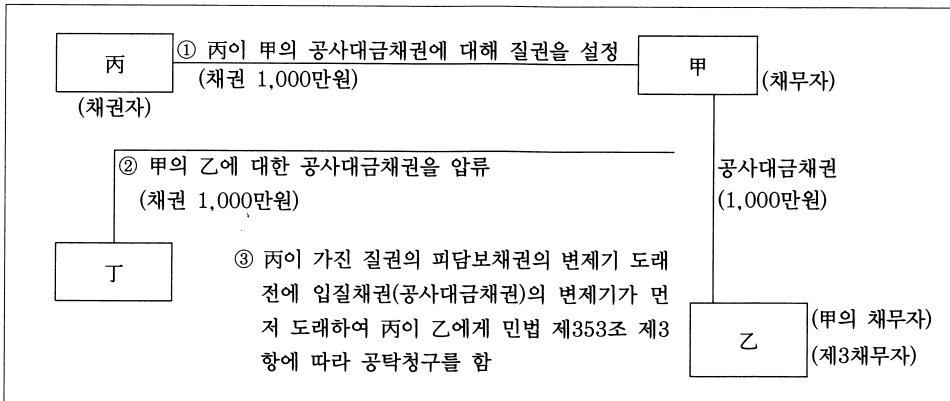
법 제488조 제1항), 공탁근거조문은 「민법 제353조 제3항」이며, 피공탁자로는 「질권 설정자(甲)」를 기재해야 한다.

이와 같이 하여 채무액이 공탁되면 질권은 그 공탁금(실제로는 질권설정자의 공탁물출급청구권)위에 존재하는 것으로 되어 있다(민법 제353조 제3항 후단).

그러므로 피담보채권의 변제가 도래한 후에 자신이 질권자임을 공탁소에 증명하고 추심권을 행사함으로써 공탁금의 출급을 받아 피담보채권의 변제에 충당할 수 있다.

나. 질권설정 후 일반채권에 의한 압류집행이 있는 경우의 공탁

[사례2]



1) 질권 설정의 대항요건이 우선하는 경우

위와 같은 경우, 위 질권과 강제집행에 의한 압류명령의 우선순위는 질권 설정이 제3자에 대한 대항요건을 갖춘 때와 압류명령이 제3채무자에게 송달되어 압류의 효력이 발생한 때의 선후에 의하게 되는데,⁵⁸⁾ 먼저 질권 설정의 대항요건이 압류명령의 효력 발생보다 우선하는 경우에 관하여 살펴본다.

이 경우 제3채무자는 어떠한 공탁을 해야 하는가.

위의 예에서 질권자인 丙이 피압류채권 전액에 대해 질권을 설정한 경우라면, 그 모두에 대해서 질권자가 압류채권자에 대해 우선하므로 제3채무자는 그저 민법 제

58) 東京地裁債權執行等手續研究會, 債權執行の諸問題, 判例クイムズ社, 268.; 지명채권에 대한 질권의 대항요건은 민법 제349조에 따라 지명채권양도의 대항요건과 동일하다. 따라서 설정자가 민법 제450조에 따라 확정일자 있는 증서에 의해 제3채무자에게 질권설정 사실을 통지하거나 제3채무자가 이를 승낙함이 아니면 이로써 제3채무자 기타 제3자에게 대항하지 못하는데, 채권양도의 대항요건과 다른 압류 등 채권자 사이의 우열관계가 채권양도 통지 및 압류명령 등의 송달에 의하듯이 질권과 압류명령 등과의 우열관계도 이에 준하여 생각될 수 있는 것이다.

353조 제3항을 근거로 공탁하면 그에 의해 면책될 수 있을 것이다. 이때 공탁근거법령은 「민법 제353조 제3항」을, 피공탁자는 「질권설정자(甲)」를 기재하면 된다.

그런데 이 경우는 질권만 설정되어 있었던 앞서와 경우와 다른 점이 있다. 즉 질권 설정 후에 일반채권자인 丁이 동일한 채권을 압류한 것이 있어서 마냥 위와 똑같이 볼 수는 없다는 것이다. 왜냐하면, 이 경우 제3채무자인 乙이 민법 제353조 제3항에 따라서만 공탁해버린다면 그것을 가지고 질권설정자 및 질권자에 대한 관계에서는 대항할 수 있을 것이지만, 질권도 질권자의 포기 등에 의해서 효력을 상실할 수도 있으므로 만약 이러한 상황이 발생한다면 제3채무자는 이러한 공탁만으로는 그 이후의 다른 압류채권자인 丁에게는 대항할 수 없게 되는 수가 있어 이중지급의 위험을 부담할 가능성이 있기 때문이다.

따라서 이러한 경우에는 다른 이해관계 있는 채권자 및 제3채무자의 보호를 위해 민법 제353조 제3항에 의한 공탁과 압류가 경합된 경우에 있어서 민사집행법 제248조에 의한 공탁과의 혼합공탁을 하는 것이 보다 안전한 방법이 될 것이다.⁵⁹⁾

이와 같이 된 혼합공탁의 경우에는 공탁서의 공탁근거법령을 「민법 제353조 제3항 및 민사집행법 제248조 제1항」이라고 기재하고, 피공탁자란에는 「질권설정자(甲)」라고 기재하며, 집행공탁에 있어서 그 출급청구권자는 집행법원의 배당에 의한 지급위탁에 의하여 정해지므로 질권 후에 경합된 압류채권자(위에서 丁)는 공탁서에 피공탁자로 기재하지 않는다.

☞ 이때, 공탁원인사실은 다음과 같이 기재하면 된다.

「甲은 공탁자인 乙에 대하여 1,000만 원의 공사대금채권(변제기 연월일, 변제장소 피공탁자의 주소)을 가지고 있는데, 공탁자는 2018. 0. 0. 피공탁자로부터 위 채권에 관하여 피공탁자의 채권자 丙이 피공탁자에 대하여 가지고 있는 1,000만 원의 대여금채권(변제기 연월일)의 담보로서 이에 아래와 같은 질권을 설정한 뜻의 통지를 받았고, 이어서 2018. 0. 0. 질권자 丙으로부터 위 금액에 관하여 민법 제353조 제3항에 따른 공탁청구를 받았으나, 다시 위 채권에 관해서 아래와 같이 丁에 의한 압류가 경합하게 되었다. 그런데 위 질권의 효력이 아직 확정되지 아니하였는데, 그 효력 여하가 후행 압류 등의 효력에 영향을 미치고 있으므로 민법 제353조 제3항, 민사집행법 제248조 제1항에 따라 위 1,000만 원에 변제기의

59) 大森淳, “質權者による供託請求がない場合の供託の可否”, NBL 376号, 26.; 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 265.

다음날부터 공탁일까지의 지연손해금 50만 원을 합한 1,050만 원을 공탁한다.

아 래

1. 질권자 丙, 질권설정자 甲, 질권설정금액 1,000만 원으로 하는 甲의 공탁자에 대한 질권설정통지(확정일자 있는 서면) 2018년 ○월 ○일 도달
2. ○○ 법원 2018타채0000호 채권자 丁, 채무자 甲, 제3채무자 공탁자로 하는 채권압류명령, 청구채권액 1,000만 원, 압류채권액 1,000만 원, 2018년 ○월 ○일 송달」

그리고 위와 같이 혼합공탁이 되면, 그 공탁의 성질 속에 집행공탁도 포함하고 있기 때문에 제3채무자는 공탁서를 첨부하여 압류명령을 먼저 발령한 집행법원에 사유신고를 해야 한다(민집 제248조 제4항).

그런데 여기에서 이러한 혼합공탁에 의한 사유신고서를 제출받은 집행법원이 압류경합에 따른 배당절차를 진행시킬 수 있을 것인가 여부가 문제되는데, 위와 같은 경우에는 질권이 위에서 본 포기 기타 사정 등에 의해서 그 효력이 상실되었음이 집행법원에 증명되지 않는 한(즉 혼합해소가 증명되지 않는 한) 배당절차를 진행시킬 수 없다고 보아야 한다.⁶⁰⁾

그리고 질권자는 질권 실행을 위한 압류명령을 신청하거나 배당요구 등을 하지 않는 한, 자신의 질권에 기초한 청구권을 행사하여 공탁소로부터 공탁금의 출급청구가 가능한가 어떤가 하는 것만이 문제되는 것이고(그것은 피담보채권의 변제기가 도래해야만 가능할 것이다. 즉 피담보채권의 변제기가 도래하면 공탁소에 대하여 자신이 질권자임을 증명하여 공탁금을 추심할 수가 있다), 집행법원의 배당등 절차에서 배당등을 받을 채권자가 되는 것은 아니다.⁶¹⁾

2) 압류명령이 먼저 송달된 경우

나아가 위와 반대로, 제3채무자에 대하여 압류명령이 송달된 후에 질권설정이 제3자에 대한 대항요건을 구비한 때에는 그것은 압류명령의 처분금지효에 위반되는 것으로 되기 때문에 질권설정이 무시되므로 제3채무자는 민사집행법 제248조에 의해 집행공탁을 할 수 있고, 또한 집행법원은 이 경우 바로 배당등 절차를 진행할 수 있다.

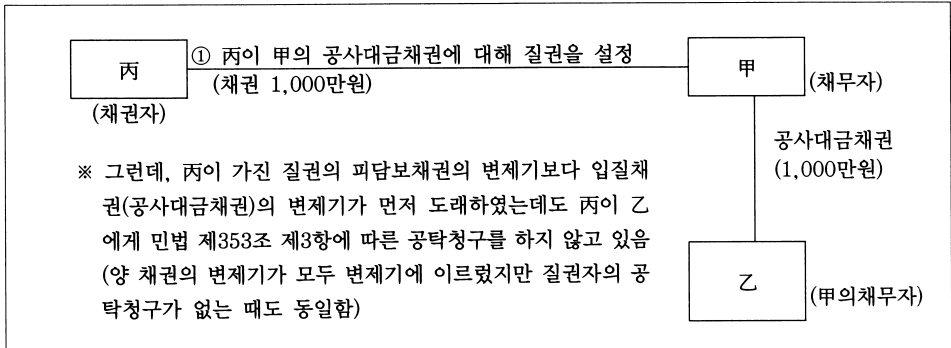
60) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 265.

61) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 265-266.

다. 질권자가 공탁청구권을 행사하지 않는 경우

1) 질권 설정만 되어 있는 경우

[사례3]



가) 이미 보았듯이 질권자는 그 질권의 실행으로서 직접 제3채무자로부터 추심할 권리가 있으므로(민법 제353조 제1항, 제2항), 제3채무자는 질권의 포기 또는 해제가 되어 있지 아니한 상황에서는 질권자의 승낙이 없는 한 공탁에 의하여 채무를 면할 수 없다.⁶²⁾

그러나 위 사례와 같은 경우에 제3채무자에게 공탁을 인정하지 않으면 제3채무자는 질권자가 피담보채권의 변제기 후에 그 실행을 할 때까지 사이에 질권에 의한 구속을 받아 입질채권의 변제기가 도래해도 질권설정자에게는 변제하지 못한 채 입질채권의 관계에서는 이행지체의 책임(지연손해금의 발생 등)을 부담하게 되어서 제3채무자에게 가혹한 결과를 안겨 주게 될 것이다.

나) 이러한 제3채무자의 불리한 지위를 구제해주기 위한 견해들이 다음과 같이 나타나고 있다.

(1) 제1설(수령불능을 원인으로 한 변제공탁설) : 이 설은 입질채권의 변제기가 먼저 도래하였는데도 질권자가 공탁청구를 하지 않는 경우라면 그 청구가 없더라도 질권자가 변제를 수령할 수 없는 때에 해당한다고 볼 수 있으므로 제3채무자로서는 민법 제487조 전문에 따라 변제공탁을 함으로써 채무를 면할 수 있다는 견해이다.⁶³⁾

62) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 490.

63) 앞의 민법주해 [6], 437.; 박준서 대표, 주석민법 [물권], 한국사법행정학회(1993), 525.; 林良平, 注釋民법(1983), 有斐閣(1983), 61.; 柚木馨, 高木多喜男 共著, 擔保物權法(新版), 有斐閣, 157.

그러나 이 견해는 질권자의 수령불능을 원인으로 변제공탁을 하는 것이므로 피공탁자를 질권자로 하여야 할 것인데, 아직 피담보채권의 변제기가 도래하지 않아 질권에 기한 추심권의 행사가 없는 상태에서는 질권자는 단지 담보권을 가지는 것일 뿐 피담보채권의 주체가 되지 못하고 그 추심 전의 주체는 본래의 채권자인 질권설정자라고 보아야 하므로 이러한 추심권 행사 전에 있어서의 질권자는 변제공탁의 피공탁자가 되지 못한다 할 것이다. 또한 앞서 본 바와 같이 제3채무자는 질권의 구속력을 받아도 질권설정자에게 변제하는 것이 금지되는 것은 아니고, 다만 그 변제로써 질권자에게 대항할 수 없는데 불과한 것으로서 이러한 경우에 질권설정자가 반드시 수령불능상태에 있다고는 말하기 어렵다. 하지만 그런 이유로 위 변제공탁에서 피공탁자를 질권설정자로 한다고 해도 난점이 있다. 즉 이러한 때에는 민법 제353조 제3항 후단(이 조항은 질권자가 공탁청구한 때에 그 질권의 효력이 공탁금 위에 존재한다는 것이다)과 같은 규정이 없으므로 질권자의 질권이 질권설정자의 공탁금출급청구권에 미치지 않게 되어 결국 위 공탁으로써 질권자에게 대항할 수 없다는 결론에 이르고 마는 것이다. 따라서 위 제1설을 취하기 위해서는 위와 같은 난점이 먼저 해결되어야 할 것이다.

(2) 제2설(채권자불확지를 원인으로 한 변제공탁설) : 이러한 경우에 질권자가 추심권을 행사하기까지의 사이에는 채권자가 질권자인지 질권설정자인지 확인할 수 없으므로 제3채무자로서는 변제자의 과실 없이 채권자를 알 수 없는 경우에 해당하는 것으로 보아 민법 제487조 후문에 따른 변제공탁을 할 수 있다는 견해이다.⁶⁴⁾

하지만 이 견해도 이러한 경우에 있어서 질권자가 민법 제487조 후문에서 말하는 「채권자」라고 볼 수 있는지 여부에 관하여 다시 논쟁이 시작되어야 하는데, 과연 그와 같이 볼 수 있는지가 의문이므로 이 견해 역시 선뜻 따르기 어렵다.

다) 결국, 위에서 본 어떠한 견해도 먼저 변제기가 도래한 입질채권의 제3채무자의 지위를 편안하게 해주지는 못하고 있으며, 그럴 경우 제3채무자로서는 이에 관한 법적 근거가 없는 한 이행지체 책임을 지더라도 공탁에 의해 채무를 면할 수 없다는 결과가 되고 만다.

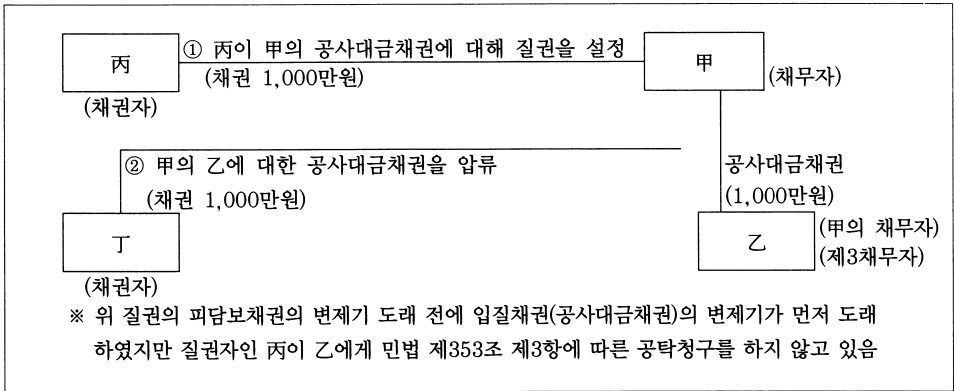
생각건대 이 경우 기본적으로는 그에 관한 법령의 정비를 필요로 하고 있다고 보이지만, 그때까지는 질권자 및 제3채무자 쌍방의 이익을 고려하여 입질채권의 변제기가 먼저 도래하면 질권자에 의한 민법 제353조 제3항에 따른 공탁청구가 있다고

64) 남기정, 실무서식공탁절차, 육법사(1991), 147.

확장해석함으로써 이 조항을 근거로 제3채무자가 공탁할 수 있다고 해석하는 것이 가장 최선의 방법이라고 보여진다.⁶⁵⁾

2) 질권 설정 후 압류집행이 있는 경우

[사례4]



가) 질권이 압류에 우선하고 있는 경우에는 질권자는 설사 후행하는 압류가 존재 하더라도 질권실행으로서 직접 제3채무자로부터 추심할 수 있고(민법 제353조 제1항, 제2항), 질권의 포기 또는 해제가 되어 있지 아니한 상황에서는 제3채무자로서도 압류채권자에 대해서 지급할 형편에 있지 아니하므로 제3채무자로서는 이러한 경우에도 공탁에 의해서 채무를 면할 수가 없다.

하지만 이때도 위 1)의 경우와 같이 제3채무자에게 일정한 불이익이 있게 되므로 이러한 경우에 제3채무자에게 공탁을 인정함으로써 채무를 면하게 할 수 있는가, 만약 가능하다면 제3채무자는 어떠한 공탁을 해야 하는가 여부 등에 관하여 다음과 같은 견해가 등장하고 있다.

나) 먼저, 이를 소극적으로 보는 견해⁶⁶⁾는, 압류를 원인으로 하는 제3채무자의

65) 남기정, 실무공탁요론, 법률문화원(1992), 180.; 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 263-264.; 이에 대하여 위 법원실무자료 민사집행(Ⅲ), 355.은 이 경우 민법 제487조의 변제공탁을 인정할 여지가 있다고 하고 있으나, 그 변제공탁이 민법 제487조 전단에 의한 공탁인지 아니면 제487조 후단에 의한 공탁인지, 또 이와 같이 변제공탁을 인정하는 근거가 무엇인지 등에 관하여는 아무런 언급이 없다.

66) 中野貞一郎, 民事執行法(下), 550.[東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 266.에서 재인용] 이하; 昭和62(1987). 3. 24. 民事四卷 439号 法務省民事局長回答, 先例集 7卷 166. “甲이 乙에 대하여 가지는 금전채권에 대하여 丙을 질권자로 하는 질권설정 후에 위 채권에 대한 甲의 다른 채권자 A 및 B에 의한 압류가 경합한 경우, 채권의 변제기가 도래하여도 질권이 소멸하지 않는 한(일본)민사집행법 제156조 제2항에 의한 공탁의무는 생기지 않는다.”

공탁은 집행절차의 일환인 집행공탁이고, 그에 따라 배당가입의 차단효과 생기고(민집 제252조), 또한 곧바로 배당절차를 실시하게 되므로 압류 이전에 대항요건을 구비한 질권이 설정된 경우에는 질권에 우선하지 못하는 압류채권 등을 위해서 배당을 실시할 수 없기 때문에, 이 경우 제3채무자는 공탁할 수 없다고 보고 있다.

이에 대해서, 적극설은 이 경우 제3채무자에게 공탁할 권리를 인정하지 않는다면 제3채무자의 채권자(집행채무자)에 대한 금전채무의 변제기 도래에 의해서 이행지체로 되고, 그로 인한 지연손해금의 발생 등의 불이익을 받게 되기 때문에 그 공탁을 인정해야 한다는 견해들인데, 그 근거에 관해서는 또 입장이 나뉘어지고 있다.

그 가운데 제1설은, 민사집행법 제248조 제1항의 권리공탁규정은 채권압류가 1개인 경우라도 제3채무자의 입장에서 보아 어느 쪽에 변제하는가를 정하기 곤란하고, 압류채권자가 추심에 착수하지 않기 때문에 변제하고 싶어도 변제할 수 없는 경우에 있어서 그 부담을 경감하기 위한 규정이므로 이 경우 위 규정에 따라 공탁할 수 있다고 주장하고,⁶⁷⁾ 제2설은 민법 제487조 전단 또는 후단에 의한 공탁과 민사집행법 제248조 제1항 또는 제3항을 근거로 하는 혼합공탁에 의할 것이라는 견해이며, 제3설은 민법 제353조 제3항에 의한 공탁과 민사집행법 제248조 제1항 또는 제3항을 근거로 하는 혼합공탁에 의할 것이라고 주장한다.

다) 살피건대, 위 견해들 중 소극설은 제3채무자가 압류를 원인으로 하는 공탁을 하면 배당가입차단효과 생기고, 바로 배당등 절차가 실시되므로 선행하는 질권이 유효하게 존재하는 한 그에 우선하지 못하는 압류채권자들을 위해서 “곧바로” 배당절차를 진행할 수 없기 때문에 이 경우 질권자의 공탁청구가 없는 한 공탁을 인정할 수 없다는 취지이나, 위와 같이 “곧바로” 배당등 절차를 진행할 수 없는 것은 질권자의 공탁청구가 있는 경우에도 제3채무자의 공탁에 의해 배당가입차단효과 생기고 있지만 집행법원이 다른 사정에 의하여 곧바로 배당등 절차 등을 진행하지 못하는 경우도 상정될 수 있으며, 이는 또한 집행법원의 절차 진행에 따라 조정될 수 있는 것이므로 이를 들어 공탁을 부정하는 것은 제3채무자의 이익을 너무 도외시하는 것이라고 생각된다.

그리고 적극설 중에서 제1설은 그 공탁에 의해서 질권자에 대해 면책되는 근거를 찾기 어렵고, 제2설은 위 1)에서 본 바와 같이 이 경우 제3채무자에게 바로 민법

67) 小林秀之, “質權が設定されている金銭債權に對して押留えが競合した場合における供託義務”, 供託先例判例百選, 別冊ジュリ107号, 141.

제487조에 의한 변제공탁을 인정하기는 어려우므로 그것을 포함하는 혼합공탁 또한 인정할 수 없다.

따라서 이 경우도 민법 제353조 제3항을 확장해석함으로써 위 규정에 의한 공탁과 민사집행법 제248조의 집행공탁과의 혼합공탁을 인정하는 제3설이 가장 타당하다고 본다.⁶⁸⁾

그러므로 이 경우에 관한 그 이후의 취급은 앞에서 본대로 질권자의 공탁청구가 있는 경우에 관하여 설명하였던 것과 거의 동일하게 생각하면 될 것이다.

☞ 즉 피공탁자는 「질권설정자(甲)」, 공탁근거법령은 「민법 제353조 제3항, 민사집행법 제248조 제1항」이 된다. 그리고 이때, 공탁원인사실은 다음과 같이 기재하면 된다.

「甲은 공탁자인 乙에 대하여 1,000만 원의 공사대금채권(변제기 연월일, 변제장소 피공탁자의 주소)을 가지고 있는데, 공탁자는 2018. ○. ○. 피공탁자로부터 아래와 같이 위 채권에 관하여 피공탁자의 채권자 丙이 피공탁자에 대하여 가지고 있는 1,000만 원의 대여금채권(변제기 연월일)의 담보로서 이에 질권을 설정한 뜻의 통지를 받았으나, 다시 위 채권에 관해서 아래와 같이 丁에 의한 압류가 경합하게 되었다. 그런데 위 질권의 효력이 아직 확정되지 아니하였는데, 그 효력 여하가 후행 압류 등의 효력에 영향을 미치고 있으므로 민법 제353조 제3항, 민사집행법 제248조 제1항에 따라 위 1,000만 원에 변제기의 다음날부터 공탁일까지의 지연손해금 50만 원을 합한 1,050만 원을 공탁한다.

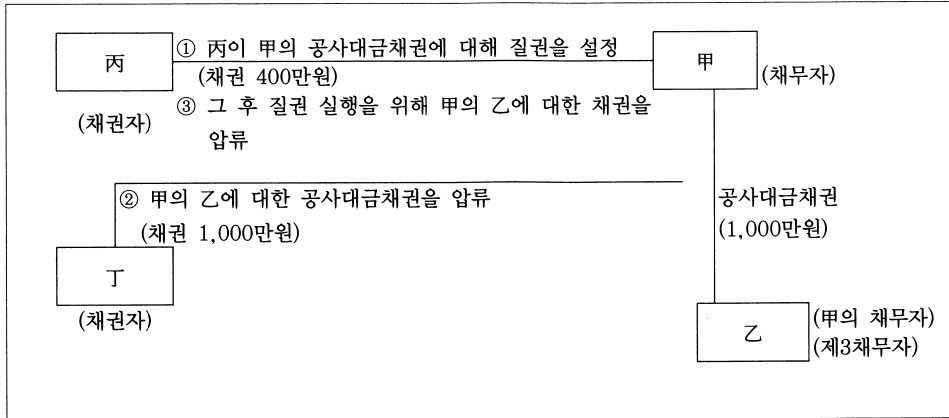
아 래

1. 질권자 丙, 질권설정자 甲, 질권설정금액 1,000만 원으로 하는 甲의 공탁자에 대한 질권설정통지(확정일자 있는 서면) 2018년 ○월 ○일 도달
2. ○○ 법원 2018타채○○○○호 채권자 丁, 채무자 甲, 제3채무자 공탁자로 하는 채권압류명령, 청구채권액 1,000만 원, 압류채권액 1,000만 원, 2018년 ○월 ○일 송달」

68) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 267.

3. 질권실행을 위한 압류가 있는 경우

[사례5]



위 사례는 앞의 경우와 달리 질권자가 이제 담보권실행을 위한 압류를 한 경우에 관한 것이다(丙이 피압류채권 모두에 대해 질권을 설정한 경우도 거의 동일하지만 여기서는 아래 설명의 편의를 위해 400만 원만 질권을 설정했다고 보는 것이다).

가. 압류의 경합 여부

1) 압류의 경합이란 개념에 대해서는 앞서 제6장 「집행의 경합」을 살펴볼 때에 보았듯이, 이는 어떤 동일한 채권에 대하여 여러 개의 채권압류 등이 경합되어 있고, 또한 이와 같이 경합적으로 집행된 압류의 합계액⁶⁹⁾이 피압류채권액을 넘어서고 있는 경우를 말한다고 볼 수 있다.

이러한 압류의 경합이 있는 경우에는 우리 집행법이 취하고 있는 채권자평등주의의 실현을 위하여 다음과 같은 효력이 인정된다.

즉 ① 각 압류가 목적채권의 일부에 대한 것이었다고 하더라도 그 압류의 효과가 목적채권의 전부에까지 확장되는 효력(압류효의 확장, 민집 제235조)이 있고, ② 경합에 관계된 압류채권자나 가압류채권자의 청구가 있을 경우 제3채무자는 그 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁할 의무가 있으며(제3채무자의 공탁의무, 민집 제248조

69) 만일 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 1,000만 원의 채권에 대하여 채권자가 600만 원의 집행채권을 가지고 압류를 한 경우, 그가 압류의 효력범위를 위 집행채권액 등으로 제한하였다면 집행채권액과 압류액의 양자는 일치할 것이나, 위와 같이 압류의 효력범위를 한정하지 않았다면 집행채권액은 600만 원인 반면, 압류액은 1,000만 원이 될 것이므로 양자는 불일치하게 될 것이다.

제3항, 구 민소법하에서라면 압류가 경합된 경우에 한해서 제3채무자는 그 법 제581조 제1항에 따라 권리로서 집행공탁을 할 수 있고, 또한 채권자의 공탁청구가 있을 때에는 위 제581조 제2항에 의해 공탁의무가 발생하는 등 압류 경합에 따른 제3채무자의 집행공탁권리 및 의무가 있는 것으로 규정되어 있었으나, 현행 민사집행법은 압류가 경합된 경우가 아니라도 제248조 제1항에서 제3채무자로 하여금 공탁할 수 있는 권리를 인정하고 있으므로 이제는 권리공탁에 관한 부분은 압류 경합의 효과로 다루기가 적절치 않게 되었다고 보아야 한다), 또한 ③ 각 압류는 그 선후에 관계없이 서로 배당요구를 한 것과 같은 효력(배당요구의 효력)이 발생하게 되는 것이다.

2) 따라서 여기서의 문제는 위의 사례에서 丙의 질권에 기한 압류와 丁의 일반채권에 기한 압류 사이에 위와 같은 압류의 경합을 인정할 수 있을 것인가에 관한 것이다.

이에 관하여는 적극설⁷⁰⁾과 소극설⁷¹⁾이 나오고 있고, 그 중 전자의 견해는 민사집행법 제235조가 같은 법 제273조 제3항에 의하여 명문으로 채권과 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행절차에 준용되고 있고, 채권의 집행단계를 압류·현금화·만족이라는 3단계로 구분하여 볼 때, 우선 압류단계라는 것은 목적채권에 대한 처분 제한을 위한 것으로서 우선채권이나 일반채권 사이에 그 효력에 차이를 둘 이유가 없으므로 경합된 부분에 대한 압류 자체의 효력은 동등하게 그 부분에 미쳐 경합한다고 보아야 한다는 것이나, 민사집행법 제235조 등 채권압류의 경합에 관한 조문들은 경합하는 각 집행채권자가 평등한 관계에 있음을 전제로 하여 그들 사이의 이해관계를 조절하기 위하여 규정된 것이므로 외관상은 채권압류가 경합된 것처럼 보이더라도 실제법상 어떤 채권자의 채권이 다른 채권자에게 우선하는 관계에 있을 때에는 위 각 조문들은 그 적용이 배제되어야 할 것이므로 소극설이 보다 타당하다고 본다.⁷²⁾

나. 압류효의 확장 여부

1) 민사집행법 제235조가 일반채권자들 사이의 압류에 있어서 그 경합이 일부만 발생하여도 양 채권의 압류의 효력이 피압류채권 전액으로 확장되도록 인정하고 있는

70) 신동기, “우선권 있는 채권에 기한 채권압류와 일부채권에 기한 채권압류가 일부 경합된 경우의 전부명령의 효력”, 판례연구 3집(1993. 02.) 부산판례연구회, 457.

71) 윤진수, “압류의 경합”, 민사집행에 관한 제문제(상), 재판자료 제71집, 351.

72) 필자는 초판을 집필할 당시, 이 문제에 관하여 적극설의 입장을 취하고 있었으나, 개정판에서 이와 같이 그 견해를 소극설로 바꾸었다. 이는 현재의 민사집행법 제235조가 일반채권자들 사이의 채권자평등주의를 실현하기 위한 규정이라는 기본적 전제는 소극설의 주장과 일치하고 또 그것이 정당하므로 이를 반영한 것이며, 압류의 경합에 관하여 적극설을 취하면서 그 이후에 압류효 확장의 효력을 인정하지 않는 것도 이론적으로 맞지 않다는 고려하에서 이를 수정한 것이다.

이유는 채권자평등주의를 취하는 일반채권에 있어서 채권자를 보호하기 위한 것이다.⁷³⁾

다시 말해, 압류가 일부라도 경합되면 각 채권자는 자신의 채권 전부의 만족을 얻을 수 없게 되는데, 만일 일부라도 압류 경합이 안된다고 하여 그 부분에 대해 일반 채권자의 우선적 만족을 주게 되는 전부명령 등을 인정하게 되면 결과적으로 평등 배당을 할 수 없게 되므로 이러한 결과를 막고 추심절차나 또는 특별현금화절차로 나아가 그 추심금, 환가금이 각 채권자에게 안분되도록 하여야 하는바, 그 방안으로서 압류가 일부만 경합하여도 그 압류효를 피압류채권 전액으로 확장시키는 것이 가장 간명하고 효과적인 방법이라고 보아 이러한 확장효를 인정하고 있는 것이다.

따라서 이 사안과 같이 일반채권에 비하여 실체법상 우선권이 있어서 채권자 평등의 원칙이 적용되지 아니하는 경우, 즉 우선권 있는 채권압류와 일반채권에 기한 채권압류가 외관상 일부 경합되었을 경우에는 양 채권의 성질상 우선권 있는 채권압류에 대하여 평등분배를 위한 압류효의 확장을 인정할 필요가 없다.⁷⁴⁾

그러므로 이 경우 丙은 자신의 채권인 400만 원 범위 내에서만 丁과의 사이에서 압류의 중복(외관상 또는 형식상 압류의 경합)이 발생하고 그 나머지 부분(600만 원)으로 그 압류의 효력이 확장되지 아니한다.⁷⁵⁾

그리고 이러한 경우 담보권자인 丙은 우선변제권의 범위 내에서 우선하게 되므로 압류가 형식상 경합하더라도 담보권자인 丙은 그 압류에 기해 위 400만 원에 대하여 전부명령 또는 양도명령을 얻을 수 있고, 또는 고유의 추심권능에 기초하여 추심권을 행사할 수도 있다.

2) 다른 한편 위의 경우에 질권자인 丙이 400만 원의 채권으로서 질권실행을 위한 압류를 하고, 다른 일반채권자인 丁이 800만 원의 채권을 가지고 압류명령을 받은 다른 예를 생각해보자.

위에서 보았듯이 丙의 압류의 효력은 피압류채권 중 나머지인 600만 원 부분으로 확장되지 않지만, 丁의 채권압류의 효력은 어떠할까. 즉 이 문제는 담보권 실행을

73) 신동기(주70), 450.; 조정래, “채권에 대한 강제집행에 있어서의 다수채권자의 경합”, 재판자료 제35집, 1987, 443.

74) 신동기(주70), 455, 457.; 윤진수(주71), 351, 354, 등; 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다 12233 판결

75) 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결; 신동기(주70), 455.; 윤진수(주71), 354, 등; 만약 위 사례에서 丁이 피압류채권 전액이 아닌 800만 원만을 압류한 경우 丁의 압류의 효력도 나머지 피압류채권 부분으로 확장되지 아니한다.

위한 압류와 일반채권에 의한 압류가 형식상 경합할 때에 일반채권에 기한 압류 효력의 편면적 확장을 인정할 수 있을지의 문제를 살펴보자는 것이다.

이에 관하여는, 담보권자에 의한 추심 후의 잔여액에 대하여 다른 일반채권자의 권리실현을 도모할 필요상 혹은 담보권실행 내지 행사를 취한 후에 배당등 절차를 행할 필요상, 일반채권에 기한 압류의 효력이 편면적으로 확장된다고 보는 견해(적극설)⁷⁶⁾과 이 경우 질권 실행을 위한 압류와 일반채권에 기한 압류 사이에서는 우선채권과 일반채권의 관계로서 양자 사이에 압류의 경합을 인정하기 어렵고 또 그에 따라 압류 효력의 확장을 인정할 여지가 없으므로 편면적 압류효의 확장도 이를 부정하는 견해(소극설)⁷⁷⁾이 나타나고 있다. 이론적인 면에서 볼 때 소극설의 견해가 타당하다고 볼 것이나, 다만 그와 같이 할 경우 다른 일반채권자의 권리실현이 복잡하거나 난항을 겪을 수 있고 배당절차의 진행이 어려워지는 등의 실례상 문제에 봉착하게 된다. 앞으로 이를 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

다. 추심 및 공탁의 문제

1) 丙이 위 질권실행을 위한 압류에 기해 추심권을 행사하면 乙은 그에게 그 채권 400만 원을 지급하면 면책된다.⁷⁸⁾

丙이 위 압류에 기해 전부명령 또는 양도명령을 받으면 400만 원 범위 내에서 질권자인 丙에게 이전하게 되므로 우선변제받게 되는 것과 같다.

그리고 丙이 이와 같이 압류 후에도 추심권 행사 등을 하지 않는다면, 甲의 乙에 대한 채권에 대하여 질권을 설정하였던 丙이 질권의 피담보채권의 변제기가 도래하여 그 실행을 위하여 채권을 압류한 경우에는 제3채무자로서도 공탁에 의한 방법으로 채무를 면할 수 있으므로,⁷⁹⁾ 제3채무자인 乙은 압류의(형식적) 경합을 이유로 민사집행법 제248조 제1항에 따라 그 채무액 1,000만 원을 모두 권리공탁할 수 있다고 본다.⁸⁰⁾

일반채권자인 丁의 경우 만약 그가 1,000만 원에 대해 전부명령을 받은 경우라

76) 吉野衛·三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋민사집행법(6), きんぎい, 平成 7年(1995), 258.

77) 윤진수(주71), 354.

78) 질권자인 丙은 우선권의 행사에 의해 400만 원을 지급받은 것이므로 민사집행법 제236조 제1항에 따라 집행법원에 대한 추심의 신고는 필요하지 않다.

79) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355.

80) 이러한 집행공탁의 인정은 앞서 본 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결의 취지를 유추 적용한 것이다. 지참채무의 원칙상 丙이 추심권을 행사하지 않는다는 이유만으로 그를 상대로 위 400만 원을 변제공탁할 수는 없다.

면 그 중 질권 설정 부분인 400만 원 부분은 이미 우선권자인 丙에게 채권이 양도되어버린 경우와 같으므로 그 부분에 대해서는 효력이 없다.⁸¹⁾ 82)

2) 그런데 만약 丁이 1,000만 원 전부에 대하여 추심권을 행사하였고, 乙이 이에 대해 1,000만 원을 그에게 지급해버렸다면 乙은 채무를 면할 수 있을까.

생각건대 질권자인 丙이 우선채권자이기는 하나, 이 경우 일반채권자인 丁 또한 추심권을 얻은 채권자 중 1인이므로 제3채무자에게 丙과 丁의 우선관계를 따져서 丙의 추심권행사에 대해서만 응할 의무를 부여한다거나 또는 그로 하여금 그와 같이 행동해줄기를 기대하기란 어렵고, 제3채무자로서도 그들 모두에게 각 지급의무를 부담하므로 그 중 추심권을 먼저 행사한 자에게 채무액을 변제하면 면책된다고 보아야 할 것이다.⁸³⁾

다만 이때 丁은 민사집행법 제236조 제1항에 따라 집행법원에 추심의 신고를 해야 하고 다른 압류인 질권자에 의한 압류가 있으므로 그 제2항에 의해 공탁한 후 사유를 신고함으로써 결국 질권 설정 부분을 제외한 나머지만 배당 받게 될 것이다.⁸⁴⁾

Ⅶ. 체납처분에 의한 압류와 강제집행에 기한 압류의 경합

1. 의의

유효하게 부과된 조세 또는 납세의무가 확정된 조세가 납부기한까지 완납되지

81) 대법원 1981. 9. 22. 선고 80누484 참조 판결【판결요지】[1] 채권압류 및 전부명령 송달 당시에 피전부채권이 이미 제3자에 대한 대항요건을 갖추어 양도되었다가, 위 전부명령 송달 후에 위 채권양도 계약이 해제되어, 동 채권이 원채권자에게 복귀하였다고 하여도 동 채권은 위 압류채권자에게 전부되지 아니한다. [2] 공사금채권에 대한 압류 및 전부명령은 그 송달 후 체결된 추가 공사계약으로 인한 추가 공사금채권에는 미치지 아니한다.

82) 만약, 丙이 丁의 압류 및 전부명령 이전에 400만 원 부분에 대하여 먼저 그 실행을 위한 압류를 하였던 경우라면 丁의 1,000만 원에 대한 압류 및 전부명령 중 400만 원 부분은 민사집행법 제229조 제5항에 따라 전부명령의 효력이 없게 된다. 따라서 어느 경우이든 질권 설정부분에 대한 전부명령은 효력이 없다.

83) 이는 결국 선의·무과실인 채권의 준점유자에 대한 변제(민법 제470조)를 인정하는 것이라고 볼 수 있다.

84) 丁이 1,000만 원의 지급을 구함에 대하여, 乙이 이에 응하지 않으면 丁은 추심금 소송을 제기해야 한다. 이때에 乙은 그 소송에서 질권자의 존재를 이유로 하여 丁에게 추심금의 지급을 거절할 수 없다(대법원 1997. 4. 22. 선고 95다41611 판결). 丁이 추심금 소송에서 승소한 경우의 처리에 관하여는 대부분 다시 이를 민사집행법 제236조 제1항, 제2항에 따라 공탁하고 사유신고함으로써 결국은 질권자가 우선 배당받는다는 것으로 해석하고 있다.

않을 때에는 조세채권자인 국가 또는 지방자치단체는 일정한 절차를 거쳐 납세의무자의 일반재산을 압류하고 강제환가하여 그 환가대금으로부터 체납된 국세 등에 충당하는 절차를 행하게 되는바, 이를 「조세의 체납처분」이라고 하고, 그 절차에 관해서는 국세징수법이 규정하고 있다.⁸⁵⁾

이러한 조세의 체납처분이 일반 사채권(私債權)에 대한 사법절차와는 달리 행정기관에 의해 독립된 절차로서 행해지는 당연한 결과로서, 동일한 집행목적물에 대하여 체납처분에 의한 절차와 일반 민사집행에 의한 절차가 경합하여 행해질 수가 있게 되는데, 현행법상 이러한 국세체납절차와 민사집행절차는 별개의 절차로서 양 절차 상호간의 관계를 조정하는 법률의 규정이 없으므로 한 쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭할 수 없고, 쌍방의 절차에서 각 채권자는 서로 다른 절차에 정한 방법으로 그 다른 절차에 참여할 수밖에 없는 것이 원칙이다.⁸⁶⁾

☞ 독일의 경우, 체납처분의 기본법규인 국세징수법(Abgabenordnung)⁸⁷⁾에서 체납처분을 거의 강제집행의 원칙에 의존하도록 규정하고 있으므로 체납처분과 강제집행 등의 통일적 규정이 이미 완벽하게 실현되어 있다고 볼 수 있다. 독일

85) 의료보험료·산업재해보상보험료·국민연금보험료 기타 징수금 채권 등은 그 순위는 일반채권에 우선하고 조세채권 보다 후순위이지만, 한편 징수절차는 모두 국세체납처분의 예에 의하도록 하고 있어서 일반채권자에 대한 관계에서는 조세채권자와 그 지위가 거의 유사하므로 체납처분에 의한 압류와 일반채권에 기한 압류 사이에 경합하는 경우의 내용에 준하여 생각하면 될 것이다.

86) 민사집행법에 의한 강제집행은 집행권원을 가진 채권자 등의 신청으로 사채권(私債權)의 실현을 목적으로 집행법원이나 집행관이 집행기관이 돼 진행되는 절차인 반면 국세징수법상의 체납처분은 납세자에 대한 조세채권의 실현을 목적으로 세무서장 등이 집행기관이 된다는 점 등에서 차이가 있다. 하지만 양 절차는 모두 국가기관이 개인의 재산을 강제적으로 매각해 금전채권을 실현하는 절차라는 공통점을 가지고 있기 때문에 동일한 재산에 대해 민사집행절차와 체납처분절차가 동시에 진행될 경우 감정료와 신문공고료 등 비용과 시간을 이중으로 낭비하게 되는 등 혼란이 불가피하다. 또 양 절차의 매수신청인 가운데 먼저 절차를 종료하는 자 즉, 낙찰 또는 공매를 받아 대금을 납부하는 사람이 소유권을 취득하게 되므로 낙찰 또는 공매를 받더라도 종국적으로 소유권을 취득할 수 있는지 여부가 여전히 불확실하다는 점은 경매나 공매 등 제도자체에 대한 불신을 초래하고 있다. 실제로 지난 93년 의정부지원에서는 경매절차에서 건물이 최고가매수인에게 낙찰이 됐으나 경매허가결정에 대한 항고·재항고심이 진행되던 중에 체납처분에 의한 공매처분이 이뤄지는 바람에 경매신청인이 감정료 등 경매비용 5,000만원을 모두 날린 사례가 발생하기도 했다. 특히 체납처분절차에서는 일반 채권자가 배당요구를 할 수가 없고, 국세에 우선하는 채권자와 담보권자에 대해서만 배분을 한 뒤 남은 금액은 체납자에게 돌려주므로 일반채권자가 체납자의 배분금 잔액교부청구권을 제때에 압류하기는 거의 불가능하다. 이에 따라 가압류 채권자나 채무명의를 가진 일반채권자는 체납처분절차에서는 전혀 권리를 보호받지 못하는 것은 큰 문제점으로 지적되고 있다. 이 같은 문제점이 지적되자 한국자산관리공사가 강제경매나 담보권실행을 위한 경매가 선행하고 있는 경우에는 공매절차를 중지하는 조치를 함으로써 절차의 이중진행으로 인한 폐해가 많이 줄어들고 있으나 이는 법률의 근거가 없이 임의적으로 이뤄지는 미봉책에 불과하다. 따라서 '의정부사건'이 언제든지 재발할 수 있는 위험을 안고 있다.

87) 1919년에 제국국세징수법(Reichsabgabenordnung)이 제정되어 시행되던 중 1977년 위 법률이 국세징수법(Abgabenordnung)으로 전면 개정되었다.

국세징수법은 국세의 징수가 과세관청이라는 행정기관에 의하여 행하여진다는 것을 명백히 하고 있으면서도 배당절차나 그에 대한 이의절차는 전적으로 민사소송법을 준용하도록 하고 있다는 데 그 특징이 있다.

일본의 경우, 이와 같은 양 절차의 조정을 위해 1957년 「滯納處分과強制執行등과 의節次의調整에관한法律」(이하, 滯調法이라고 한다)을 제정하였으나, 채권집행에 있어서 양자의 조정에 관한 규정은 마련되어 있지 않았기 때문에 양 절차가 경합하는 경우 제각기 절차를 진행하되, 이른바 선착수주의 원칙에 의해 먼저 압류한 절차가 우선한다는 것으로 해석하여 사실상의 조정을 도모하고 있었다. 즉 금전 채권에 대하여 체납처분에 의한 압류와 강제집행이 경합하는 때에만은 양 절차에 어떠한 접촉점도 없고, 체납처분이 선행하는 경우에는 강제집행 측으로부터 체납처분으로의 개입이 인정되지 않으며, 또한 강제집행이 선행하는 경우에도 배당을 전제로 한 집행공탁이 인정되지 않지만, 먼저 강제집행에 의한 압류가 되고 이에 대해 징수직원 등으로부터 교부요구가 있으면 이 교부요구를 민사소송법에 의한 배당요구가 있었던 경우에 준하여 제3채무자가 위와 같은 공탁이 가능한 것으로 되어 있었다. 그 후에 민사집행법이 제정되어 강제집행 등의 규정이 정비됨에 따라 위 滯調法 역시 개정되어 종래 조정의 대상으로 되어 있지 않던 채권에 대한 체납처분에 의한 압류와 강제집행등과의 절차의 조정에 관한 규정이 신설되었던 것인데, 그 내용이 우리에게 선례가 될 수 있으므로 아래 관련된 부분에서 조금씩 언급하기로 한다.

우리의 경우 아직까지 일본의 滯調法과 같은 법률이 존재하지 않으므로 여기에서 논의로 삼고 있는 채권집행에 있어서 체납처분에 의한 압류와 일반채권에 기한 압류가 경합하는 경우의 문제점에 관해서도 전적으로 해석에 일임되어 있는지라, 그에 관한 의견이 분분하기 이를 데 없다.

지금부터 이에 관한 기존의 이론 등을 검토해보고 새로운 민사집행법하에서의 해결책을 도모해보기로 한다.

2. 체납처분에 의한 채권압류

가. 체납압류에 있어서 그 납세채권자인 세무서장은 당해 목적채권에 대하여 체납압류한다는 뜻을 채무자(제3채무자)에게 통지하고(국세징수법 제41조 제1항), 이와

같이 압류된 후에는 그 뜻을 채납자(집행채무자)에게 통지하여야 한다(동법 제41조 제3항). 세무서장이 채무자(제3채무자)에게 통지한 때에 채납압류의 효력이 발생하여(동법 제42조), 세무서장은 이때부터 피압류채권에 대하여 국세·가산금·채납처분비를 한도로 하여 채권자(집행채무자)에게 대위한다(동법 제41조 제2항).

위에서 「대위한다」가 무엇을 의미하는지에 관하여, 우리 판례의 경우⁸⁸⁾ 명시적으로 “..국세징수법에 의한 채권압류는 강제집행에 의한 경우와 같이 그 압류의 결과 피압류채권의 채권자 및 채무자는 그 채권에 관하여 변제·추심 등 일체의 처분행위를 금지하는 효력이 있기는 하나 채납자에 대신하여 추심권을 취득함에 불과하다 할 것으로서..”라고 판시하여 이를 추심권 취득의 일종으로 보고 있다(추심권 취득설).⁸⁹⁾ 따라서 위와 같이 채권을 압류한 세무서장은 채권자(집행채무자)의 승낙 없이 직접 채무자(제3채무자)로부터 추심할 권리를 가진다 할 것이다.

즉 채납압류의 효력은 강제집행절차상 압류·추심명령이 발령된 경우와 유사하다.⁹⁰⁾

나. 채납압류에 있어서 압류조서의 작성은 과세관청 내부에서 채권 압류 사실을 기록·증명하는 것에 불과하여 채권압류의 효력발생요건 아니므로 압류조서가 작성되지 않았다고 하여 채권압류 자체가 무효는 아니다. 그러나 제3채무자에 대한 채권압류통지서의 문언에 비추어 피압류채권이 특정되지 않거나 채납자에 대한 채무이행을 금지하는 문언이 기재되어 있지 않은 경우에는 채권압류의 효력이 없다.⁹¹⁾ 이러한 법리는 지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률의 적용을 받는 지방자치단체의 과징

88) 대법원 1979. 6. 12. 선고 79다662 판결; 대법원 1985. 4. 9. 선고 82다카449 판결

89) 우리의 통설도 대부분 이를 지지하고 있다. 일본의 경우 이를 채권이 법률상 國에 이전하는 것으로 이해하는 견해도 있다(법률상 채권이전설; 平峰隆, “國稅徵收法 第23條ノ1にいう代位の意義”, 民商法雜誌 48卷 5号, 120. 이하)

90) 대법원 2005. 3. 10. 선고 2004다64494 판결 [판결요지]채납처분에 의한 채권의 압류에 관한 국세징수법 제41조, 제43조, 같은 법 시행령 제44조 등의 규정에 의하면, 국세징수법상 채권압류에 의하여 보전되는 국세의 범위는 압류의 원인이 된 채납국세로서 채무자에게 통지된 당해 국세에 한정된다 할 것인데, 이 때 그 채권압류에 기한 추심의 범위에 관하여 국세징수법 제41조 제2항은 피보전국세와 그 가산금 및 채납처분비를 한도로 대위한다고 규정하고 있고, 한편 국세징수법 제21조, 제22조가 규정하는 가산금과 중가산금은 과세권자의 확정절차 없이 국세를 납부 기한까지 납부하지 아니하면 같은 법 제21조, 제22조의 규정에 의하여 당연히 발생하고 그 액수도 확정되는 것으로서 국세 미납분에 대한 지연이자 성격의 지니고 있는 것이므로 위 채권압류 통지서에 기재된 당해 피보전국세의 미납으로 인하여 발생하는 가산금(중가산금의 경우도 동일하다. 국세징수법 제3조 제2항 및 국세기본법 제2조 제5호 참조) 역시 당연히 그 대위에 의한 추심권 행사의 범위에 포함된다.

91) 대법원 2017. 6. 15. 선고 2017다213678 판결

금, 이행강제금 및 부담금 등의 압류절차에도 그대로 적용된다(지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률 제19조 참조).

다. 세무서장이 제3채무자로부터 추심한 금전⁹²⁾은 ① 압류에 관계되는 국세·가산금·채납처분비 ② 채납압류절차에 교부청구해온 세금채권 ③ 피압류채권이 저당권이 채권질권의 목적인 경우에는 그 피담보채권자, 전세보증금인 경우에는 전세권자에게 각 배분한다(동법 제81조 제1항), 그리고 배분 후 잔금이 있으면 이를 채납자(집행채무자)에게 지급한다(동법 제81조 제3항).

이와 같이 채납압류배분절차에는 국세·가산금·채납처분비·지방세·공과금 등 세금에 관한 우선채권자 외에는 채권질권자 및 저당권자, 전세권자 등 우선채권자만이 참가할 수 있을 뿐 일반채권자는 참가가 허용되지 아니하므로 일반채권자에 의한 배당요구 등이 허용되지 아니한다.

라. 국세징수법에 의한 채납압류만이 있는 경우 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 집행공탁을 하는 것이 가능한지 여부가 문제로 될 수 있는데,⁹³⁾ 이에 관하여 판례⁹⁴⁾는, “국세징수법 제41조, 같은 법 시행령 제44조 제1항 제4호, 같은 법 시행규칙 제25조 제1항 및 민사집행법 제227조, 제229조에 의하면, 국세징수법상의 금전채권의 압류와 민사집행법상의 금전채권의 압류는 그 효력을 달리 규정하고 있고, 국세징수법 제56조, 제14조 제1항 및 민사집행법 제235조에 의하면 복수의 압류가 있는 경우의 효력에 관하여도 달리 규정하고 있다. 이와 같은 차이는 강제집행절차가 경합하는 일반채권에 대한 할당 변제에 의한 사법적 해결을 그 본지로 함에 비하여, 채납처분절차는 행정기관에 의한 조세채권의 신속한 만족을 위한 절차라는

92) 제3채무자가 세무서장의 추심에 응하여 지급한 금전 또는 추심에 응하지 않음에 따라 제3채무자를 상대로 국세징수법시행령 제45조 제2항에 의한 추심의 소송을 제기하여 승소함으로써 지급받은 금전을 모두 포함한다.

93) 이 경우 변제공탁이 가능한지 여부가 문제로 될 수 있으나, 이에 관하여는 채납처분에 의한 압류와 일반 압류가 경합하는 경우에 관하여 살펴 볼 때에 보기로 한다. 결론적으로 채납처분에 의한 채권압류의 효력은 피압류채권의 채권자와 채무자에 대하여 그 채권에 관한 변제, 추심 등 일체의 처분행위를 금지하고 추심권자가 채납자에 대신하여 추심할 수 있게 하는 것이므로 제3채무자는 피압류채권에 관하여 채납자에게 변제할 수 없고 추심권자인 국(國)에게만 이행할 수 있을 뿐이다. 따라서 하나의 채납압류가 있는 경우 제3채무자는 채납자를 피공탁자로 한 변제공탁은 할 수 없고, 압류권자와의 관계에서 ‘별도의 변제공탁사유’가 있을 때만 압류권자를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수 있을 것이며, 여기서 ‘별도의 변제공탁사유’란 제3채무자의 항변권, 특히 상계권 행사와 관련하여 채무금액에 다툼이 있는 등의 사유로 압류권자가 수령을 거절하거나 또는 채권양도와의 경합 등의 사유로 채권자 불확지에 해당하는 경우 등을 말한다.

94) 대법원 2007. 4. 12. 선고 2004다20326 판결; 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다60557 판결

점에서 비롯된 것이다. 이와 같은 국세징수법상의 압류와 민사집행법상의 압류의 효력의 차이 및 체납처분절차와 강제집행절차의 차이 등에 비추어 볼 때, 민사집행법 제248조 제1항 및 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제40조 제2항 제4호 소정의 공탁의 전제가 되는 ‘압류’에는 국세징수법에 의한 채권의 압류는 포함되지 않는다고 보아야 한다.”고 하여 이를 부정하는 취지이다.

따라서 국세징수법상의 체납처분에 의한 압류만을 이유로 집행공탁이 이루어진 경우에는 사업시행자가 민사집행법 제248조 제4항에 따라 법원에 공탁사유를 신고하였다고 하더라도 민사집행법 제247조 제1항에 의한 배당요구 종기가 도래한다고 할 수는 없다.⁹⁵⁾

다만 판례는, 위와 같이 요건을 흠결한 집행공탁이 이루어지고 그에 따라 배당절차가 진행된 경우라도 그에 관계된 채권자들이 집행공탁의 하자를 추인하며 그 공탁에 기초하여 진행된 배당절차에 참여하여 배당요구를 함에 따라 채권자들에게 그 순위에 따른 배당이 이루어졌다면 위 집행공탁의 하자가 치유된다는 입장이다.⁹⁶⁾ ⁹⁷⁾

마. 나아가 복수의 체납처분에 의한 압류만이 있는 경우 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 집행공탁을 할 수 있는지 여부가 또한 문제로 될 수 있다.⁹⁸⁾

우리 국세기본법은 압류선착주의를 취하고 있는데, 압류선착주의란 납세자의 재

95) 대법원 2007. 4. 12. 선고 2004다20326 판결

96) 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다60557 판결 【판결요지】공익사업보상법상의 보상금채권에 관하여 위와 같이 요건을 흠결한 집행공탁이 이루어지고 이에 기하여 배당절차가 진행되는 경우, 수용되는 부동산의 근저당권자가 사업시행자의 공탁사유신고 이후 배당금이 지급되기 전에 공탁금출급청구권에 관한 압류 및 추심명령을 받아 위 배당절차에서 배당요구를 하였다면, 이는 적법하게 물상대위권을 행사한 것으로 볼 수 있으며, 공익사업보상법상의 보상금채권에 관하여 이루어진 집행공탁이 요건을 갖추지 못한 경우라 하더라도, 수용부동산의 소유자 또는 공익사업보상법 제2조 제5호 소정의 관계인 등 보상금채권에 관한 채권자가 집행공탁의 하자를 추인하며 그 집행공탁에 기초하여 진행된 배당절차에 참여하여 배당요구를 함에 따라 보상금채권에 관계된 채권자들에게 우선순위에 따라 배당이 이루어졌다면, 집행공탁의 하자는 치유되고 보상금채무 변제의 효력이 발생하고, 위와 같이 요건을 흠결한 집행공탁에 기한 공탁사유 신고 이후 배당금의 지급 전에 물상대위권을 행사한 근저당권자를 제외하는 것으로 배당표가 작성된 경우, 위 근저당권자는 그가 배당받을 수 있었던 금액 상당의 금원을 배당받은 후순위의 채권자를 상대로 배당이의의 소를 제기할 수 있다.

97) 제3채무자가 채무 전액을 공탁하지 않아 집행공탁의 효력이 인정되지 않는 공탁금에 대하여 배당절차가 종료된 경우, 그 공탁금에 대하여 변제의 효력이 인정된다는 것에는 대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다41443 판결 및 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012다91385 판결 등 참조.

98) 이 경우 변제공탁이 가능한지 여부에 관하여는, 앞서 본 단일한 체납압류의 경우와 같이 해석하면 될 것이다.

산에 대하여 압류한 조세채권은 교부청구한 조세채권보다 그 압류재산의 환가대금에서 우선하여 징수하는 원칙을 말한다(국세기본법 제36조 제1항, 지방세기본법 제101조 제1항). 그리고 체납처분에 의한 선행압류가 되어 있는 재산에 체납처분을 하고자 하는 자는 교부청구 또는 참가압류의 방식으로 선행의 체납처분 절차에 참가할 수 있을 뿐이고, 이중으로 압류를 하는 것은 금지된다. 따라서 이미 압류한 채권에 관하여 다시 행한 압류는 교부청구 또는 참가압류의 효력밖에는 인정되지 아니한다(국세징수법 제56조, 제14조 제1항, 제57조).

그런데 복수의 체납처분에 의한 압류가 있고, 압류 총액이 피압류채권을 초과하는 경우, 제3채무자의 입장에서 보면 객관적으로 민사집행법상의 압류경합의 상태가 없더라도 외형상 동일한 채권에 대하여 다수의 압류가 있는 경우로 판단하여 집행공탁을 할 여지가 있고, 이러한 경우 집행공탁에 의한 면책을 인정하지 않는다면 제3채무자는 집행법원이나 강제집행법 전문가에 준하는 지식에 기초한 판단을 요구받는 결과가 되고 그 판단이 틀린 경우 이중변제의 위험까지 부담하게 되므로 부당한 결과가 될 수 있다.⁹⁹⁾

그러나 앞서 본 대법원 2007. 4. 12. 선고 2004다20326 판결의 태도는, 체납처분에 의한 압류는 압류선착주의에 의하여 이미 압류한 채권에 다시 압류한 경우 압류의 효력이 인정되지 않아 압류경합의 문제가 발생할 여지가 없다는 것이고, 공탁선례 200504-1에서 체납처분에 의한 압류의 경우 민사집행법상의 집행공탁을 할 수 없다고 하고 있는 점에 비추어 볼 때, 복수의 체납처분에 의한 압류가 있는 경우가 민사집행법 제248조 제1항 소정의 집행공탁 사유에 해당되는 것으로 해석하기는 어려운 실정이다.

바. 결국 민사집행법과 달리 국세징수법에는 체납처분에 의하여 채권을 압류한 경우 제3채무자가 공탁할 수 있는 규정이 없으므로 공탁에 의하여 채무를 면하는 것은 인정되지 않는다. 다만 여러 개의 체납처분에 의한 압류가 있는 경우 제3채무자로서는 누구에게 채무를 변제해야 면책되는지 몰라 고심하게 되므로 체납처분에 의한 압류의 경우에도 제3채무자가 공탁함으로써 채무를 면하는 것을 인정할 필요가 있으나, 이는 입법적으로 해결되어야 할 것이다.

99) 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결; 1999. 11. 26. 선고 99다35256 판결; 2000. 6. 23. 선고 98다31899 판결 등 참조.

3. 체납처분에 의한 압류 후에 일반채권에 기한 압류가 있는 경우

가. 체납압류 후에 일반채권에 기한 압류의 가능 여부(집행의 경합 가능 여부)

1) 예컨대, 조세채권자인 丙이 국세징수법 제41조 제1항에 기하여 체납자인 甲의 제3채무자인 乙에 대한 1,000만 원의 임차보증금반환채권을 체납처분에 의하여 모두 압류한 이후에 다른 일반채권자인 丁이 동일한 채권을 1,000만 원의 일반채권으로 다시 전부 압류하는 것이 가능할 것인가. 즉 이는 체납압류된 재산에 대하여도 강제집행절차를 진행시킬 수 있다고 볼 것인지 여부에 관한 문제인 것이다.

이에 대해서는 우선, ① 이를 인정할 경우 혼란을 일으키고 당사자에게 예측할 수 없는 손해를 입힐 우려가 있으며, 병존하는 양 절차 중 효력을 상실하는 측의 절차에 따른 비용 등이 낭비에 불과한 점, ② 국세징수법 제81조 제1항 등에 따르면 체납압류배분절차에 대해서는 당해 체납압류된 채권에 대한 우선채권자 등의 참가만을 예정하고 있을 뿐 일반채권자의 참가는 예정되어 있지 아니하므로 체납압류 이후에 일반채권에 기한 이중압류는 허용되지 않는다고 보아야 한다는 점 등을 들어 이를 인정할 수 없다는 소극설의 입장¹⁰⁰⁾이 제기되고 있다.

그러나 ① 체납압류 후에 강제집행이 불가능하다고 하면 체납압류의 처분금지의 효력은 상대적 효력만 있으므로 체납자는 압류된 재산을 제3자에게 유효하게 양도할 수 있고, 그 후에 어떤 사정으로 체납압류가 해제되어 버리면 이미 압류목적물은 제3자의 소유에 속하게 되어 강제집행이 불가능하게 되는 부당한 결과가 생길 수 있는 점, ② 또한 일반채권자는 조세채권의 액수가 아무리 적고 압류목적물의 가액이 아무리 높아도 체납처분절차가 종료될 때까지는 수수방관하고 체납압류의 해제를 기다릴 수밖에 없어 불합리한 점(이는 체납자가 다른 일반채권자의 강제집행을 면할 목적으로 소액의 세금을 체납하여 고액 재산의 압류를 자초한 다음 체납압류를 유인함으로써 강제집행의 면탈에 이용될 가능성도 배제할 수 없다), ③ 국세기본법 제35조 제1항(지방세기본법 제99조 제1항도 동일)은 “국세, 가산금 또는 체납처분비는 다른 공과금 기타의 채권에 우선하여 징수한다.”라고 규정하여 국세우선의 원칙을 표방하고 있지만, 이러한 국세우선의 원칙은 강제집행 등의 배당절차에서 조세채권이 일반채권보다 우선하여 배당받을 수 있으면 충분하지 더 나아가 체납자의 재산에 대한 일반채권자의 강제집행까지 허용하지 않는다는 의미는 아니라고 보아야 하는 점 등에 비추어 위 소극설은 따르기 어렵

100) 김훈, “체납처분과 강제집행 등의 경합”, 사법논집 7집, 486.; 남기정, “강제집행등 경합과 공탁관계”, 법조 40권 12호, 118. 등

고, 채납압류 후에도 강제집행절차를 진행시킬 수 있다는 적극설¹⁰¹⁾이 타당하다고 본다.

우리 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결 역시 “현행법상 채납처분절차와 민사집행절차는 별개의 절차이고 두 절차 상호 간의 관계를 조정하는 법률의 규정이 없으므로, 한쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭할 수 없는 반면, 쌍방 절차에서 각 채권자는 서로 다른 절차에 정한 방법으로 다른 절차에 참여하게 된다. 따라서 채납처분에 따라 압류된 채권에 대하여도 민사집행법에 따라 압류 및 추심명령을 할 수 있다.”라고 판시하여 위 적극설과 같은 입장을 취하고 있다.¹⁰²⁾

따라서 위 예의 경우 조세채권자인 丙의 채납압류가 선행하고 있었다 하더라도 일반채권자인 丁 역시 동일한 채권에 대한 압류집행이 가능하다 할 것이다.

2) 그런데 여기에서 한 가지 더 의문이 드는 것은, 앞의 예에서 일반채권자인 丁이 위와 같은 압류에서 더 나아가 현금화절차인 추심명령까지 얻는 것이 가능한지 여부에 관한 것인바, 이에 대해서도 채납처분에 의한 압류가 선행된 채권에 대하여 강제집행절차에 따라 일반채권에 기한 압류가 가능하다고 하더라도 선행하는 채납처분에 의한 압류와 중복되는 부분에 대해서는 일반채권에 비해 우선하는 선채납압류라고 하는 「집행장애」가 있는 경우와 같다고 볼 수 있고 이러한 경우 위 집행장애 때문에 채납처분에 의한 압류 부분이 해제되지 않는 한 그에 대하여 추심명령을 얻어서 추심할 수도 없다고 하여 이를 소극적으로 보는 견해¹⁰³⁾가 나타나고 있으나, 다음에서 다시 보겠지만 채납처분에 의한 압류절차와 민사집행절차는 서로 다른 별개의 절차이고, 또 위와 같은 추심명령은 현금화절차에 불과하므로 채납처분에 의한 압류권자가 현실적으로 추심하지 않은 이상 일반채권자도 추심명령까지 가능하다고 보아야 할 것이다. 우리 판례 또한 이를 인정하고 있다.¹⁰⁴⁾

☞ 일본의 滯調法에 따르면, 채권에 관하여 채납처분에 의한 압류가 된 경우에도

101) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 425.; 임용모, “채납처분에 의한 압류와 공탁관계”, 사법논집 제33집, 752. 이하; 강인애, 국제징수법해설, 청림출판(1994), 241.; 조재연, “강제집행과 채납처분의 경합”, 재판자료 제36집, 115. 등

102) 부동산경매절차의 경우 동일한 취지의 대법원 1961. 2. 9. 선고 4293민상124 판결이 있다.

103) 남기정(주99), 118.; 남기정, 위 실무공탁요론, 153.

104) 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결(이 경우 추심명령을 발령받은 채권자는 제3채무자를 상대로 추심의 소를 제기하는 것도 가능하다. 제3채무자는 압류 및 추심명령에 선행하는 채납처분에 의한 압류가 있어 서로 경합된다는 사정만을 내세워 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 추심청구를 거절할 수 없고, 또한 민사집행절차에 따른 압류가 근로기준법에 따라 우선변제권을 가지는 임금 등 채권에 기한 것이라는 등의 사정을 내세워 채납처분에 의한 압류채권자의 추심청구를 거절할 수도 없다고 판시)

강제집행에 의한 압류가 가능하다(滯調法 제20조의3 제1항). 압류가 경합한 때에는 강제집행에 의한 압류의 효력은 그 채권 전부에 미치는 것으로 되지만(滯調法 제20조의4), 이 경우 조세채권에는 우선권이 있고, 나아가 징수직원 등은 사채권(私債權)을 포함하여 배당절차를 행할 권한이 법률상 인정되어 있지 않기 때문에 일본 민사집행법 제156조¹⁰⁵⁾와는 다르게 처리된다.

즉 조세채권에 우선권이 있는 것으로 하면 징수직원 등에게 추심을 인정해도 강제집행의 채권자에게 불이익하지 않으므로 징수직원 등은 압류에 관계된 채권 전액을 징수하는 것이 가능하다(國稅徵收法 제67조).

따라서 제3채무자가 위 징수에 응한 때에는 징수직원등은 국세징수법의 규정(제128조 내지 제134조)에 따라서 배당을 하면 되고, 잔여금이 생기면 비로소 민사집행절차와의 조정이 필요하게 된다. 즉 잔여금은 국세징수법의 규정에 의하면 채납자에게 교부해야 하지만(國稅徵收法 제128조 제3항), 그 채권에 대해 강제집행에 의한 압류명령이 발하여져 있는 경우에는 징수직원 등은 이를 집행재판소에 교부해야 하고(滯調法 제20조의8 제1항, 제6조 제1항, 제3항), 그러면 집행재판소가 이에 대한 배당을 실시하게 된다(滯調法 제20조의7 제1항).

그리고 집행재판소가 징수직원 등으로부터 잔여금의 교부를 받은 때에 민사집행법상 배당요구의 종기에 이른다(배당가입의 차단효 발생, 滯調法 제20조의7 제3항). 이런 이유로 채납처분에 의한 압류가 선행하는 경우에 있어서는 제3채무자에게 공탁의무를 과할 필요가 없기 때문에 강제집행에 의한 압류가 경합하는 것과 같은 공탁의무가 부과되어 있지 않다.

그러나 제3채무자로서는 징수직원 등에 의한 징수를 기다리지 않고 조기에 채무를 변제하여 면책을 얻을 이익을 가지고 있는 경우도 있기 때문에 滯調法은 제3채무자에 대하여 공탁하는 것에 의해 면책을 얻을 수 있는 권리를 인정하였다. 즉 금전채권에 관하여 채납처분에 의한 압류가 된 경우에 있어서 강제집행에 의한 압류가 되어 압류가 경합하는 경우에는 제3채무자는 그 채권 전액에 상당하는 금전을 채무이행지 공탁소에 공탁할 수 있다(滯調法 제20조6 제1항). 이때에 징수직원 등은 앞서 말한 채납처분에 의한 압류를 한 부분에 관하여 징수를 할 수 있고, 또한 강제집행에 의한 압류채권자도 채납처분에 의한 압류 부분을 제외한 나머지에 대하여 추심하는 것이 가능하다(滯調法 제20조의3).

105) 제3채무자의 공탁에 관한 규정이다.

제3채무자는 이 공탁을 한 경우에는 징수직원 등에 대하여 서면으로 공탁서정본을 첨부하여 사유신고를 할 필요가 있다(滯調法 제20조의6 제2항). 이 사유신고를 받은 징수직원 등은 그 뜻을 집행재판소에 서면으로 통지해야 한다(滯調法 제20조의6 제3항).

그리고 채권의 일부에 관하여 채납처분에 의한 압류가 된 경우에 있어서, 다시 강제집행에 의한 압류와 강제집행에 의한 압류 또는 가압류의 집행이 경합한 때, 또는 강제집행에 의한 압류와 배당요구가 경합한 때에는 제3채무자는 채납처분에 의한 압류의 잔여액에 상당하는 금전을 채무이행지 공탁소에 공탁해야 한다(민사집행법 제156조 제2항).

또 滯調法 제20조의6 제1항의 규정 또는 이 규정 및 민사집행법 제156조 제2항의 쌍방 규정을 근거로 하여 채권 전액에 상당하는 금전을 공탁하는 것도 가능하다. 滯調法 제20조의6 제1항이 적용됨과 동시에 일부에 관해서는 민사집행법 제156조 제2항도 함께 적용되는 사안이기 때문이다.¹⁰⁶⁾

나. 압류의 경합 여부

1) 위의 예와 같이 조세채권자인 丙이 피압류채권 전액을 채납압류한 이후에 일반채권자인 丁이 다시 그 전액을 압류한 경우 또는 이와 다르게 丙이 피압류채권의 일부인 400만 원을 압류한 이후에 일반채권자인 丁이 피압류채권 전액을 압류한 경우, 만일 丙이 丁과 같은 일반채권자였다면 이는 동일한 채권에 대하여 압류의 경합이 발생하는 경우일 것이지만, 위와 같이 丙이 조세채권자여서 채납압류한 때에도 위 피압류채권에 대한 압류의 경합을 인정할 수 있을까.

압류의 경합이란 개념과 그 효과 등에 대하여는 앞서¹⁰⁷⁾ 개략적으로 살펴보았는바, 여기에서 보고자 하는 것은 위와 같이 선행 압류권자가 채납처분에 의한 압류권자인 경우에도 일반 채권에 기한 압류와 사이에서 이러한 압류의 경합이 발생한다고 할 수 있는지 여부에 관한 문제인 것이다(위의 예에서도 조세채권자인 丙의 채납압류와 일반채권자인 丁의 압류는 집행이 경합하고 있고, 또한 그 압류의 합계액이 피압류채권을 넘어서고 있다는 압류의 경합에 관한 형식적 요건은 충족하고 있으므로 그것을 일반채권자 사이에서 발생하는 압류의 경합과 동일하게 볼 수 있는지가 문제되고 있

106) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 516-518.

107) 제2절 Ⅶ. 3. 가. 이하 참조

다).

2) 이에 관하여는 위와 같은 경우를 압류의 경합으로 취급하는 견해가 있고, 이에 따르면 제3채무자는 우선권이 있는 채납처분에 의한 압류권자에게 채무액을 지급하든가 또는 구 민소법 제581조 제1항에 따라 압류 경합을 이유로 집행공탁을 할 수 있다고 한다(이하, 이 설을 편의상 적극설이라고 한다).¹⁰⁸⁾

3) 그러나 이와 같은 적극설은 다음과 같은 점에서 이를 그대로 받아들이기 어렵다.

우선 앞서 보았듯이, ① 민사집행법 제235조 등 채권압류의 경합에 관한 조문들은 경합하는 각 집행채권자가 평등한 관계에 있음을 전제로 하여 그들 사이의 이해관계를 조절하기 위하여 규정된 것이므로 외관상은 채권압류가 경합된 것처럼 보이더라도 실제법상 어떤 채권자의 채권이 다른 채권자에게 우선하는 관계에 있을 때에는 위 각 조문들은 그 적용이 배제된다고 봄이 타당하다. 그리고 ② 현행법상 국세채납절차와 민사집행절차는 별개의 절차로서 양 절차 상호간의 관계를 조정하는 법률의 규정이 없으므로 한 쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭할 수 없고, 쌍방의 절차에서 각 채권자는 서로 다른 절차에 정한 방법으로 그 다른 절차에 참여할 수밖에 없는 것이 원칙이므로 동일 채권에 관하여 양 절차에서 각각 별도로 압류하여 서로 경합하는 경우에도 공탁 후의 배분(배당)절차를 어느 쪽이 행하는가에 관한 법률의 정함이 없어 제3채무자의 공탁을 인정할 여지가 없다(대법원 1999. 5. 14. 선고 99다3686 판결). 여기에서 말하는 공탁이란 재판상 배당을 전제로 하는 것, 다시 말해 구 민소법 제581조 제1항이 압류 경합 등의 경우에 있어서 인정하고 있던 집행공탁을 말하는 것이고, 따라서 이는 채납처분에 의한 압류 후에 일반채권에 기한 압류가 있는 경우에는 이러한 집행공탁을 인정할 여지가 없다는 것을 뜻하며, 이것은 또한 거꾸로 말하면, 이 경우는 그러한 집행공탁이 인정되는 압류의 경합이 아니라는 것을 의미한다. 또한 ③ 국세징수법은 강제집행에 의한 압류가 선행하는 경우에 세무서장으로 하여금 교부청구 또는 참가압류를 인정함으로써 그에 대한 참가를 허용하는(국세징수법 제56조, 제57조) 반면, 채납처분에 의한 압류가 선행하는 경우에 있어서는 강제집행에 의한 압류가 끼어들어 경합 등이 생길 여지를 두고 있지 아니하다(이는 채납처분에 의한 압류집행 이후에 다시 일반채권에 기한 압류집행이 경합하는 것은 가능하지만, 이러한 집행을 경합이 가능하다는 것과 그 이후에 그 양자 사이에 채권자평등주의의 실현을 위해 고안된 압류의 경합이 발생하는지의 문제는 다르다는 것을 말한

108) 신동기(주70), 445.

다).¹⁰⁹⁾

4) 그러므로 이에 따르면 체납처분에 의한 압류와 일반채권에 기한 압류는 우선 채권과 일반채권의 성격상 압류의 경합이 인정되지 않을 뿐만 아니라, 양자는 서로 섞일 수 없는 「물과 기름」의 관계와도 같은 것이어서 그것이 피압류채권액의 일부 또는 전부범위에서 중복되어 있다 하더라도 그것은 민사집행절차 내에서 일반채권자들 사이에서 발생하는 압류의 경합과는 다르고, 이는 다만 그 중복 범위 내에서 서로 전혀 다른 절차에 따른 압류가 「형식적으로」 경합되어 있는 것에 불과하다.

그리고 이와 같이 압류가 「형식적으로」 경합되어 있음에 불과하다는 것은 체납처분에 의한 압류와 일반채권에 기한 압류가 외관상 일부 또는 전부에서 경합하는 것처럼 보이더라도 이에 대해서는 압류의 경합으로 인해 발생하는 일반적 효과, 즉 앞서¹¹⁰⁾ 본 압류효의 확장, 제3채무자의 공탁의무, 배당요구의 효력 등이 인정되지 않는다는 것을 의미한다.

5) 결론적으로, 체납처분에 의한 압류 후에 일반채권에 기한 압류가 있음으로 인해 피압류채권의 일부 또는 전부에 대해 양 절차에 따른 압류가 중복되어 있다 하더라도 이는 민사집행법 제235조가 규정하는 압류의 경합은 아닌 것이며,¹¹¹⁾ 따라서 이러한 경우를 압류의 경합으로 보아 구 민소법 제581조 제1항에 따른 집행공탁이 가능하다고 보고 있는 위 적극설은 적절하지 않다 할 것이다.

109) 다음에 보게 되겠지만, 대법원 행정예규 제542호 「공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침」을 보더라도, 위 사례와 같이 체납처분에 의한 압류가 선행하고 강제집행에 의한 압류가 후행하는 경우는 사유신고의 대상에 해당하지 않는다고 명시하고 있다. 공탁공무원이 사유신고할 수 있으려면, ㉠ 압류의 경합이 발생하였을 것 ㉡ 지급요건이 충족되었을 것 등의 요건을 갖추어야 하는 것인데, 이와 같은 경우는 아예 압류가 경합된 경우가 아니기 때문에 이를 사유신고의 대상에서 제외하고 있는 것이다(이 예규는 비록 공탁금지급청구권에 대하여 압류의 경합 등이 있는 경우 「공탁공무원에게」 사유신고를 해야 할 때와 하지 않아야 할 때를 규정하는 것이지만, 압류 경합이 되는 것과 되지 않는다는 것의 의미가 일반채권자들에게 있어서 다르고 공탁공무원에게 있어서 또 다르게 해석되는 그런 문제는 아닌 것이다).

110) 제2절 Ⅶ. 3. 가. 이하 참조

111) 同旨; 윤진수(주71) 351.(이 경우를 압류가 경합된 경우로 볼 수 없다는 견해이다); 남기정(주99), 118. 및 남기정, 앞의 실무공탁요론, 91.(이 견해는 체납압류가 선행하면 강제집행에 기한 압류 및 추심명령은 불가(不可)하고, 강제집행에 기한 압류가 후행되더라도 경합이 인정되지 않는다는 것으로서, 여기에서 집행의 경합이 아니라는 의미는 체납압류 후에 강제집행에 의한 압류를 할 수 없다는 것을 말하고, 지금 살펴보는 압류 경합의 일반적 효과가 발생하지 않는다는 의미에서의 압류 경합이 아니라는 것은 아니어서, 그 내용이 위 소극설의 내용과 약간 다르기는 하지만 어쨌든 압류의 경합을 인정할 수 없다는 것이므로 이 범주에 넣기로 한다) 등

다. 압류효의 확장 여부

1) 여기에서는 앞의 예 중에서 조세채권자 丙이 400만 원만 체납압류한 경우를 생각해보자.

이 경우 체납처분에 의한 압류가 있는 부분(400만 원)에 대해서는 다른 절차인 민사집행에 따른 기한 압류가 중복되어 있는바, 그 중복으로 인한 압류 효력의 확장을 인정할 수 있을지가 논의되고 있으므로 이에 관해 살펴보고 가기로 한다.

가) 우선 이에 대하여는 이미 본 바 있는 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다 12233 판결이 그 답을 제시하고 있다. 즉 국세징수법 제43조는 체납처분에 의한 채권압류의 범위에 관하여 체납액을 한도로 하여야 하고 다만 압류할 채권이 체납액을 초과하는 경우에 필요하다고 인정하는 때에는 그 채권 전액을 압류할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 압류의 효력의 확장에 관하여 별다른 규정을 두고 있지 않는바, 이는 체납처분에 의한 압류와 후행하는 일반채권자에 의한 압류가 채권의 일부가 압류된 후에 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류명령이 발하여진 때에는 각 압류의 효력은 그 채권의 전부에 미친다고 하는(구 민소법 제568조의2 제1항) 일반채권에 기한 강제집행에 있어서의 압류경합의 경우와 다르다는 것을 의미하고, 또한 체납처분에 의한 압류에 관하여서는 피압류채권의 일부를 특정하여 압류한 경우 그 특정한 채권 부분에 한하여 압류의 효력이 미치는 것이며 그 후 강제집행에 의한 압류가 있고 그 압류된 금액의 합계가 피압류채권의 총액을 초과한다고 하더라도 그 압류의 효력이 피압류채권 전액으로 확장되지 아니한다고 할 것이므로 나머지 부분(위 사례에서 丙의 채권 400만 원을 넘는 600만 원 부분)에 대하여 압류경합이 되는 것은 아니라는 것이다.

나) 그러나 위 판례가 압류효가 확장되지 않는 근거에 관하여 ① 국세징수법에 압류효 확장에 관한 규정이 없다는 것과 ② 채권압류의 범위에 관한 국세징수법 제43조를 들고 있는 것 등에 대하여는, 압류효 확장 규정이 없는 것이 바로 국세징수법상의 압류의 효력이 그러한 규정이 있는 민사소송법과 달리 확장하지 않는다고 반대해석하는 근거로서 빈약하고, 위 확장효에 관한 규정도 구 민사소송규칙과 개정 민사소송법이 이를 규정하기 전에는 아무 규정도 없었던 것이지만 확설·판례에 의하여 압류효의 확장효를 인정하고 있었던 점에 비추어도 그 논거가 미흡할 뿐만 아니라, 국세징수법 제43조는 “세무서장은 채권을 압류한 때에는 체납액을 한도로 하여야 한다. 다만 압류할 채권이 체납액을 초과하는 경우에 필요하다고 인정하면 그 채권 전

액을 압류할 수 있다.”라고 규정하고 있는데, 이는 그 규정취지로 보아 납세자를 보호하기 위하여 압류할 채권의 범위를 한정된 초과압류금지에 관한 규정으로 볼 것이지 채권압류의 효력이 미치는 범위를 직접적으로 규정한 것은 아니라고 할 것인바,¹¹²⁾ 이를 두고 압류효 불확장의 근거로 하는 것은 무리이며, 오히려 그 근거는 국세 등은 일반채권에 비하여 우선권이 있으므로 일반채권과 경합되어 있더라도 평등배당의 문제가 생기지 아니하므로 그 압류의 효력을 확장할 필요가 없다는 그 채권의 성격에 기인하는 것으로 보아야 할 것이라고 주장하면서 위 판례의 논지를 비판하는 견해가 있고,¹¹³⁾ 이러한 비판은 일응 적절한 면이 있는 것으로 보인다.

그러나 또한 이에서 더 나아가 보면 위의 경우에 압류효의 확장이 발생하지 않는 근거는 압류의 경합에 관한 앞서 본 소극설의 논지처럼 체납처분에 의한 압류 후에 일반채권에 의한 압류가 있는 경우에는 동일한 민사집행절차에서 발생하는 압류의 경합으로 볼 수 없기 때문에 위와 같은 경우 그 경합을 전제로 하는 압류효 확장의 문제는 당초부터 발생하지도 않는다고 설명하는 것이 간단명료할 것이다.

다) 어쨌든, 조세채권은 일반채권과 일부 형식적으로 경합(중복)하고 있다 하더라도 그 압류의 효력이 피압류채권 전액(위의 예에서 400만 원을 넘어서는 나머지 600만 원 부분까지)으로 확장되지 아니한다.

2) 그런데 여기에서 다른 예, 즉 조세채권자인 丙이 400만 원의 채권으로써 甲의 乙에 대한 채권을 체납압류한 후 다시 일반채권자인 丁이 800만 원의 채권을 가지고 압류 및 추심명령을 받은 경우를 가정해보자.

이 경우는 앞의 사례와 약간 다른 것이 일반채권자인 丁이 피압류채권 전액을 압류하지 않고 丙과 마찬가지로 그 일부만 압류하고 있는 것인데, 이 때 역시 丙의 압류는 자신의 채권의 나머지 부분(600만 원 부분)으로 그 효력이 확장되지 않게 되지만, 丁의 압류에 대하여 편면적 압류효의 확장을 인정할 수 있을까.

☞ 참고로, 앞서 본 滯調法을 두고 있는 일본의 경우 압류가 일부 경합된 경우에 체납처분에 의한 압류의 효력의 확장 여부에 대하여는 규정이 없으나, 위 滯調法 제20조의4와 제36조의4가 이러한 경합의 경우 강제집행에 의한 압류의 효력이 목적채권 전부로 확장됨을 규정하고 있다.

이와 같이 양 절차에 의한 일부 압류의 경우에 강제집행에 의한 압류의 효력만을

112) 김대영, 국세징수실무, 조세통람사(1991. 6. 15.), 130.

113) 신동기(주70), 467-468.

편면적으로 확장시킨 이유에 대하여, 학설은 대부분 조세채권은 실체법상 일반 사채권(私債權)에 우선하는 관계에 있고, 체납처분이 선행하는 경우에는 절차적으로도 징수직원 등은 후행의 강제집행에 불구하고 당해 압류채권의 추심을 할 수가 있고, 또, 체납처분에 의한 압류가 후행하는 경우에도 조세채권은 집행재판소가 행하는 배당절차에서 우선적 만족을 받을 수 있으므로 그 압류효를 확장할 필요는 없다.

그러나 강제집행에 의한 압류에 있어서는, 첫째로, 체납처분에 의한 압류가 선행할 때는 일반채권자는 징수직원이 추심한 금전의 잔여분을 교부받을 수 있음에 그치는데(滯調法 제20조의8 제1항, 제6조 제1항), 그 잔여금을 받을 수 있다고 하는 설명의 편의상에서, 둘째로, 강제집행에 의한 압류가 선행할 때는 체납처분에 의한 압류는 교부요구로 간주되고(滯調法 제36조의10 제1항), 압류에 관계된 조세채권은 집행재판소가 행하는 배당절차에서 받게 되어 그 만족을 받는 것으로 되므로 그 채권만족의 절차상 필요에서, 각각 강제집행에 의한 압류의 효력을 채권 전부에 확대하고 있다고 설명하고 있다.¹¹⁴⁾

이에 관하여도 질권실행을 위한 압류와 일반압류가 경합하는 경우에 있어서와 같이 적극설과 소극설의 입장이 나타나고 있다.

즉 소극설은, 이 경우 국세채권 등에 교부청구권이 인정되는 외에는 양 절차의 조정에 관한 법률이 없어 앞서 본 바와 같이 일반채권자가 체납처분절차에 참여하는 것이 배제되어 있는 등 양 절차는 상호 독자적으로 진행될 수밖에 없어서 양 절차에 기한 압류가 일부 형식적으로 경합한다고 하더라도 이는 다른 절차에 기한 압류가 병렬적으로 중복하여 존재할 뿐이라고 보아야 되는 우리 법과, 추심명령제도를 폐지하고 체납처분과 강제집행과의 절차를 통일적으로 정비한 외에 선착수주의를 취하여 먼저 착수한 집행절차에 후행절차가 편승하도록 하고 있는 일본법과는 그 구조가 다르기 때문에 우리 법하에서는 해석상으로 이를 인정하기 곤란하다고 본다.¹¹⁵⁾ 이에 따르면 위 사안에서 丙의 압류가 400만 원 범위 내에서 그 효력이 확장되지 않는 한편, 일반채권자인 丁의 압류 또한 800만 원 범위에서 더 이상 피압류채권 전액으로 그 효력이 확장되지 않고 머물러 있게 될 것이다.

114) 宇佐見隆男, 改正滯調法による滯納處分と強制執行等との手續の調整について, 登記研究 第399号 (1981. 3.), 1. 이하[신동기(주70), 464-465.에서 재인용]

115) 同旨; 신동기(주70), 465.

그러나 이 경우도 질권실행을 위한 압류에서와 동일하게 체납압류에 의한 추심 후의 잔여액에 대하여 다른 일반채권자의 권리실행을 도모할 필요상 혹은 체납압류의 실행 내지 행사 후 배당등 절차를 행할 필요상, 일반채권에 기한 압류의 효력이 편면적으로 확장된다고 보는 견해(적극설)가 또한 등장하고 있다.

생각건대, 이론적으로만 본다면 소극설이 타당하다고 할 수 있으나, 실재상 다른 일반채권자의 권리실행 및 배당절차의 원활한 진행을 위하여 이를 적극적으로 해석하는 것도 가능하다고 본다.¹¹⁶⁾ 향후 검토가 필요한 부분이라 하겠다.

라. 추심 및 공탁의 문제

1) 집행공탁의 인정 여부

가) 앞의 예 중에서 조세채권자인 丙이 피압류채권 전액을 체납압류 하였는데, 만일 후행하는 일반채권자인 丁이 다시 1,000만 원에 대해 전부명령을 얻은 경우라면, 민사집행법 제229조 제5항¹¹⁷⁾의 「다른 채권자의 압류」에는 체납처분에 의한 압류도 포함된다고 보아야 할 것이므로 丁의 전부명령은 무효라 할 것이다.¹¹⁸⁾

116) 예를 들어, 채무자 A의 제3채무자 B에 대한 1,000만 원의 피압류채권을 조세채권자 甲이 400만 원의 채권을 가지고 체납압류하고 다른 일반채권자 乙이 700만 원의 채권을 가지고 압류하였으며, 또다른 채권자 丙이 200만 원의 채권을 가지고 위 피압류채권을 다시 압류한 경우의 사안을 한번 생각해보자. 이 경우 소극설에 의하면 乙의 700만 원 압류부분은 피압류채권 전채로 확장되지 않는다(丙의 압류의 효력이 확장되지 않은 것은 물론이다). 이때 만일 체납압류권자 甲이 400만 원을 추심하였다면, 피압류채권은 600만 원뿐이 남지 않게 된다. 다른 채권자 乙과 丙의 채권의 합계가 이보다 더 많은 900만 원인데도 소극설에 의할 경우 乙과 丙의 압류 어느 것도 피압류채권 전채로 확장될 수 없기 때문에 위 남은 600만 원을 乙과 丙에게 어떻게 배당해야 하는지 여부를 해결하기 어려워진다. 이 경우 적극설에 의할 경우 甲의 체납압류와 乙의 일반압류가 경합할 때 甲의 체납압류는 그 효력이 확장되지 않는 반면, 乙의 일반압류는 그 효력이 1,000만 원 전채로 확장하게 된다(甲의 체납압류 금액 400만 원과 乙의 일반압류 금액 700만 원이 피압류채권 1,000만 원을 초과하고 있으므로). 그렇게 되면 乙의 일반압류 후에 참가한 또다른 채권자 丙은 이미 乙이 모두 압류하고 있는 피압류채권을 다시 압류하는 것이 되므로 이 또한 민사집행법 제235조 제2항에 따라 그 압류의 효력이 전채로 확장되어 미치게 되는 것이다. 이렇게 되면 이후 체납압류권자 甲이 추심 등에 의하여 400만 원에 대하여 권리행사한 후라도 乙과 丙은 나머지 600만 원에 대하여 자신의 청구채권액 범위 내에서 안분배당을 받아갈 수 있게 되는 것이다. 이러한 일반채권자들의 권리행사와 배당절차 등을 위하여 적극설이 적극 검토되어야 할 필요가 있다는 것이다.

117) 위 조항은 “전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 그 금전채권에 관하여 다른 채권자가 압류·가압류 또는 배당요구를 한 경우에는 전부명령은 효력을 가지지 아니한다.”라고 규정하고 있다.

118) 同旨 : 서울민사지방법원 1984. 3. 22. 선고 83가합6019 판결. 전부명령이 무효로 된 이후 제3채무자의 공탁 문제는 이하에서 살펴보게 될 압류 및 추심명령이 발령되었는데, 채권자가 추심권을 행사하지 않는 경우와 동일하다고 볼 수 있다.

다만 위 丙이 피압류채권 중 일부, 예컨대 400만 원만 체납압류한 상태라면 丁의 전부명령은 그 400만 원 부분에서만 무효이고, 나머지 600만 원 부분은 여전히 유효하다.¹¹⁹⁾

나) 이제 처음 예의 경우와 같이 조세채권자인 丙이 甲의 乙에 대한 1,000만 원 채권 모두를 체납처분에 의해 압류하였고, 그 후에 일반채권자인 丁이 다시 1,000만 원 모두에 관해 압류 및 추심명령을 받은 경우를 상정해보자.

이 경우 그 추심권 행사에 관하여, 체납압류권자가 일반채권에 기한 압류권자보다 우선하여 추심할 수 있다는 견해¹²⁰⁾도 있으나, 이미 본 바와 같이 체납처분에 의한 절차와 민사집행절차는 조정과 간섭 내지 참여가 쉽지 않은 서로 다른 별개의 다른 절차이고, 또한 추심권 행사에 있어서 전자에 있어서의 압류가 후자보다 우선한다는 취지의 명문 규정도 없으므로 丙과 丁은 누구든 먼저 추심권을 행사할 수 있고, 제3채무자로서도 그들 모두 각각 지급의무를 부담하므로 그 중 추심권을 행사하는 자에 대하여 채무액을 지급하면 면책된다고 보아야 하며, 그로 인해 어느 일방의 압류채권자가 변제받으면 타방의 절차도 종료된다고 보아야 할 것이다.¹²¹⁾

그리하여 위의 예에서 제3채무자인 乙은 조세채권자인 丙이든 일반채권자인 丁이든 먼저 추심권을 행사하는 자에 대하여 피압류채권을 지급하면 그로써 면책될 수 있다. 다만 乙이 일반채권자인 丁의 추심권 행사에 응하여 1,000만 원을 지급하였다면 丁으로서는 민사집행법 제236조 제1항, 제2항¹²²⁾에 따라 추심신고 및 공탁과 사

119) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 425.; 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결【판결요지】[1] 일반적으로 금전채권의 압류에 관하여 특히 피압류채권의 수액에 특별한 제한을 둔 바 없다면 압류의 효력은 채권 전액에 미치는 것이며, 압류가 경합된 채권에 대한 전부명령은 그 효력이 없다. [2] 체납처분에 의한 채권압류에 관한 국세징수법 제43조의 규정취지에 비추어 보면 이는 채권의 일부가 압류된 후에 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류명령이 발하여진 때에는 각 압류의 효력은 그 채권의 전부에 미친다고 하는 일반채권에 기한 강제집행에 있어서의 압류경합의 경우와 다르다고 할 것으로서 우선권 있는 채권에 기한 체납처분에 의한 압류에 관하여서는 피압류채권의 일부를 특정하여 압류한 경우 그 특정한 채권 부분에 한하여 압류의 효력이 미치는 것이며 그 후 강제집행에 의한 압류가 있고 그 압류된 금액의 합계가 피압류채권의 총액을 초과한다고 하더라도 그 압류의 효력이 피압류채권 전액으로 확장되지 아니한다고 할 것이므로 나머지 부분에 대하여는 압류경합이 되는 것은 아니라고 할 것이다.

120) 윤경(주101), 492.

121) 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결; 임용모(주101), 757.; 강인애(주101), 243.; 조재연(주101), 118.; 신동기(주70), 464.

122) 민사집행법 제236조 제2항의 「다른 압류」에는 체납처분에 의한 압류가 포함된다(대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다203833 판결).

유신고를 해야 하고,¹²³⁾ 그에 따라 실시된 배당절차에서 결국 조세채권자인 丙이 모두 배당받게 될 것이다.

원래 체납압류권자는, 앞서 본대로 체납처분절차와 일반 강제집행절차를 조정하는 법률이 없고 또 체납처분에 기한 압류채권자가 일반 채권집행의 배당절차에서 배당받을 채권자에 해당되는 것도 아니므로(제247조 제1항 참조), 배당표에 이를 기재하거나 또는 그 자를 상대로 배당이의의 소를 제기하거나 그 소송의 상대방이 될 수 없는 것이다. 그러함에도 불구하고 현재 실무는 체납압류권자가 포함된 피압류채권이 공탁되면 이를 배당절차 사건으로 접수한 후 배당절차를 진행하여 체납압류권자에게 배당을 해주고 있으나, 그렇다고 하더라도 이는 체납압류권자의 추심권 행사의 결과일 뿐이지 체납압류권자가 배당받을 채권자여서 그와 같이 배당을 해주는 것이 아니라고 보아야 한다. 즉 체납압류권자는 일반 민사집행절차에 참여할 수 없고 다음에서 보게 되듯이 체납압류권자가 포함된 채권집행에 대하여 제3채무자가 집행공탁을 할 수도 없는 것이나, 그런데도 일단 집행공탁이 되면 실무는 이를 배당절차로 진행하여 배당해주고 있는 것인데, 이는 체납압류권자가 민사집행절차의 진행과 관계없이 어느 단계에서든 자신의 추심권을 행사하여 그 실현이 가능하다는 것의 표현일 뿐이다(그 배당에 있어서 배당법원은 조세채권자의 일반채권자에 대한 우선적 지위를 고려하여 먼저 배당해주고 나머지를 일반채권자에게 배당하는 방식으로 처리하는 것이다). 또한 배당이의의 소를 인정하는 것도 원래는 배당절차 및 집행절차가 모두 종료한 후에 실체법상 부당이득반환청구소송으로 해결해야 할 것을 분쟁의 일회적 해결을 위해 배당이의절차에서 가능하도록 취급하고 있는 것이라 보아야 할 것이다.

그러나 제3채무자가 체납처분에 의한 압류권자인 丙에게 변제하면 체납처분절차에는 추심명령과 같은 추심신고 및 공탁제도가 없고, 일반채권자가 세무서장에게 체납압류권자에게 배분하고 남은 잉여금을 자신에게 지급하라고 요구할 수 있는 절차가 마련되어 있지 아니하므로 결국 일반채권자인 丁은 체납자(집행채무자인 甲)의 丙에 대한 잉여금반환채권을 다시 압류하는 수밖에 없을 것이다.

다) 위의 경우에 丙 또는 丁이 추심권을 행사해오지 않는다면 乙은 어떻게 해야

123) 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결(제3채무자는 이 경우 압류 및 추심명령에 선행하는 체납처분에 의한 압류가 있어 서로 경합된다는 사정만을 내세워 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 추심청구를 거절할 수 없고, 또한 민사집행절차에 따른 압류가 근로기준법에 따라 우선변제권을 가지는 임금 등 채권에 기한 것이라는 등의 사정을 내세워 체납처분에 의한 압류채권자의 추심청구를 거절할 수도 없다고 판시)

할까.

먼저, 이 경우 채권가압류에 있어서 민법 제487조에 의한 변제공탁을 인정한 위 대법원 93다951 판결의 취지를 준용하여 체납처분에 의한 압류가 선행하고 강제집행에 기한 압류가 후행하는 경우에도 제3채무자는 별개절차인 민사절차에 의한 압류가 있기 때문에 피공탁자를 집행채무자로 하는 변제공탁을 할 수 있다고 보는 견해가 있다.¹²⁴⁾

그러나 체납처분에 의한 압류 후에 강제집행에 의한 압류가 있는 경우에는 체납처분에 의한 압류권자가 취득하는 추심권의 효력에 의해 피압류채권의 채권자와 채무자에 대하여 그 채권에 관한 변제, 추심 등 일체의 처분행위를 금지하고, 체납압류권자가 체납자에 대신하여 추심할 수 있게 되는 것이므로(국세징수법 제41조 제2항, 제42조 등), 제3채무자는 피압류채권에 관하여 체납자에게는 변제할 수 없고 추심권자인 국(國)에게만 이행할 수 있을 뿐이며,¹²⁵⁾ 또한 강제집행에 의한 압류가 있다 하더라도 이를 이유로 체납처분에 의한 압류권자의 추심청구를 거절할 수도 없기 때문에, 제3채무자는 이행기가 도래하면 지체 없이 체납처분에 의한 압류권자에게 채무이행을 해야지 압류채무자(체납자)를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수는 없다 할 것이므로 위 견해에는 찬동하기 어렵다.¹²⁶⁾ ¹²⁷⁾ ¹²⁸⁾

라) 다만 그 조세채권자와의 관계에서 「별도의」 변제공탁사유가 있다면 그 때에는 체납압류권자를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수 있다고 본다.

여기서 「별도의」 변제공탁사유가 무엇인가에 관하여, 이예다가 체납압류에 의한 추심권자(혹은 일반압류에 기한 추심권자)가 변제기 도래 후 상당기간을 경과하여도 추심하러 오지 않을 경우를 포함시킴으로써 이러한 때라면 제3채무자는 변제불능을

124) 윤경(주101), 495.

125) 대법원 1999. 5. 14. 선고 99다3686 판결【판결요지】[2] 국세징수법 제41조에 의한 채권압류의 효력은 피압류채권의 채권자와 채무자에 대하여 그 채권에 관한 변제, 추심 등 일체의 처분행위를 금지하고, 체납자에 대신하여 추심할 수 있게 하는 것이므로 제3채무자는 피압류채권에 관하여 체납자에게는 변제할 수 없고, 추심권자인 국(國)에게만 이행할 수 있을 뿐이다.

126) 同旨 : 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007다33842 판결

127) 또한 압류된 채무가 지참채무일 경우(대부분 그럴 것임), 제3채무자는 변제기 도래 후 다른 사정이 없는 한 압류권자의 현주소 또는 영업소에 가서 채무이행을 하여야 하는데, 이러한 때에 변제공탁을 인정한다면 압류권자는 자신의 아무런 귀책사유도 없이 채권행사를 위해 공탁소에 직접 가서 공탁물출급청구를 해야 하는 번거로움도 발생할 것이다.

128) 다만 위의 예에서처럼 체납압류가 피압류채권의 일부인 400만 원 범위 내에서만 행해진 경우라면 그것을 제외한 나머지 600만 원에 대해서는 위와 같은 변제공탁(현행 민사집행법下에서는 권리공탁)을 인정할 여지는 있다.

이유로 위 추심권자를 피공탁자로 하여 변제공탁을 할 수 있다고 보는 견해가 있다.¹²⁹⁾

하지만 채납압류의 효력이 발생하면 제3채무자는 그 이행기 도래시 대부분 지참 채무의 원칙상 다른 사정이 없으면 압류권자의 현주소 또는 영업소에 직접 가서 채무 이행을 하는 것이기 때문에 추심권자가 추심권 행사를 하지 않는다는 이유만으로 당연히 제3채무자가 그 압류권자를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수 있는 것은 아니라 할 것이다.¹³⁰⁾ 그리고 그것은 압류권자가 변제기 도래 후 상당기간 추심권 행사를 하지 않는 경우일지라도 마찬가지다.

따라서 위에서 말한 「별도의」 변제공탁사유란 제3채무자의 항변권, 특히 상계권 행사와 관련하여 채무금액에 다툼이 있는 등의 사유로 압류권자가 수령을 거절하거나 또는 채권양도와 경합 등의 사유로 채권자 불확지에 해당하는 경우 등을 말하는 것이고, 이와 같은 경우에 제3채무자는 채납압류권자를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수 있다고 보아야 한다.

마) 결국, 위의 논의를 종합해 보면, 압류권자들이 추심권을 행사하지 않더라도 제3채무자는 압류채무자를 피공탁자로 하는 변제공탁은 할 수 없다는 것이 되고, 채납압류권자에 대한 변제공탁도 그 추심권 불행사의 사유만으로는 인정하기 곤란하다.

바) 이제 그렇다면, 집행공탁 쪽으로 발길을 돌려보기로 하자.

우리는 앞서, 구 민소법 제581조 제1항의 권리공탁규정이 대법원 95마252 판결에 의하여 중복압류 등에 의해 압류가 경합하는 경우에도 유추적용되었다는 것, 그리고 그것은 다시 대법원 96다5179 판결에 의해 진정한 압류의 경합이 아닌 경우, 즉 복수의 압류명령이 존재하지만 그 압류액의 총액이 피압류채권액을 초과하지 않는 경우에도 또한 유추적용됨으로써 그로 인하여 위 모든 경우에 있어 제3채무자는 위 규정에 따른 권리공탁이 가능해졌다는 것을 살펴본 바 있다.

그런데 여기에서 한 가지 주목할 것은 위 대법원 96다5179 판결이 위와 같은 경우에 권리공탁을 인정하고 있는 이유 부분에 관한 것이다. 위 대법원판결은 위와 같은 유추적용을 이끌어내는 데 있어서, ‘첫째로, 복수의 압류명령이 있지만 압류액의 총액이 피압류채권액을 초과하지 않는 경우는 본래적 의미에 있어서 압류의 경합이 아니다. 둘째로, 그렇지만 이런 경우라도 제3채무자의 입장에서 볼 때에는 압류의 경

129) 윤경(주101), 495.의 각주 525)

130) 임용모(주101), 762.

합이 있는지 여부에 대한 판단이 곤란하다고 보이는 객관적 사정이 있다.’라는 식으로 논리를 전개해가고 있는 것이다.

채납압류권자인 丙이 피압류채권 전액인 1,000만 원을 압류하고, 일반채권자인 丁이 다시 피압류채권을 모두 압류한 위의 사례는 이미 보았듯이, 이론적으로 압류가 경합된 경우가 아니다(이는 丙이 피압류채권 일부인 400만 원을 압류하고, 丁이 1,000만 원을 전부 압류한 경우라도 마찬가지이다).

하지만 이러한 경우일지라도 제3채무자인 乙의 입장에서 본다면, 복수의 압류가 있고, 그 압류액의 총액이 피압류채권액인 1,000만 원을 넘어서고 있는지라 우리 법 구조상의 채납처분절차와 민사집행절차의 특수성을 알지 못하는 한 압류가 경합되어 있다고 볼 여지가 충분히 있고, 그렇지 않더라도 최소한 그 압류 경합 여부에 대한 판단이 곤란하다는 객관적 사정이 있다고 볼 수 있는 것이다.

그러므로 이러한 경우도 위 대법원 96다5179 판결의 취지에 비추어 구 민소법 하에서라면 제3채무자는 위 제581조 제1항을 유추적용함으로써 그에 따른 집행공탁을 할 수 있다고 보아야 할 것이다.

그러하다면 현행 민사집행법하에서도 이러한 경우 제3채무자는 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리공탁을 할 수 있다고 해석될 수 있는 것이다(다만 이 경우는 압류의 경합이 아니고, 위 대법원판결 역시 구 민소법 제581조 제1항의 권리공탁 규정에 관해서만 유추적용할 수 있다고 판시한 점에 비추어 현행 민사집행법하에서 새로 생긴 민사집행법 제248조 제3항에 따른 의무공탁규정은 유추적용되지 않는다고 보아야 할 것이다). 이 경우 제3채무자가 위와 같은 압류경합이 아니라 후행하는 강제집행에 의한 압류가 1개인 것에 착안하여 권리공탁을 하는 것은, 그럴 경우 그 공탁을 가지고 채납압류권자에게 대항할 수 없기 때문에 바람직하지 않다.

따라서 위 사례에서 丙과 丁이 추심권을 행사해오지 않는 경우 제3채무자인 乙은 변제공탁은 어렵지만 민사집행법 제248조 제1항에 따른 권리공탁은 할 수 있다고 본다(반대 견해 있음).

그에 따라 한걸음 더 나아가면, 丙 또는 丁이 추심권을 행사함에 대하여 乙은 이를 거절하고 민사집행법 제248조 제1항에 따라 피압류채권 전액을 공탁할 수도 있다. 丙의 추심권 행사에 대해 乙이 이를 지급하지도 않고 공탁도 하지 않는 경우라면 丙은 국세징수법시행령 제45조에 의해 채권자(집행채무자)를 대위하여 채무자(제3채무자)를 상대로 소송을 제기해야 하고, 그에 따라 지급 받은 채권액 400만 원은 국세징수법 제

81조 이하에 따라 배분절차를 밟게 된다. 丁의 추심권 행사에 대해 乙이 응하지 않으면 丁 또한 추심금 소송을 제기하여야 하고, 거기에서 승소하면 다시 민사집행법 제236조 제1항, 제2항에 따라 공탁하고 사유신고한 다음 배당절차로 나아가게 될 것이다.

사) 이와 같은 경우 설사 집행공탁이 가능하지 않다고 하더라도 제3채무자는 위 채권자들 중 우선하는 채권자를 확지할 수 없다는 것을 들어 채권자불확지 변제공탁과 집행공탁(위의 예에서 丁과 戊의 압류는 경합하고 있으므로)을 합한 혼합공탁을 할 수 있다. 그럴 경우 피공탁자는 「甲(채무자) 또는 丙(조세채권자)」이고, 공탁근거법령은 「민법 제487조 후단, 민사집행법 제248조」로 적으면 될 것이다(제9장 혼합공탁 제4절 I. 참조).

2) 실무 및 판례의 입장

가) 구 민소법하의 대법원 1999. 5. 14. 선고 99다3686 판결은, “현행법상 국세채납 절차와 민사집행 절차는 별개의 절차로서 양 절차 상호간의 관계를 조정하는 법률의 규정이 없으므로 한 쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭할 수 없는 반면, 쌍방 절차에서 각 채권자는 서로 다른 절차에 정한 방법으로 그 다른 절차에 참여할 수 밖에 없고, 동일 채권에 관하여 양 절차에서 각각 별도로 압류하여 서로 경합하는 경우에도 공탁 후의 배분(배당)절차를 어느 쪽이 행하는가에 관한 법률의 정함이 없어 제3채무자의 공탁을 인정할 여지가 없다.”고 판시하여 제3채무자의 공탁을 부정하였다. 위 판시의 근거에는 민사집행법 제248조 제1항에 의한 집행공탁을 인정하면 그 후의 배당절차에서 채납처분권자도 참여할 수 있는 길을 마련하여 주어야 하는데, 현행법상 그것이 어렵다는 이유가 깔려있다.

즉 배당요구란 먼저 강제집행에 착수한 채권자가 있는 경우에 다른 채권자가 그 절차에서 동일한 재산으로부터 평등한 비율로 변제를 받으려는 집행신청이므로 배당요구의 시기는 해석상 압류명령이 제3채무자에게 송달된 때부터 할 수 있다고 보는데, 강제집행에 의한 채권압류명령이 제3채무자에게 송달되기 전에 이루어진 채납처분에 의한 채권압류를 배당요구와 동일한 효력이 있는 것으로 볼 수는 없기 때문이다.

위와 같은 판례의 기본 입장에 따르면, 채납압류와 일반 채권에 기한 압류가 경합하는 경우 제3채무자의 집행공탁은 가능하지 않고, 설사 제3채무자가 공탁을 하였다고 하더라도 채납압류권자는 여전히 제3채무자에게 직접 피압류채권을 추심할 수

있고, 제3채무자는 이를 거절할 수 없다.¹³¹⁾

대법원 행정예규 제542호(공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침, 2004. 4. 1. 개정)에서도, 복수의 압류가 있고 집행채권의 총액이 피압류채권(공탁금지급청구권) 총액을 초과하더라도, 체납처분에 의한 압류가 선행하고, 강제집행에 의한 압류가 후행한 경우는 사유신고의 대상이 아니라고 규정하고 있는데, 이는 제3채무자의 공탁을 부정하는 취지였다고 볼 수 있다.¹³²⁾

나) 그러나 대법원은 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결에 이르러 이러한 입장을 변경하고 있다. 즉 “이 경우 제3채무자는 체납처분에 따른 압류채권자와 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자 중 어느 한쪽의 청구에 응하여 그에게 채무를 변제하고 변제 부분에 대한 채무의 소멸을 주장할 수 있으며, 또한 민사집행법 제248조 제1항에 따른 집행공탁을 하여 면책될 수도 있다. 그리고 체납처분에 의한 압류채권자가 제3채무자에게서 압류채권을 추심하면 국세징수법에 따른 배분절차를 진행하는 것과 마찬가지로, 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자가 제3채무자에게서 압류채권을 추심한 경우에는 민사집행법 제236조 제2항에 따라 추심한 금액을 바로 공탁하고 사유를 신고하여야 한다.”라고 판시함으로써 체납압류와 일반 강제집행에 의한 압류가 경합하는 경우 제3채무자에 의한 집행공탁을 인정하고 있는 것이다. 이러한 대법원의 태도는 공탁제도의 법리와 그 취지상 지극히 타당한 것이라고 본다.

다) 한편 토지수용보상금이 지급되기 전에 우선권 있는 저당권자가 물상대위에 의하여 토지수용보상금채권을 압류한 경우, 그 압류를 전후하여 토지수용보상금채권에 대한 체납처분에 의한 압류가 있었다고 하더라도 민사집행법 제248조 제1항에 의한 집행공탁을 할 수 있다.¹³³⁾ 그 이유는 체납압류가 있다고 하더라도 저당권자의 물상대위권에 기한 압류가 있으면 그 효력의 우열관계는 저당권설정등기일과 체납압류의 효력발생

131) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007다33842 판결(설사 체납압류 후에 근로기준법상 우선변제권을 갖는 임금 등 채권에 의한 가압류집행이 이루어졌더라도 제3채무자는 그 가압류를 이유로 체납압류권자의 추심청구를 거절할 수 없다고 판시); 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결(제3채무자는 압류 및 추심명령에 선행하는 체납처분에 의한 압류가 있어 서로 경합된다는 사정만을 내세워 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 추심청구를 거절할 수 없고, 또한 민사집행절차에 따른 압류가 근로기준법에 따라 우선변제권을 가지는 임금 등 채권에 기한 것이라는 등의 사정을 내세워 체납처분에 의한 압류채권자의 추심청구를 거절할 수도 없다고 판시)

132) 위 예규 내용은 민사집행법 제정 전에도 동일하였음 - 1999. 5. 26. 제정 대법원 행정예규 제387호

133) 공탁선례 제201210-1호, “토지수용보상금이 지급되기 전에 체납처분에 의한 압류 후 담보권자의 물상대위에 의한 압류가 있는 경우 제3채무자가 공탁할 수 있는지 여부(적극)”

시기의 선후에 의하게 되어 마치 저당권설정등기일에 압류가 행해진 것과 같게 되기 때문이다(즉 이 경우 체납압류가 물상대위에 기한 압류보다 먼저 되었든, 나중에 되었든 결국 저당권의 설정등기일보다 나중에 된 것이므로 일반압류 후에 행해진 것으로서 교부청구 또는 참가압류의 효력밖에 없고, 따라서 집행공탁이 가능한 것이다).

마. 배당절차 진행 문제

위와 같이 체납처분에 의한 압류 후에 일반 강제집행에 의한 압류가 있는 경우 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따른 집행공탁을 하여 면책될 수 있는 것에서 더 나아가 집행법원이 이에 대하여 배당절차를 진행함으로써 절차를 종료시킬 수 있는지 여부가 문제로 될 수 있다.

이에 대하여 판례는 이를 긍정하고 있다.¹³⁴⁾ 즉 “민사집행절차에서 압류 및 추심 명령을 받은 채권자뿐만 아니라 체납처분에 의한 압류채권자의 지위도 민사집행법상의 배당절차에서 배당을 받을 채권자의 지위로 전환된다고 할 것이어서, 체납처분에 의한 압류채권자가 공탁사유신고 시나 추심신고 시까지 민사집행법 제247조에 의한 배당요구를 따로 하지 않았다고 하더라도 그 배당절차에 참가할 수 있다.”라고 판시하고 있는 것이다. 위 판례는 그 근거로서 ① 체납압류 또한 제3채무자에게 채무자에 대한 지급을 금지하고 채무자에게 채권의 처분과 영수를 금지하는 효력을 가지는 것으로서 민사집행절차에서 압류명령을 받은 채권자의 전속적인 만족을 배제하고 배당절차를 거쳐야만 하게 하는 민사집행법 제229조 제5항의 ‘다른 채권자의 압류’나 민사집행법 제236조 제2항의 ‘다른 압류’에는 해당하는 점, ② 민사집행법에 따른 압류 및 추심명령과 체납처분에 의한 압류가 경합한 후 제3채무자가 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 추심청구에 응하거나 민사집행법 제248조 제1항에 따른 집행공탁을 하게 되면 그 피압류채권은 소멸하게 되고 이러한 효력은 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자에 대하여는 물론 체납처분에 의한 압류채권자에 대하여도 미치므로 민사집행법에 따른 압류 및 추심명령과 함께 체납처분에 의한 압류도 그 목적을 달성하여 효력을 상실하는 것으로 보아야 하는 점 등을 들고 있다.

위 대법원판결은 기존 실무가 이 경우 제3채무자의 집행공탁을 인정하고 그에 따라 배당절차사건으로 접수한 후 배당절차로 진행해주고 있던 것을 반영한 것으로서 이론적으로 살펴봐도 타당한 것이라 하겠다.

134) 대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다203833 판결

4. 일반채권에 기한 압류 후에 체납처분에 의한 압류 등이 있는 경우

☞ 일본 滯調法에 의하면, 채권 일부에 관하여 강제집행에 의한 압류가 된 경우에 있어서, 그 잔여 부분을 초과하여 체납처분에 의한 압류가 된 때에는 강제집행에 의한 압류의 효력은 그 전부에 미치는 것으로 되어 있다(滯調法 제36조의4).

滯調法은, 체납처분에 의한 압류를 강제집행절차 속으로 끌어들여 그 절차에 있어서 채권 전체에 대하여 환가배당하는 것으로서 양 절차의 조정을 도모하고 있는바, 이를 위해서는 강제집행에 의한 압류의 효력을 채권 전체에 미치도록 해둘 필요성이 있는 것이다.

금전채권에 대하여 강제집행에 의한 압류가 된 후 체납처분에 의한 압류가 있어 압류가 경합하는 때에는 제3채무자는 그 채권 전액에 상당하는 금전을 채무이행지 공탁소에 공탁해야 한다(滯調法 제36조의3 제1항). 이는 공평배당을 확보하기 위한 것이다.

제3채무자는 위 공탁을 한 때에는 집행재판소에 대하여 사유신고를 해야 한다(滯調法 제36조의6 제2항). 그 사유신고를 받은 집행재판소는 그 뜻을 징수직원 등에게 서면으로 통지해야 한다(滯調法 제36조의6 제3항). 이때 사유신고에 관계된 국세 등에 관하여는 체납처분에 의한 압류가 있었던 때에 교부요구가 있었던 것으로 된다(滯調法 제36조의10 제1항).¹³⁵⁾

가. 교부청구 또는 참가압류의 경우

1) 세무서장은 납세자가 집행법원 등에 의해 강제집행을 받을 때에는 납기 전이라도 이미 납세의무가 확정된 국세 등에 관해서는 당해 집행법원 등에 대하여 국세·가산금과 체납처분비의 교부를 청구할 수 있고(국세징수법 제56조, 제14조 제1항 제3호), 압류하고자 하는 재산이 이미 다른 기관에서 압류하고 있는 재산인 때에는 위의 교부청구에 갈음하여 참가압류통지서를 그 재산을 이미 압류한 기관에 송달함으로써 그 압류에 참가할 수 있다(국세징수법 제57조 제1항).

즉 위 규정에 따르면 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 채무자의 채권자가 이미 압류하였다면 조세채권자는 교부청구하거나 또는 그에 갈음하여 참가압류할 수 있다는 것이다.

135) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 518-520.

이런 경우 교부청구나 참가압류는 모두 배당요구로서의 효력이 있다.¹³⁶⁾ 그리하여, 예컨대 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 대여금 채권에 관하여 일반채권자인 丙이 1,000만 원을 압류한 이후에 다시 조세채권자(세무서장)인 丁이 400만 원을 교부청구 또는 참가압류하였다면 위 400만 원 부분은 배당요구의 효력이 있으므로 결국 이는 민사집행법 제248조 제1항, 제2항의 적용 대상이 된다.¹³⁷⁾

따라서 이 경우 제3채무자인 乙은 일반채권자인 丙의 추심청구 이전이라면 민사집행법 제248조 제1항에 따라 피압류채권 전액인 1,000만 원을 공탁할 수 있고, 조세채권자인 丁이 민사집행법 제248조 제2항에 따라 공탁청구를 하면 압류된 부분에 해당하는 1,000만 원을 공탁해야 한다.

2) 일반채권자인 丙의 추심청구에 대해 乙이 채무액 1,000만 원을 지급하면, 丙으로서는 민사집행법 제236조 제1항, 제2항¹³⁸⁾에 따라 공탁하고 사유신고를 한 후 배당절차로 진행하게 될 것이다.

제3채무자인 乙로서는 丙의 추심청구를 거절하고 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁할 수 있고, 또한 지급도 않고 공탁도 하지 않을 수 있으므로 이러한 때에는 丙은 추심금 소송으로 문제를 해결해야 한다.

나. 체납처분에 의한 압류의 경우

1) 이제, 위의 예에서 조세채권자인 丁이 400만 원의 甲에 대한 채권을 가지고 위와 같이 국세징수법에서 정하고 있는 교부청구 또는 참가압류가 아니라 丙의 채권 압류 이후에 다시 국세징수법 제41조 제1항에 따라 체납처분에 의한 압류를 한 경우 그 효력 여하는 어떠한지에 관하여 보기로 한다.

2) 이에 관하여는 위와 같은 체납처분에 의한 압류는 부적법한 것이므로 그 효력을 인정할 수 없다는 취지로 주장하는 견해¹³⁹⁾도 있고, 현행 국세징수법상 명문의 규정에 의할 때 이러한 견해도 일응 수긍되는 바가 없지 않으나, 그렇다고 해서 부동산과 달리 공시방법이 없는 채권압류에 있어서 조세채권자로 하여금 압류하고자 할 때마다 선행 압류가 있는지 여부를 확인하여 교부청구 또는 참가압류를 할 것인가 아

136) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96다51585 판결; 대법원 2001. 6. 12. 99다45604 판결; 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000다21154 판결; 대법원 2001. 11. 27. 선고 99다22311 판결; 대법원 2012. 5. 10. 선고 2011다44160 판결 등.

137) 대법원 행정예규 제542호 「공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침」도 이 경우 압류 경합에 준하여 제3채무자의 공탁 및 사유신고를 인정하고 있는 취지로 볼 수 있다.

138) 이때 丁의 교부청구(배당요구)는 민사집행법 제236조 제2항의 「다른 배당요구」에 해당된다.

139) 남기정(주99), 118. 이하

니면 체납압류를 할 것인가를 결정하여 참가하도록 하는 것도 적절하지 않고,¹⁴⁰⁾ 또 이러한 압류도 그것이 법에 규정된 바대로 행해지지는 않았지만 최소한 조세채권자가 배당요구를 바라는 의사표시를 나타냈다고 선해(善解)할 수 있다고 보이는 점 등을 고려하면, 이러한 경우일지라도 그 압류에 교부청구(배당요구)의 효력을 인정할 수 있다고 보아야 한다.^{141) 142)}

그렇다면 이 경우도 위 가.와 마찬가지로 제3채무자는 민사집행법 제248조 제1항에 따라 집행공탁이 가능하다 할 것이다.¹⁴³⁾

3) 다만 이러한 경우이더라도 조세채권자가 체납압류를 하였다는 사실을 집행법원이 요지(了知)하여야만 그에 대하여 배당등 절차를 진행시킬 수 있을 것이므로 이와 같이 민사집행에 의한 압류가 되어 있는 채권에 대하여 체납처분에 의한 압류가 되었다면 최소한 ① 조세채권자가 그 압류사실을 집행법원에 통지하거나 ② 혹은 제3채무자가 공탁을 하고 그 사유를 집행법원에 신고할 때에 그 사유신고서에 체납처분에 의한 압류의 표시가 기재되어 있어야만 할 것이다(현재의 실무는 대부분 위 ②의 경우가 많아 그와 같이 처리되고 있다). 그리고 이때에 교부청구(배당요구)를 하였다

140) 현재 채권압류의 실무상 조세채권자가 체납압류(국세징수법 제41조 제1항, 제3항)와 교부청구 또는 참가압류(국세징수법 제56조, 제57조)를 구별하여 압류절차에 참가하는 것은 오히려 예외라고 할 정도인데, 이러한 참가를 모두 무효라고 하기에는 그 실정을 다소 도외시한 해석론이라고 보여진다.

141) 임용모(주101), 767.; 대법원 1994. 3. 22. 선고 93다19276 판결, 대법원 1993. 9. 14. 선고 93다22210 판결 등

142) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96다51585 판결 [판결요지][1] 세무서장이 국세징수법 제56조에 따라서 경매법원에 대하여 국세의 교부를 청구하는 것은 민사소송법에 규정된 부동산경매절차에서 하는 배당요구와 성질이 같은 것이므로 국세의 교부청구도 배당요구와 마찬가지로 경락기일까지 할 수 있으나, 경매부동산에 관하여 국세체납처분의 절차로서 압류의 등기가 되어 있는 경우에는 교부청구를 한 효력이 있는 것으로 보아야 하고, 이 경우 세무서장이 경락기일까지 체납된 국세의 세액을 계산할 수 있는 증빙서류를 제출하지 아니한 때에는 경매법원으로서의 당해 압류등기촉탁서에 의한 체납세액을 조사하여 배당할 수 있다. [2] 확정된 배당표에 의하여 배당을 실시하는 것은 실체법상의 권리를 확정하는 것이 아니므로 배당을 받아야 할 자가 배당을 받지 못하고 배당을 받지 못할 자가 배당을 받은 경우에는 배당을 받지 못한 우선채권자는 배당을 받은 자에 대하여 부당이득반환청구권이 있다. [3] 강제집행진행 중의 부동산에 대하여 조세채권의 보전을 위한 압류가 있었으나 경락기일까지 압류사실을 신고하지도 않고 체납 세액을 계산할 수 있는 증빙서류도 제출하지 않은 조세채권자에게도 당해 압류등기촉탁서 등에 의하여 조사 가능한 체납세액은 그 우선순위에 따라 배당하여야 한다는 이유로, 확정된 배당표에 의하여 배당에서 제외된 조세채권자의 부당이득반환청구를 인용한 사례(본 사건은 경매개시결정의 기입등기 후 국가가 토지초과이득세 채권의 보전을 위한 압류를 하였으나 경락기일까지 압류사실의 신고, 체납 세액을 계산할 수 있는 증빙서류의 제출, 교부청구 등의 어느 것도 하지 아니하고 있다가 경락기일 이후 배당기일 이전에 금 166,798,484원의 교부청구를 하였으나 경매법원이 조세채권에 대한 배당을 하지 아니한 채 배당표가 확정된 사안임).

143) 이에 관하여 대법원 행정예규 제542호 「공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침」도 이 경우 압류 경합에 준하여 제3채무자의 공탁 및 사유신고를 인정하고 있는 취지로 볼 수 있다.

고 보는 시기는 집행법원이 체납압류사실을 안 때가 아니라 조세채권자가 체납처분에 의한 압류를 한 때라고 해석해야 한다.

그렇다면 앞서와 같이 일반채권자인 丙이 1,000만 원을 압류한 이후에 조세채권자인 丁이 400만 원에 대하여 교부청구 또는 참가압류가 아닌 체납압류를 하였다 하더라도 이에겐 교부청구(배당요구)의 효력이 있다고 해야 할 것이므로 그에 대한 법률관계는 결국 위 가.항과 같아지게 된다.

5. 체납처분에 의한 압류와 보전처분이 경합하는 경우

☞ 일본 滯調法の 경우, 금전채권에 관하여 가압류 집행과 체납처분에 의한 압류가 경합하는 때에는 제3채무자는 그 채권 전액에 상당하는 금전을 채무이행지 공탁소에 공탁하는 것이 가능하다(滯調法 제20조의9 및 제36조의12에 의한 滯調法 제20조의6 제1항 준용).

이 경우 가압류집행과 체납처분에 의한 압류의 선후에 불구하고 징수직원 등이 우선하여 징수권을 가지기 때문에(국세징수법 제67조 제1항, 제140조), 제3채무자에게 공탁의무를 과할 필요가 없다.

이 경우 공탁에 관해서는 금전채권에 대하여 가압류집행만이 된 경우의 공탁과 동일하다.¹⁴⁴⁾ 다만 위 滯調法은 가압류의 대상이 채권, 무체재산권 등인 경우와 가처분에 대해서는 적용되지 않는 것으로 되어 있다.

가. 보전처분의 효력 여하

우선 국세징수법 제35조는 “재판상의 가압류 또는 가처분 재산이 체납처분 대상인 경우에도 이 법에 따른 체납처분을 한다.”라고 규정하고 있으므로 체납압류 후에 민사집행에 의한 가압류 또는 가처분¹⁴⁵⁾이 있어도 체납압류는 그 영향을 받지 아니하고, 또한 이미 체납자의 재산에 대하여 가압류 또는 가처분집행이 되어 있다 해도 이에 개의치 않고 체납처분에 의한 압류가 가능하다.

하지만 위 규정이 이에 더 나아가 체납압류와 보전처분 사이의 효력에 관한 우열문제까지 해결하고 있는 규정이라고 보기는 어려우므로¹⁴⁶⁾ 이 문제는 다시 살펴보

144) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 520.

145) 가처분 중에서 민사집행법 제304조에 의한 임시의 지위를 정하는 가처분이나 상법 제407조 제1항에 의한 이사의 직무집행정지가처분 등은 그 성질상 금전급부를 목적으로 하는 체납처분 절차와 경합될 여지가 없으므로 여기에서는 이를 제외하기로 한다.

아야 할 것인바, 이에 관해서는 현재 견해가 분분하다.

1) 체납압류 후에 행해진 보전처분의 효력

체납처분에 의한 압류가 있는 후에 가압류 또는 가처분을 할 수 있는가의 문제에 관해서는 앞서 본 본압류의 경우와 달리 이해할 이유가 없으므로 이를 긍정해야 할 것이다.

다만 예컨대 조세채권자인 丙이 피압류채권 전액인 1,000만 원을 체납압류한 이 후에 일반채권자인 丁이 다시 1,000만 원의 채권으로써 가압류집행을 한 경우, 丁의 가압류집행의 효력을 어떻게 이해할 것인가의 문제가 있다.

이에 관하여 현재 대부분의 학설은,¹⁴⁷⁾ 체납압류가 해제되는 경우를 생각하여 체납압류와 모순되지 않는 한도에서 가압류 등의 집행은 가능하지만, 체납처분이 완결되면 가압류 등은 무시되므로 체납처분절차가 종료되면 그 후에 이루어진 가압류 등은 모두 말소되어야 한다고 해석하고 있으며, 위 국세징수법 제35조의 취지상 이러한 해석은 타당하다고 본다.

그리고 위의 경우에 만일 丙이 피압류채권의 일부인 400만 원만 압류하였다면 丁의 가압류는 그와 모순되지 않는 600만 원 한도에서는, 丙에 의하여 위 400만 원에 대한 체납처분절차가 종료한다 하더라도 여전히 그 효력을 유지하게 될 것이다.

2) 보전처분 후에 체납압류가 있는 경우

가) 가압류의 경우

(1) 일반적으로 가압류명령의 집행은 채무자가 가압류의 목적물에 대하여 하는 매매, 증여 또는 질권 등의 담보권설정 기타 일체의 처분을 금지하는 효력을 생기게 한다.

다만 채무자가 가압류명령을 어기고 목적물을 처분하더라도 절대적으로 무효가 되는 것은 아니고 가압류채권자에 대한 관계에서만 그 처분행위의 무효를 주장할 수 없는 상대적 효력이 있을 뿐이다(가압류의 상대적 효력). 또한 가압류의 효력이 상대적이라고 할 때에 그 상대적인 무효를 주장할 수 있는 자의 범위에 관하여는 개별상 대효설과 절차상대효설이 대립하고 있으나, 가압류에 반하는 처분행위는 가압류채권

146) 대법원 1993. 2. 19.자 92마903 결정【결정요지】이는 선행의 가압류 또는 가처분이 있다 하더라도 체납처분의 집행에 영향을 미치지 않는다는 취지의 절차진행에 관한 규정일 뿐이고 체납처분의 효력이 가압류, 가처분의 효력에 우선한다는 취지의 규정은 아니므로...

147) 강인애(주101), 386.; 유수열, “보전처분과 체납처분의 경합”, 보전소송에 관한 제문제, 재판자료 46집, 287.; 조재연(주101), 123. 등

자 및 처분행위 이전에 집행에 참가한 자에 대한 관계에서만 무효일 뿐 처분행위 후에 집행에 참가한 채권자에 대하여는 그 처분의 유효를 주장할 수 있다는 개별상대효설이 통설·판례의 입장이다.¹⁴⁸⁾

(2) 한편, 위 국세징수법 제35조에 따라 체납자의 재산에 대하여 먼저 가압류집행이 되어 있더라도 체납처분에 의한 압류는 가능한 것이지만, 그와 같이 체납압류가 있을 때에 앞선 가압류의 효력은 어떻게 되는지에 관한 규정이 따로 없어서 이에 대해 가압류효력소멸설과 가압류효력유지설의 입장 차이가 있다.¹⁴⁹⁾

그러나 이에 관해서도 대부분의 학설은 체납처분의 집행에 영향이 없는 한 가압류채권자의 지위를 존중하는 것이 타당하다고 보아 이러한 경우 가압류의 효력은 체납처분에 의한 압류에 의하여 바로 소멸하지는 않고 체납처분에 의한 환가(현금화)가 완료된 경우에 비로소 소멸하는 것으로 해석하고 있고,¹⁵⁰⁾ 판례¹⁵¹⁾ 또한 “현행법상 국세체납절차와 민사집행절차는 별개의 절차로서 그 절차 상호간의 관계를 조정하는 법률의 규정이 없으므로 한 쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭을 할 수 없는 반면 쌍방절차에서의 각 채권자는 서로 다른 절차에서 정한 방법으로 그 다른 절차에 참여할 수밖에 없는 것이어서 유체동산에 대한 가압류집행이 있다고 하더라도 국세체납처분에 의한 공매처분이 종결되면 위 유체동산가압류의 효력은 상실되며 국세에 충당하고 남은 환가금에 대한 채무자의 반환채권에 위 가압류의 효력이 미친다고 볼 수 없다.”라고 판시함으로써 위 학설의 견해와 그 궤를 같이 하고 있다고 생각된다.

따라서 후행 체납압류가 있더라도 곧바로 선행 가압류가 실효되는 것은 아니며 가압류 중 체납압류되지 아니한 부분에 대해서는 가압류의 효력에 영향이 없고, 또 중복 압류된 부분에 대해서도 가압류의 효력은 잠재적으로 존속하므로 만일 체납압류가 해제되면 그때에 가압류의 효력은 현재화(顯在化)한다. 가압류의 효력이 완전 소멸하는 것은 가압류집행부분의 채권금액이 전부 체납압류에 의해 추심이 된 경우일 것이다.¹⁵²⁾

(3) 또한 이와 같이 가압류의 효력이 잠재적으로 존재하고 있다는 것과 관련하여 체납압류에 기해 추심한 금액에 대해 국세징수법에 따라 배분절차를 실시함으로써 체납세액에 충당하고 남은 잉여금이 있는 경우, 체납처분담당공무원이 그 잉여금을 가

148) 위 법원실무제요 민사집행(IV), 254.; 대법원 1994. 11. 29.자 94마417 결정 등 다수

149) 유수열(주147), 288. 이하; 임용모(주101), 771. 이하

150) 강인애(주101), 380.; 임용모(주101), 771.

151) 대법원 1989. 1. 31. 선고 88다카42 판결

152) 남기정, 위 실무공탁요론, 168.

압류채권자를 위하여 법원에 공탁해야 하는지, 아니면 그저 체납자에게 반환하면 되는 것인지 여부에 관하여 의문이 들 수 있는데, 이에 관하여 우리 판례¹⁵³⁾는 명시적으로 “민사소송법 제589조(현행 민사집행법 제256조, 제160조) 제3항의 규정은 평등주의 원칙에 입각한 강제집행과 가압류가 경합하는 경우에 한하여 적용되고, 우선주의 원칙에 의하여 규율되는 체납처분에는 명문의 근거 없이 위 규정이 적용된다고 볼 수 없기 때문에, 국세징수법 제49조, 제92조, 제1항, 국세징수사무규정(재무부훈령 제45호) 제55조의 각 규정을 종합하면 국세체납처분에 의하여 환가(현금화)한 돈에서 관계된 국세 등을 우선변제 충당하고, 나머지가 있을 때에는 이 돈은 체납자에게 반환할 것이요, 설사 그 체납처분이 된 재산 위에 이미 가압류채권자가 있다손 치더라도 체납처분 담당공무원이 그 돈을 가압류채권자를 위하여 법원에 공탁할 성질의 것은 아니라 할 것이다.”라고 판시하여 채무자반환설을 취하고 있다.

따라서 가압류채권자로서는 체납자가 조세채권자에 대하여 가지는 잉여금반환청구권을 다시 가압류해야만 그 잉여금에 대한 권리를 보전할 수 있을 것이다.

나) 가처분의 경우

(1) 가처분의 내용은 매우 다양하고 그 효력도 상이하여 일률적으로 말하기 어려우며, 그 범위도 상대적인 것이 있는가 하면 절대적인 것도 있다.

그런데 그 중 대표적이라고 볼 수 있는 처분금지가처분의 경우 그에 위반한 처분행위는 가처분채권자에 대한 관계에서는 물론이고 그 밖의 모든 사람에 대한 관계에서도 항상 절대적으로 무효라고 하는 견해(절대적 효력설)도 있기는 하지만, 판례와 통설은 위 가처분위반의 처분행위는 가처분채무자와 그 상대방 및 제3자 사이에서는 완전히 유효하고 단지 가처분채권자에게만 대항할 수 없음에 그친다는 견해(가처분효력의 주관적범위에 관한 상대적 효력설)를 취하고 있다.¹⁵⁴⁾

또한 위 처분금지의 효력은 가처분채권자의 권리를 침해하는 한도에서만 생기는 것이므로 가처분채권자는 피보전권리의 한도에서 가처분위반의 효력을 부정할 수 있

153) 대법원 1974. 2. 12. 선고 73다1905 판결

154) 대법원 1968. 9. 30. 선고 68다1117 판결 등 다수 【판결이유】가처분결정에 의하여 매매 기타의 처분행위가 금지된 부동산을 그 소유자로부터 매수한 제3자는 그 소유권취득의 효력을 가처분채권자에게 대항할 수 없으나 그 후 그 가처분의 등기가 적법하게 말소된 경우에는 그 후 그 소유권취득의 효력을 대항할 수 있다 할 것이므로 이 사건에 있어서 소의 유○○은 원 판시 가처분등기가 있은 후에 이 사건 토지를 피고로부터 매수하여 등기를 하였으므로 가처분채권자인 원고에게 대하여 그 소유권취득의 효력을 대항할 수 없었다 할지라도 그 후 가처분등기가 원 판시와 같이 적법하게 말소된 이상 소의 유○○은 이 사건 부동산에 대한 소유권취득의 효력을 원고에게 대항할 수 있다 할 것이니...

다(가처분효력의 객관적 범위에 관한 실체적 효력설).¹⁵⁵⁾

(2) 체납압류처분과 가처분의 관계에 있어서도 위 국세징수법 제35조에 따라 이미 가처분집행이 되어 있는 재산에 대하여도 체납압류가 가능한 것은 위 가압류의 경우와 같다. 다만 이때에 가처분의 효력이 어떻게 되는지에 관해서는 다음과 같은 견해가 서로 주장되고 있다.¹⁵⁶⁾

먼저, 가처분효력소멸설은 위 국세징수법 제35조를 체납처분과 가처분의 효력과 관계에 관한 창설적 규정으로 이해하고, 가압류와 마찬가지로 체납압류에 의하여 가처분의 효력은 소멸되지 않고 잠재적으로 존재하지만, 체납처분에 의하여 당해 재산에 대한 환가(현금화)가 완결된 경우에는 그 매수인의 권리취득과 저촉되는 가처분의 효력은 소멸하는 것으로 해석하는 견해이다.

이에 대해 가처분효력유지설은 위 국세징수법 제35조의 규정을 가처분의 효력에 관한 상대적 효력설의 입장에서 이미 가처분이 집행된 재산에 대해서도 체납처분을 집행할 수 있다는 것을 규정한 선언적 규정으로 이해하고, 또 조세채권과 특정물의 인도나 급여를 목적으로 하는 특정물에 관한 청구권 사이의 우선관계에 관해서는 아무 규정이 없으므로 처분금지가처분이 집행된 재산에 대한 체납처분은 적법하지만 가처분채권자가 본안소송에서 승소의 확정판결을 받게 되면 그 피보전권리와 상충되는 체납압류의 결과를 부인할 수 있으며 이때에는 체납처분의 완결에 의하여 매수인에게 소유권이 이전되더라도 이로써 가처분채권자에게 대항할 수 없다고 보는 입장이다.

(3) 생각건대 이 문제는 국세우선원칙을 선언한 국세기본법 제35조 제1항과 국세징수법 제35조의 규정을 어떻게 해석하느냐에 따라 그 결론이 달라지는 것인바, 그 해석에 있어서는 조세우선권을 규정한 목적, 그 특성 나아가 체납처분의 본질 및 보전처분의 성격, 목적 등을 합목적으로 고려하여 결정해야 하는 것이다. 그런데 가처분의 경우는 평등주의 원칙에 따르는 사채권(私債權)에 대한 장래의 집행을 보전함으로 목적으로 하므로 만족의 단계에 있어서 조세채권에 열후(劣後)하게 되는 것이 당연한 가압류의 경우와는 다르게 해석되어야 하는 것이다. 위 국세징수법 제35조가 체납처분의 집행이 보전처분의 방해를 받지 않고 병행하여 실시 가능한 것임을 인정한 것은 틀림없지만 이는 선행의 보전처분이 있다 하더라도 체납처분의 집행에 영향을 미치지 않는다는 취지의 절차 진행에 관한 규정에 불과하

155) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 255.

156) 조재연(주101), 288. 이하; 임용모(주101), 773. 이하

므로 이를 양자의 효력의 우열관계까지 해결하고 있다고 확대해석하는 것은 가처분 채권자에게 예측할 수 없는 손해를 주는 가혹한 결과를 낳을 수 있어서 부당하다.

또한 국세기본법 제35조 제1항이 체납처분이 일반 사채권(私債權)에 우선함을 규정하고 있지만 여기서 채권이란 금전채권에 한하는 것이고 가처분이 주로 그 대상으로 하고 있는 특정물의 인도청구권 등은 포함되지 않는다고 보아야 하는 것이므로 위 규정 또한 양자 사이의 효력관계를 결정하는 법적 근거가 될 수 없는 것이다.

이와 같이 위 국세징수법과 국세기본법의 규정 등이 체납압류의 효력 우선의 근거가 될 수 없는 한 양자 효력의 우열문제는 현행 보전처분제도와 관련하여 이론에 의해 결정할 수밖에 없는바, 명확한 법적 근거 없이 후행하는 체납처분으로써 선행하는 가처분채권자의 지위를 침해하는 것은 사법질서를 침해할 위험성이 크므로 이는 결국 일반이론에 따라 보전처분과 일반강제집행이 경합하는 경우에 있어서와 똑같은 관점에서 그 해결책을 찾아야 할 것이다.

그렇다면 일반논리에 따라 가처분권리자가 본안소송의 승패나 피보전권리의 여부와 관계없이 가처분 중인 것만을 이유로 하여 체납처분에 대하여 즉시 불복신청을 하고 그 압류를 배제할 수는 없지만, 후일 본안소송에서 승소하여 실체법상의 권리가 확정된 경우에는 그 피보전권리 여하에 의해 자기가 가지는 권리에 따라 공매처분에 의한 권리를 취득한 자에 대하여 대항할 수 있다고 보는 가처분효력유지설의 입장이 타당하다 할 것이다.¹⁵⁷⁾

우리 판례¹⁵⁸⁾ 역시 “부동산에 관하여 처분금지가처분의 등기가 된 후에 가처분권자가 본안소송에서 승소판결을 받아 확정이 되면 피보전권리의 범위 내에서 가처분 위반행위의 효력을 부정할 수 있고 이와 같은 가처분의 우선적 효력은 그 위반행위가 체납처분에 기한 것이라 하여 달리 볼 수 없다.”라고 판시하여 위 가처분효력유지설의 입장을 지지하고 있다고 보여진다.¹⁵⁹⁾

157) 유수열(주147), 299. 이하; 임용모(주101), 775. 등

158) 대법원 1993. 2. 19.자 92마903 결정

159) 그 이전에 가처분효력소멸설의 입장을 취하는 듯한 대법원 1987. 6. 23. 선고 86다카2408 판결([1] 국세체납처분은 재판상 가처분으로 인하여 그 집행에 영향을 받지 아니하는 것이므로 비록 부동산에 관한 체납처분이 처분금지 가처분보다 후에 이루어졌고 또한 그 가처분권자가 본안소송에서 승소판결을 받아 위 부동산에 관하여 가처분권자 앞으로 소유권이전등기를 경료하였다 하더라도 그 소유권이전등기가 체납처분이 이루어진 다음에 경료된 것이라면 가처분권자는 그 가처분으로써 당해 체납처분에 대하여 우선권을 주장할 수 없을 뿐만 아니라 그 가처분권자가 가처분시에 소급하여 소유권을 취득하는 것도 아니므로 그 체납처분이 제3자 소유의 재산에 대하여 이루

나. 추심 및 공탁의 문제 등

1) 가압류의 경우

가) 먼저, 채권가압류와 체납처분에 의한 압류가 중복되어 있는 때에 체납압류권자가 추심권을 행사하면 제3채무자는 이에 응하여 지급함으로써 면책될 수 있다. 만일 체납압류된 금액이 피압류채권액의 일부였다면 위 추심권 행사 이후에 남은 금액에 대해서는 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리공탁할 수 있다.

나) 체납압류권자가 추심권을 행사하지 않으면 어떻게 해야 할까. 이 경우 이를 ‘채권자가 변제를 수령할 수 없는 때’에 해당한다고 보아 제3채무자는 민법 제487조의 규정에 의해 집행채무자를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수 있다는 견해¹⁶⁰⁾가 있으나, 체납압류 후에 본압류가 있는 경우에서 살펴본 것과 같이 제3채무자는 피압류채권의 이행기가 도래하면 지체 없이 체납압류권자에게 채무이행을 해야 하고 압류채무자(체납자)를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수 없으며, 다만 체납압류권자와의 관계에서 별도의 변제공탁사유가 있을 때만 그를 피공탁자로 하는 변제공탁을 할 수 있을 뿐이라고 보아야 하므로 위 견해는 타당하지 않다.¹⁶¹⁾

다) 그리고 체납압류와 가압류집행의 경우 양 절차의 선후에 관계없이 그 집행이 피압류채권의 일부 또는 전부에서 중복되어 있다 하더라도 이는 서로 다른 절차에 기한 압류 등이 중복되어 있음에 불과하므로 압류의 경합은 발생하지 않는다.¹⁶²⁾ 따라서 구 민소법하에서라면 재판상 배당을 전제로 하는 제581조 제1항에 따른 집행공탁

어진 것으로서 당연무효라고 할 수 없다. [2] 주택임대차보호법 제3조 제2항 소정의 “양수인”은 임차주택에 관하여 소유권이전등기를 경료받아 소유권을 취득한 자를 의미하는 것이므로 갑이 을로부터 이 사건 부동산을 양도받기로 약정한 것이 임차인들의 임대차 계약체결 이전이고 또한 갑이 위 법률의 시행 전에 위 부동산에 대하여 가처분등기를 한 다음 그에 대한 본안판결에 의하여 위 부동산에 관하여 갑 앞으로 소유권이전등기를 경료한 자라 할지라도 위 부동산에 관하여 갑 명의의 소유권이전등기가 위 법률의 시행 후에 경료되었다면 갑은 위 부동산에 관한 위 법조소정의 양수인으로서 을의 위 임차인들에 대한 임대인으로서의 지위를 승계한다)이 있기는 하였다.

160) 윤경(주101), 490.; 1999. 3. 13. 법정 3302-82 질의회답 “임차보증금반환채권에 대하여 채권가압류와 국세체납처분에 의한 압류가 있는 경우에는 집행공탁의 요건인 압류경합에 해당하지 않으므로 재판상배당을 전제로 하는 민사소송법 제581조 제1항에 의한 집행공탁을 할 수는 없고, 이 경우에도 제3채무자는 변제공탁을 함으로써 이행지체의 책임을 면할 수 있을 것이다.”도 같은 취지이다.

161) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007다33842 판결

162) 윤경(주101), 490-491.; 대법원행정예규 제542호 「공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침」의 1. 다. ②항 등도 같은 취지이다(물론, 이 경우는 구 민소법하에서의 해석이었으므로 그것이 구 민소법 제581조 제1항에 따른 집행공탁에 의한 사유신고 사유가 아니라는 것으로 설명하고 있다.); 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결 참조

을 할 수 없고,¹⁶³⁾ 또한 현행 민사집행법하에서도 압류 경합을 이유로 한 제248조 제1항의 권리공탁이나 제248조 제3항의 의무공탁이 인정되지 않는다.

라) 그러나 이때에도 체납압류 후에 일반채권에 기한 압류가 있는 경우에서 본 대법원 96다5179 판결의 취지를 감안하면 법률전문가가 아닌 제3채무자 입장에서 압류 경합이 있는지 여부에 대한 판단이 곤란하다고 보이는 객관적 사정이 있다고 봄으로써 체납압류 후에 가압류가 있는 경우에는 현행법하에서 민사집행법 제248조 제1항에 따른 집행공탁(권리공탁)을 인정할 여지가 있다고 본다. 또한 가압류 이후에 체납압류가 있는 경우에는 선행 가압류채권의 불확정을 이유로 혼합공탁을 할 수도 있을 것이다(이에 대하여는 제9장 혼합공탁 제4절 Ⅲ.에서 자세히 보기로 한다).

마) 실무는 현재 가압류와 체납압류가 경합하는 경우 그 선후를 불문하고 집행공탁을 부정하는 입장이라고 보여진다.¹⁶⁴⁾ 그런데 대법원 2007. 9. 6. 선고 2007다29591 판결은 이례적으로 가압류 후에 체납압류가 있는 경우 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항, 제297조에 따라 집행공탁을 인정하는 취지로 판시하고 있다.¹⁶⁵⁾

다만 앞서 본 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결이 체납압류와 일반압류가 경합하는 경우 제3채무자에 의한 집행공탁을 전면적으로 인정하게 되었으므로 향후 실무는 오히려 기존 입장에서 볼 때 이례적이었던 위 대법원 2007다29591 판결에 따라 체납압류와 가압류가 경합하는 경우에도 제3채무자에 의한 집행공탁을 인정하는 쪽으로 운영되어질 가능성이 있어 보인다.

2) 가처분의 경우

앞서 본 가처분효력유지설에 의하더라도 승소판결에 의해 실체법상의 권리가 확정되지 않는 한 가처분만 가지고서는 체납처분에 기한 압류를 배제할 권리가 있는 것은 아니다. 따라서 제3채무자 또한 가처분을 이유로 체납압류권자에게 대항할 수 없고 피압류채권의 이행기가 도래하면 바로 조세채권자에게 채무의 이행을 하여야 한다(국세징수법 제35조 제1항 참조). 따라서 제3채무자는 조세채권자가 추심권을 행사하면 이에 응하여 지급함으로써 면책될 수 있지만, 만약 추심권을 행사하지 않는 경우라면

163) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007다33842 판결.

164) 대법원 행정예규 제542호 「공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침」참조

165) 다만 이 판례 사안의 경우 배당절차가 진행되어 확정되었고 원고는 그 배당표에 따른 배당을 받은 것으로 보이는데, 그렇다면 그 절차에서 원고가 하자를 주장하지 않았으므로 그 하자가 추인되었다고 보는 것이 앞서 본 대법원 2007. 4. 12. 선고 2004다20326 판결과 부합하는 이론적 일치를 가져오지 않았을까 싶다. 아울러 체납압류와 강제집행에 의한 압류가 경합하는 경우 그 집행공탁을 인정할 것인가의 문제는 민사집행법 전후를 비교하여 달라진 것이 아니므로 이 사건 판례가 상고논지에서 드는 민사집행법 전의 판례임을 들어 배척한 것은 적절하지 못하다고 본다.

가압류의 경우와 같이 제3채무자는 채납압류권자의 관계에서 별도의 변제공탁사유가 없는 한 변제공탁을 할 수 없고, 이는 압류 경합에도 해당하지 않으므로 재판상 배당을 전제로 하는 민사집행법 제248조 제1항에 의한 집행공탁도 할 수 없다.

그런데 처분금지가처분집행 후에 채납압류가 있는 경우에는 그 가처분의 효력에 관하여 앞서와 같이 가처분효력소멸설과 가처분효력유지설의 견해가 나타나고 있는데, 앞서 우리가 취한 가처분효력유지설을 따를 경우, 나중에 가처분채권자가 본안소송에서 승소판결을 받느냐 여부에 따라서 피압류채권의 채권자가 가처분채권자가 될 수도 있고 채납압류권자가 될 수 있는 것이므로 이는 민법 제487조 후단의 '변제자가 과실 없이 채권자를 알 수 없는 경우'에 해당한다고 볼 수 있기 때문에 제3채무자는 "가처분채권자 또는 채납압류권자"를 피공탁자로 하는 채권자(상대적) 불확지 변제공탁이 가능하다 할 것이다.¹⁶⁶⁾

이제 끝으로 입법론적으로 살펴보자면, 그 존재목적과 성질이 다른 채납처분절차와 강제집행절차를 독일의 경우와 같이 굳이 통일시킬 필요까지는 없다 할 것이나, ① 현행 국세징수법과 민사집행법을 개정하여 채납처분이 선행한 후에 강제집행절차가 개시되면 채납처분절차는 정지시키고 강제집행절차에 따르게 하거나 또는 채납처분절차를 그대로 진행시키되 그 절차에서도 채납자의 일반채권자가 배당요구 등을 하여 참가할 수 있는 구체적인 절차를 두거나 채납처분절차에서 잉여금이 발생하면 이를 일반채권자를 위하여

166) 임용모(주101), 776-777.; 대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다10079 판결, "민법 제487조 후단의 '변제자가 과실 없이 채권자를 알 수 없는 경우'라 함은 객관적으로 채권자 또는 변제수령권자가 존재하고 있으나 채무자가 선량한 관리자의 주의를 다하여도 채권자가 누구인지 알 수 없는 경우를 말하므로 양도금지 또는 제한의 특약이 있는 채권에 관하여 채권양도통지가 있었으나 그 후 양도통지의 철회 내지 무효의 주장이 있는 경우 제3채무자로서는 그 채권양도의 효력에 관하여 의문이 있어 민법 제487조 후단의 채권자 불확지를 원인으로 한 변제공탁사유가 생긴다고 할 것이고, 그 채권양도 후에 그 채권에 관하여 다수의 채권가압류 또는 압류결정이 순차 내려짐으로써 그 채권양도의 대항력이 발생하지 아니한다면 압류경합으로 인하여 민사소송법 제581조 제1항 소정의 집행공탁의 사유가 생기는 경우에 채무자는 민법 제487조 후단 및 민사소송법 제581조 제1항을 근거로 채권자 불확지를 원인으로 하는 변제공탁과 압류경합 등을 이유로 하는 집행공탁을 아울러 할 수 있고, 이러한 공탁은 변제공탁에 관련된 채권양수인에 대하여는 변제공탁으로서의 효력이 있고 집행공탁에 관련된 압류채권자 등에 대하여는 집행공탁으로서의 효력이 있다고 할 것인바(대법원 1996. 4. 26. 선고 96다2583 판결, 1999. 12. 10. 선고 99다48726 판결 등 참조), 이와 같은 경우에 채무자가 선행의 채권양도의 효력에 의문이 있고, 그 후 압류의 경합이 발생하였다는 것을 공탁원인사실로 하여 채무액을 공탁하면서 공탁서에 민사소송법 제581조 제1항만을 근거법령으로 기재하였다 하더라도, 변제공탁으로서의 효력이 발생하지 않음이 확정되지 아니하는 이상 이로써 바로 민사소송법 제581조 제1항에 의한 집행공탁으로서의 효력이 발생한다고 할 수 없으므로 집행법원은 집행공탁으로서의 공탁사유신고를 각하하거나 채무자로 하여금 민법 제487조 후단을 근거법령으로 추가하도록 공탁서를 정정하게 하고, 채권양도인과 양수인 사이에 채권양도의 효력에 관한 다툼이 확정된 후 공탁금을 출금하도록 하거나 배당절차를 실시할 수 있을 뿐, 바로 배당절차를 실시할 수는 없다고 할 것이다.

공탁하도록 하는 법규정을 마련하는 것이 필요하고, ② 강제집행절차가 선행하는 경우에도 공시제도가 마련되어 있지 않은 현실을 감안하여 조세채권자의 참가 방식을 현재처럼 교부청구 또는 참가압류에 한정할 것이 아니라 다시 체납처분에 의한 압류도 가능하지만, 그 경우에는 그 압류에 대하여 교부청구의 효력만을 인정한다는 명문의 규정을 두어 서로에 대한 참가의 범위를 넓혀주는 것이 바람직하다 할 것이다. ③ 또한 일본과 같이 양 절차의 조정을 위한 법률을 따로 마련하는 방법도 생각해보아야 할 것이다.

Ⅷ. 전부명령과 공탁

1. 전부명령에 대하여

가. 전부명령의 개념 및 요건 등

전부명령이란, 금전채권의 지급에 대신하여 압류된 채권을 채권자에게 이전하여 그 권면액으로써 집행채권을 소멸시키는 효과를 생기게 하는 집행법원의 재판을 말한다.

추심명령의 경우에는 다른 채권자로부터 압류나 배당요구가 있으면 각 채권자에게 평등하게 배당되게 되므로 신청채권자의 추심금이 적어질 우려가 있는 데 반해 전부명령은 신청채권자가 피압류채권의 대물변제를 받는 것에 의해서 독점적 만족을 얻는 제도이므로 전부명령의 효과가 생기면 이에 대해 다른 채권자가 참가할 여지가 없게 된다.

다른 한편 전부의 효과가 생기면 집행채권은 그 권면액으로 변제된 것으로 되기 때문에 제3채무자가 무자력 등인 경우에는 채권을 회수할 수 없게 될 위험도 존재하는 것이다.

이러한 전부명령을 발령하기 위해서는, ① 강제집행의 일반적 요건 및 유효한 채권압류명령이 존재할 것(전부명령도 강제집행의 일종이므로 강제집행의 요건과 강제집행개시의 요건을 모두 갖추어야 하며,¹⁶⁷⁾ 또한 전부명령이 유효하기 위해서는 우선 채권압류명령의 존재가 필요하기 때문에 압류의 대상이 되지 않는 채권에 대해서는 전부명령도 인정되지 아니한다) ② 압류채권이 전부에 적합할 것(양도성¹⁶⁸⁾이 있

167) 이러한 강제집행의 요건이나 강제집행개시의 요건을 갖추지 못한 전부명령의 효력에 대하여는 논의가 있으나, 강제집행의 요건을 갖추지 못한 경우는 별도로 하고, 강제집행개시의 요건을 갖추지 못한 경우에는 다른 강제집행의 경우와 마찬가지로 즉시항고에 의하여 취소되지 않는 한 유효하다고 보는 것이 일반적이다.

168) 당사자 사이에 양도금지의 특약이 있음에 불과한 채권에 대한 전부명령은 압류채권자가 양도금지의 특약이 있는 사실에 관하여 선의인지 악의인지를 불문하고 유효하다.

고, 권면액¹⁶⁹⁾이 있어야 한다) ③ 전부채권에 관하여 경합하는 채권자(압류, 가압류 또는 배당요구채권자)가 없을 것 등의 요건이 필요하다.

나. 전부명령의 효과

1) 전부명령의 기본적인 효력은 피전부채권의 전부채권자에게의 이전(권리이전효과)과 그로 인한 집행채권의 소멸(변제효)이다.

이러한 효력은 전부명령이 확정된 때에 발생하지만(민집 제229조 제7항), 그 확정에 의하여 발생하는 효력은 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때로 소급한다(민집 제231조).

2) 전부명령이 발령되면 그 명령은 채무자 및 제3채무자에게 송달된다(민집 제229조 제4항, 제227조 제2항). 채무자는 전부명령에 대하여 1주일 이내에 즉시항고를 할 수 있고(민집 제229조 제6항), 또한 전부명령은 확정되지 않으면 효력이 생기지 않는다(민집 제229조 제7항).

따라서 채무자가 전부명령의 송달을 받은 때로부터 1주일 이내에 즉시항고를 신청하지 않은 경우이거나 또는 즉시항고를 신청하였지만 그 즉시항고가 기각 내지 각하되어 확정된 경우에 비로소 전부명령의 그 송달시로 소급하여 생기는 것으로 되는 것이다.

그리고 전부명령의 효력은 위 요건에서 보았듯이 채권압류명령의 효력의 확정을 전제로 하고 있기 때문에, 압류명령이 확정되지 않으면 전부명령의 효력도 생기지 않

169) 권면액이라 함은 채권의 목적으로 표시되어 있는 금전의 확정된 일정액을 말하며, 그 채권의 거래의 실가(實價)를 말하는 것이 아니다. 권면액이라는 용어를 사용하지 않고 있는 현행법의 해석상 채권이 권면액을 가질 것이 전부명령의 요건인가에 관하여 논의가 있고, 이에 대해서는 이를 부정하는 견해도 없지 아니하나, 전부될 채권은 반드시 권면액을 가진 것이라야 한다는 것이 다수의 입장이다. 그러나 다수설에서도 금전채권 중 장래의 채권, 조건부채권, 반대급부에 걸린(동시이행관계에 있는) 채권 등과 같이 채권의 확정적 실현이 의문시되어 권면액의 존재를 인정하기 어려운 채권을 전부명령의 대상으로 할 수 있는 가에 대하여는 다시 견해가 나뉘어진다. 판례 중에도 전부명령의 요건으로서 권면액의 존재가 필요하다는 입장을 취한 것도 있으나(대법원 1973. 1. 24.자 72마1548 결정), 대체로 권면액에 대한 언급 없이 위 장래의 채권, 조건부채권, 반대급부에 걸린 채권의 대부분에 관하여 전부명령을 허용하고 있다(장래의 채권에 관해서는 대법원 1977. 9. 28. 선고 77다1137 판결; 대법원 1975. 7. 22. 선고 74다1840 판결; 대법원 1978. 10. 31. 선고 78다1290 판결 등, 조건부채권에 관한 것으로는 대법원 1976. 2. 24. 선고 75다1596 판결; 대법원 1978. 5. 23. 선고 78다441 판결; 대법원 1989. 11. 10. 선고 88다카19606 판결; 대법원 1981. 11. 10. 선고 81다378 판결; 대법원 1984. 6. 26.자 84마13 결정 등, 반대급부에 걸린 채권에 관하여는 대법원 1965. 4. 27. 선고 65다142 판결; 대법원 1974. 7. 23. 선고 73다245 판결; 대법원 1989. 2. 28. 선고 88다카13394 판결 등, 타인의 우선권의 목적인 채권에 대하여는 대법원 1982. 9. 23.자 82마556 결정; 대법원 1996. 1. 25.자 95마601, 602 결정 등 참조).

는 것으로 된다. 따라서 이하에서 단순히 「전부명령의 확정」이라고 하는 때에는 채권 압류명령 및 전부명령의 확정을 의미하는 것으로 한다.

3) 저당권이 있는 채권에 대하여 전부명령을 얻은 때에는 저당권이 압류채권자에 게로 이전되므로 압류채권자가 저당권자로서 저당권을 실행할 수 있다.

저당권이 있는 채권에 관하여 전부명령이 확정된 경우에는 민사집행법 제228조의 규정이 준용되므로(민집 제230조), 전부채권자의 신청에 의하여 법원사무관등은 저당권이전등기를 촉탁하여야 한다(민집규 제167조).

4) 민사집행법 제233조의 지시채권에 대한 전부명령의 효력발생시기에 관하여는 채권자가 전부명령정본에 기초하여 집행관으로부터 증권을 교부받을 때라고 하는 견해도 있으나, 그 효력발생시기는 다른 전부명령과 다를 것이 없고 증권의 채권자への 인도는 채권을 행사하는 자격의 문제에 불과하다고 보아야 할 것이다.

5) 원인채무의 이행을 위하여 제3채무자가 자기의 채권자에게 어음이나 수표를 발행교부하고 그 후에 원인채권이 압류되었는데, 그 압류 뒤에 어음금이나 수표금을 지급한 때에는 그 지급에 따라 원인채권이 소멸한 것을 압류채권자에게 대항할 수 있고, 따라서 위 원인채권을 목적으로 하는 채권압류·전부명령은 그 효력이 생기지 않게 된다.

2. 전부명령이 발하여진 경우의 공탁

가. 전부명령만 발하여진 경우

1) 먼저 전부명령이 발령되었다 하더라도 그 명령이 확정되기 전이라면 제3채무자는 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리공탁을 할 수 있다.

왜냐하면 전부명령은 유효한 압류를 전제로 하고,¹⁷⁰⁾ 그 압류의 효력은 압류명령이 제3채무자에게 송달된 시점에 이미 발생하고 있기 때문이다(민집 제227조 제3항).

따라서 전부명령이 확정될 때까지는 압류만이 존재하는 상태여서 일반원칙에 따라 위와 같이 권리공탁할 수 있는 것이다.

2) 다음으로, 전부명령이 확정되어 전부의 효과가 생긴 후에는 이미 피전부채권은 권면액으로 전부채권자에게 이전하는 것으로 되기 때문에 제3채무자로서는 채권양도의 경우와 동일하게 전부채권자에게 직접 변제를 하면 족하다(만약, 전부채권자가 그 수령

170) 채권압류명령과 전부명령은 동시에 병합하여 신청하는 것이 가능하고, 오히려 실무상 이와 같이 양자를 병합하여 신청하는 것이 대부분이며, 그리하여 동시에 그 명령이 발령되면 또한 동시에 제3채무자에게 송달된다.

을 거절하면 이를 이유로 하여 민법 제487조 전단에 따라 변제공탁을 하면 된다).

또한 전부명령의 확정에 의하여 전부채권에 대한 집행절차는 당연히 종료하고 압류의 효력도 그 목적을 달하여 소멸하므로 그에 따라 민사집행법 제248조 제1항에서 말하는 「압류에 관련된 금전채권」에 대한 집행공탁도 인정되지 않는 것으로 될 것이다.

그러나 이렇게만 해석한다면 제3채무자 입장에서 볼 때 무엇인가 불안한 면이 있어 보인다. 즉 앞서 전부명령은 채무자에게 송달되고, 채무자는 전부명령에 불복이 있는 때에는 즉시항고를 할 수 있으며, 전부명령은 확정되지 않으면 그 효력이 생기지 않는 것이라고 하였는데, 제3채무자로서는 전부명령이 언제 채무자에게 송달되었는지, 그가 즉시항고를 하였는지, 또는 이를 하지 않아 그대로 확정되었는지 등의 여부에 대하여 거의 알 수가 없는 처지에 있다. 그렇다고 제3채무자에게 자신에게 송달된 각각의 전부명령이 확정되었는가 아닌가를 조사시키거나 또는 그로 인한 위험을 부담하도록 하는 것은 가혹한 것이다.

따라서 이러한 제3채무자를 보호하는 관점에서 볼 때에 전부명령의 확정을 알 수 없는 제3채무자에게는 전부명령이 확정된 후라도 공탁서 기재상 전부명령이 확정되어 있음이 명확한 경우를 제외하고는 위 제248조 제1항에 의한 공탁을 허용하는 것이 상당하고,¹⁷¹⁾ 또한 여기서 더 나아가 공탁의 효력을 제3채무자가 전부명령의 확정을 알고 있었던가 아닌가는 주관적 사정에 관계시키는 것은 절차의 안정성을 해할 우려가 있으므로 제3채무자가 전부명령 확정 후에 민사집행법 제248조 제1항에 기초하여 공탁을 하였고, 그것이 공탁소에 의해 수리되었다면 이는 원칙적으로 유효하다고 해석하여야 할 것이다.¹⁷²⁾

그러므로 제3채무자는 전부명령 확정 후에는 직접 전부채권자에게 변제하거나 혹은 민사집행법 제248조 제1항에 따라 집행공탁도 할 수 있는 것이다.

나. 전부명령과 다른 압류명령 등이 경합하는 경우

1) 압류명령 등 이후에 전부명령이 송달된 경우

전부명령은 대물변제적 형태로 채권자의 만족을 도모하는 것이므로 동일채권을

171) 민사집행법 등의 시행에 수반한 공탁사무의 취급에 대하여(昭和 55. 9. 6. 法務省民四第 5333号民事局長通達, 第二, 四, 1.(三),(2)) “금전채권에 대하여 압류명령 및 전부명령이 발령된 경우에 있어서, 제3채무자로부터 제248조 제1항 또는 제2항의 규정을 근거로 하여, 압류에 관련된 금전채권의 전액 또는 압류금액에 상당하는 금전의 공탁신청이 있는 때에는 공탁서의 기재상 전부명령이 확정되어 있는 것이 명확한 경우를 제외하고, 이것을 수리하는데 지장이 없다.”

172) 稻葉威雄, “민사집행법における供託(一)”, 金融法務事情 930号, 9.

둘러싸고 다른 채권자가 경합하는 때에는 1인의 채권자에게 독점적인 만족을 부여하기 위한 전부명령은 허용되지 않는다.

따라서 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 피전부채권에 대하여 다른 채권자에 의한 압류명령, 가압류명령 또는 배당요구의 송달이 있었던 때에는 전부명령의 효력은 생기지 않는 것으로 된다(민집 제229조 제5항).

이 경우는 선행하는 압류 등과 전부명령의 전제가 되는 압류만이 경합하는 것으로 되기 때문에 제3채무자로서는 민사집행법 제248조 제1항 내지 제3항을 근거로 공탁을 할 수 있게 된다.

만약 선행하는 압류가 채납처분에 의한 것이라면 압류의 경합은 아니지만 앞서 본 바 있는 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결의 취지에 따라 제3채무자는 민사집행법 제248조 제1항에 의한 공탁을 할 수 있을 것이다.

2) 전부명령 후에 압류명령 등이 송달된 경우

위와 달리, 전부명령이 제3채무자에게 송달된 후에 다른 채권자의 (가)압류명령 또는 배당요구가 있어도 그 후 전부명령이 확정되면 제3채무자에게 송달된 시점에 소급하여 채권이전의 효력이 생기므로 그 후의 압류 등은 이른바 「압류의 무위(押留의 無爲)」상태가 되어 무시되고 전부명령은 유효하게 확정된다.

그러므로 전부명령 송달 후 압류명령 등이 송달되고 그 후 전부명령이 확정된 경우에는 제3채무자는 전부채권자에 대하여 직접 변제하든가 또는 그가 수령을 거절하면 이를 이유로 민법 제487조 전단에 따라 변제공탁을 하면 된다.

다만 이 경우도 전부명령 송달 후 다시 다른 압류명령이 송달된 상태에서 제3채무자로서는 앞서 된 전부명령이 확정되었는지 여부를 통상 알기 어려우므로 이러한 제3채무자 보호의 관점에서 여기서도 제3채무자에게 민사집행법 제248조 제1항에 의한 공탁을 인정하는 것이 상당하다고 본다.

다. 전부명령과 전부명령이 경합하는 경우

전부명령과 전부명령이 경합하는 경우 후의 전부명령은 다른 채권자가 압류한 다음의 전부명령으로서 그 효력이 생기지 않기 때문에 전부명령 후에 다른 압류명령 등이 송달된 경우와 동일한 상황이 되고 만다.

따라서 앞의 전부명령이 확정되어 있는 것이 공탁서의 기재 등으로부터 명확하지 않는 한 제3채무자는 민사집행법 제248조에 따라 공탁할 수 있을 것이다.

라. 압류명령 등과 우선권에 기초한 전부명령이 경합하는 경우

전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 전부명령에 관계된 금전채권에 대하여 다른 채권자가 압류 등을 한 경우에는 그 전부명령의 효력이 생기지 않는 것이지만(민집 제229조 제5항), 그 전부명령을 얻은 것이 질권 등의 우선권을 가진 채권자인 경우에는 그 전부명령은 유효하다.¹⁷³⁾

왜냐하면 일반채권에 기초하여 압류명령 후에 피압류채권에 대하여 우선채권에 기초한 전부명령이 송달된 경우 실체법상은 후의 전부채권자가 일반채권자에 우선하여 변제받는 것으로 되고, 양 채권자 사이에서는 공탁을 거쳐 평등하게 배당받아야 된다는 등의 실질적인 경합이 존재하지 않기 때문이다.

따라서 채권압류명령 및 전부명령이 우선권에 기초하여 송달된 경우에는 그 전에 다른 압류명령 등이 송달되어 있었다라도 제3채무자로서는 위 전부명령이 확정되면 전부채권자에게 직접 변제하면 족하다.

그런데 이 경우도 전부명령이 송달된 채권에 대하여 그것이 우선권 있는 채권인지 아닌지에 대하여는 일반 제3채무자가 알지 못하는 경우가 많고, 또 제3채무자로 하여금 그 우선권 유무에 대하여 정확한 판단을 내리도록 기대하기란 어렵다. 이러한 의미에서 이 경우도 제3채무자가 민사집행법 제248조에 따라 공탁하는 것을 인정해야 한다고 본다.

그리고 이러한 해석은 우선권에 기초한 전부명령 이후에 일반채권에 기한 압류명령 등이 송달된 경우에 관해서도 동일하게 적용되어질 수 있다.

3. 공탁금의 지급절차

가. 전부금액에 상당한 부분

1) 전부명령만이 발령된 경우 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁을 하였다면 집행법원은 그 전부명령의 확정 유무에 불구하고 바로 전부채권자에 대하여 지급위탁을 할 수 있다.

왜냐하면 제3채무자가 위와 같이 공탁한 때 또는 사유신고를 한 때에 배당가입 차단효가 발생하고(민집 제247조 제1항 등 참조), 전부채권자는 이에 따라 공탁금으로부터 독점적인 만족을 받을 수 있으며, 다시 위 전부명령의 효력을 다룰 실익이 존재하지 않기 때문이다.

173) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 489.

그리고 제3채무자가 위와 같이 공탁한 이후에 그 전부명령이 확정되었다면 실체적으로는 전부의 효력이 발생된 시점에 압류채권자 및 채무자 사이의 채권채무관계는 전부의 효과가 발생한 한도에서 결제되고, 압류된 채권은 법률상 당연히 집행채무자로부터 전부채권자에게 이전되므로 그 시점에서 집행절차는 당연히 종료된다.

따라서 집행법원으로서의 전부채권자로 하여금 압류 및 전부명령의 확정증명서를 제출케 한 다음 그 공탁금에 대하여 배당 또는 변제금교부절차¹⁷⁴⁾를 거칠 필요도 없이 바로 그에게 지급위탁절차를 취하는 것이 가능하다고 본다.

2) 또한 전부명령과 다른 압류명령 등이 경합한 경우라도 전부명령이 우선권이 기초한 것이거나 혹은 전부명령 후에 압류명령 등이 송달되고 그 후 전부명령이 확정되어 위 다른 압류명령 등이 무시되거나 하여 실체법적으로 전부명령 확정시에 피압류채권이 전부채권자에게 이전된 것이 기록상 명확한 경우에는 집행법원은 제3채무자가 압류의 경합을 이유로 민사집행법 248에 따라 공탁을 하였더라도 전부채권자로 하여금 압류 및 전부명령의 확정증명서를 제출케 한 다음 바로 전부채권자를 위한 지급위탁절차를 취할 수 있다 할 것이다.

다만 집행법원이 전부명령의 효력에 의심이 있다고 판단된 경우에는 배당절차를 진행시키고 그에 대해 전부명령의 효력을 주장하는 자가 배당이익을 하여 그 소송에서 전부명령에 관계된 채권에 관해 우선배당을 주장할 수 있도록 함이 타당하다.

그러나 이 경우 전부명령이 아직 미확정이어서 그 유효, 무효가 결정되지 않으

174) 변제금교부절차란, ① 배당을 받을 채권자가 1인인 때 ② 채권자가 2인 이상이지만 배당재단으로 절차비용과 각 채권자의 압류명령에 기재된 채권액의 전부를 변제할 수 있는 경우, ③ 1인의 채권자가 복수의 집행권원 혹은 동일한 집행권원으로 동일 채권을 수회 압류한 경우 등에 행해지는 절차를 말한다. 이 절차는 변제금교부기일을 지정하여(이는 「송달」이라는 절차를 취하는 배당절차와 달리 「통지」와 같이 상당하다고 인정될 수 있는 간략한 방법으로 행해진다), 배당표 대신에 변제금교부계산서를 작성하고, 변제금을 채권자에게 교부하며, 그 다음에 잉여금이 존재하면 이를 채무자에게 교부하는 간략한 절차이다(이러한 교부절차는 대부분 피압류채권으로 채권자들의 채권을 모두 만족시킬 수 있는 등 그 이해 대립이 없는 경우에 인정되므로 이 절차에 따를 경우 원칙적으로 채권자들의 배당이익도 인정하지 않게 된다). 그러나 현재의 실무는 위 ①의 경우에는 간단하게 당해 채권자에 대하여 지급위탁을 하는 방법을 취하고 있고, 위 ②③의 경우에는 모두 배당기일을 지정하고 배당표를 작성하는 등 배당절차로써 이를 진행하고 있다. 그러나 위 ②③의 경우에도 채권자 사이에 이해관계의 충돌이 없는 경우에는 엄격하고 시간이 많이 걸리는 배당절차보다 교부절차에 의하는 것도 한번 고려해볼만 한 일이라고 생각한다[위 법원실무자료 민사집행(Ⅲ), 494-495, 참조]. 또한 압류가 경합하고 있으나, 채권자들의 집행채권의 합계액이 피압류채권과 동일한 경우에 이를 배당절차로 진행할 것인지 아니면 변제금교부절차에 의해서도 가능한 것인지가 문제되나, 이 경우는 배당절차로 진행함이 바람직할 것이다. 이러한 변제금교부절차와 배당절차를 합하여 흔히 「배당등 절차」라고 부르고 있다.

면 배당등을 실시할 요건이 구비되지 않았기 때문에 집행법원으로서 그 확정을 기다려 절차를 진행시켜야 할 것이다.

압류명령 등의 송달 후에 일반채권에 기한 전부명령이 송달된 때에는 전부의 효과가 생기지 않기 때문에 집행법원은 압류의 경합으로서 배당절차를 진행하게 된다.

나. 전부금액을 초과하는 부분

금전채권의 일부에 전부명령이 발하여진 경우에 그 전액에 상당하는 금전이 공탁된 때의 전부금액을 초과한 부분의 취급은, 금전채권의 일부가 압류되어 그 전액에 상당하는 금전이 공탁된 경우의 취급과 동일하다.

즉 공탁금 속에 전부금액을 초과한 부분에 대하여 채무자는 공탁을 수락하여 출급청구를 할 수가 있고, 제3채무자는 공탁불수락을 원인으로 하여 회수청구를 할 수가 있는데, 이러한 회수청구에는 집행법원으로부터 공탁서를 보관하고 있다는 사실을 증명하는 서면을 교부받아 이를 공탁금회수청구서에 첨부하여야 한다.

IX. 제3채무자 공탁의 효과

1. 채무변제의 효과

제3채무자가 민사집행법 제248조에 의해 공탁을 하게 되면 그는 그 기본적인 효과로서 채무자에 대한 채무를 면하게 되고, 그에 따라 피압류채권이 소멸한다.¹⁷⁵⁾

앞서 제3채무자의 공탁제도의 존재이유에서 보았듯이, 채무자(제3채무자)에게 곧바로 채권자(채무자)에 대한 변제를 시키는 것이 적당하지 않은 경우에 변제의 목적물을 확실하게 보관하기 위한 제도로서 공탁제도를 마련하고, 제3채무자에 대하여 변제에 대신하여 금전을 제공시키는 경우에 위 공탁제도를 이용케 함으로써 제3채무자의 면책방법을 도모하고 있는 것이 바로 이 제3채무자 공탁 규정이기 때문이다.

제3채무자가 채무 전액을 공탁하지 않아 집행공탁의 효력이 인정되지 않는 공탁금에 대하여 배당절차가 종료된 경우, 그 공탁금에 대하여 변제의 효력이 인정된다.¹⁷⁶⁾

175) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 354.; 대법원 2019. 1. 31. 선고 2015다26009 판결

176) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다41443 판결; 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012다91385 판결

2. 압류명령의 취하 또는 취소의 불가

채권자가 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류한 상태에서 제3채무자가 민사집행법 제248조에 따라 공탁을 하게 되면, 위 압류명령은 위 공탁에 의한 목적달성으로 인하여 그 존재의의를 잃고 장래에 향하여 소멸하게 된다(압류명령으로 인한 집행이 종료됨).¹⁷⁷⁾ ¹⁷⁸⁾

따라서 위 공탁 이후에는 채권자는 위 압류명령을 취하할 수 없고, 설사 취하한다고 하더라도 이는 단지 그 후에 진행되는 배당등 절차에서의 배당수령권을 포기하는 의사라고 해석될 뿐 위 압류명령 자체의 효력에 영향을 주지 않게 된다.¹⁷⁹⁾

또한 위 공탁 이후에는 위 압류채권자의 지위가 배당등을 받을 채권자로 전화(轉化)되는 것이므로(민집 제252조 참조, 아래에서 다시 보게 되는 배당가입의 차단효 발생),¹⁸⁰⁾ 위 압류명령이 취소되더라도 그것 때문에 이미 발생한 위 압류명령의 효력이나 또는 공탁으로 인해 생긴 배당가입의 차단효가 소급적으로 복멸(覆滅)되는 것이 아니며, 오히려 그 효과는 다른 채권자들과의 사이에서 의연히 남아있게 된다고 보아야 한다.

그러므로 그 이후에 압류채권자가 압류명령을 취하하거나 또는 취소한다고 해도 그것이 압류명령의 효력을 소급적으로 변화 또는 소멸시키는 것은 아니며, 이는 배당수령권 여하의 문제로만 남게 되는 것이다.¹⁸¹⁾

계속적 수입채권의 경우에 아직 채권의 만족을 얻지 못한 상태에서 어느 채권자가 압류명령을 취하하였다면 아직 공탁되지 않은 부분에 대하여는 그 취하의 효력이 인정될 것이지만, 이미 공탁된 부분에 대하여는 취하가 인정되지 않고 다만 배당수령권을 포기하는 의사로 해석해야 할 것이다.

3. 배당가입차단효의 발생

가. 배당가입의 차단효란, 그 말 그대로 배당등에 가입하는 것이 차단되는 효력을 말한다. 이것이 무슨 말인가 하면, 예를 들어 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 채

177) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013다207774 판결

178) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 786.

179) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355-356.; 吉野衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 830.

180) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013다207774 판결; 대법원 2019. 1. 31. 선고 2015다26009 판결

181) 吉野衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 830. 참조

권자 甲이 압류한 경우에 또 다른 채권자가 과연 어느 때까지 그 채권에 대해 압류, 가압류 또는 배당요구를 하면 위 甲과 동일하게(채권자평등주의) 그 이후에 집행법원에 의해 행해지는 배당등 절차에서 배당등을 받을 채권자로 취급될 수 있을 것인가라는 문제인 것이다.

즉 배당가입차단효란 당해 배당등 절차에서 배당등을 받을 수 있는 채권자의 범위를 확정하기 위하여 필요한 개념이다(따라서 이 개념은 채권집행절차 전 부분에 걸쳐 상당히 중요한 의의를 가지는 것이다).

나. 집행공탁이 된 돈에 대하여 배당가입의 차단효가 발생하지 않는다면 그 공탁금을 대상으로 한 배당등 절차는 개시될 수도 없고 또한 개시해서도 안 된다. 집행공탁에 있어서 만약에 배당가입의 차단효란 개념을 상정하지 않는다면 당해 배당등 절차에서 배당을 받을 채권자를 특정할 수가 없게 되기 때문에 집행법원으로서 누구를 상대로 배당등 절차를 진행해야 되는지 확정할 수 없게 되는 것이다.

다. 이에 관하여, 일본 민사집행법은 제165조에서 “배당등을 받을 채권자의 범위”란 제목하에 “배당등을 받을 채권자는, 다음의 시기까지 압류, 가압류의 집행 또는 배당요구를 한 채권자로 한다.(제1호) 제3채무자가 제156조 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 공탁을 한 때,(제2호) 추심소송의 소장이 제3채무자에게 송달된 때,(제3호) 매각명령에 의해 집행관이 매득금의 교부를 받은 때,(제4호) 동산인도청구권 압류의 경합에 있어서는 집행관이 그 동산의 인도를 받은 때”라고 규정하고 있다. 즉 제3채무자에 의한 공탁의 경우에는 그 공탁시까지 피압류채권에 대하여 압류, 가압류 또는 배당요구를 한 채권자만이 당해 배당등 절차에 참가할 수 있다는 것이다.

라. 그러면, 우선 다른 경우¹⁸²⁾는 제외하고, 우리 집행법에 있어서 제3채무자가 민사집행법 제248조에 따라 공탁한 경우에 배당가입의 차단효는 언제 발생한다고 보아야 할까(이는 예를 들어, 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 甲이 압류한 경우 乙의 다른 채권자인 丁은 甲이 압류한 위 채권에 대해 언제까지 압류집행을 해야만 당해 배당등 절차에 참가할 수 있는지 여부에 관한 문제이다).

1) 우리 집행법에도 이러한 점을 고려하였다고 보이는 규정이 있는데, 그것은 민사집행법 제247조로서, 이는 그 조문에 규정한 배당요구채권자는(제3채무자의 공탁만

182) 압류채권자에 의한 추심의 경우, 매각명령을 발부받은 경우 등 다른 경우에 대하여는 제10장 배당등 절차 제6절 II. 이하에서 다시 자세히 보기로 한다.

을 말할 때) 제3채무자가 공탁을 한 후 민집 제248조 제4항에 따라 사유신고를 한 때까지 배당요구를 할 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 우리 집행법은 압류 또는 가압류채권자가 당해 배당등 절차에 가입하기 위해 언제까지 압류 또는 가압류를 해야 하는가라는 문제에 대하여는 명문의 규정이 없다.

2) 현재 간혹 다른 이론서들을 보면 압류 또는 가압류채권자들의 배당요구의 종기(이는 아마도 배당가입의 차단효 발생시기를 말하고 있는 듯 하다)가 위 민사집행법 제247조에 따라 제3채무자의 공탁 후 사유신고시까지라고 설명을 하는 견해¹⁸³⁾들이 종종 보이고 있으나, 이러한 견해들은 다음과 같은 이유로 정확한 설명이 될 수 없다.

첫째로, 위 규정은 명백히, “민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자와 집행력 있는 정본을 가진 채권자(이하, 이를 전부 지칭할 경우 배당요구채권자라고 한다)는 다음 각 호의 시기까지 법원에 「배당요구」를 할 수 있다.”라고 규정하고 있을 뿐이다.

압류된 채권에 대하여 다른 채권자가 동일 채권을 목적으로 강제집행에 참가할 수 있는 방법은 이중압류(또는 가압류)를 하거나 혹은 그 압류명령에 대하여 배당요구를 하는 2가지 방법(이로써 집행이 경합하게 된다)이 있는데, 위 제247조가 규정하는 것은 채권자가 후자인 배당요구의 방법으로 배당등의 집행절차에 가입할 수 있음과 그것으로써 가입하려면 언제까지 해야 한다는 것을 규정하고 있는 것에 불과하다.

또한 압류 등이 경합하는 경우에 있어서 후행 압류에 배당요구의 효력을 인정하거나 또는 모든 압류 등에 배당요구의 효력을 인정하는 것과 위 제247조가 규정하는 배당요구는 서로 다른 개념이다. 압류와 배당요구는 신청방식이 다르고, 그로 인한 효력발생시기 또한 다르며 집행개시요건이 필요한지, 또 그것으로 인하여 집행법상의 구속력이 발생하는지 등에 관하여 배당요구에는 이러한 효력이 없다는 것이 일반적 견해를 차지하고 있는바(이것에 관한 자세한 논의는 제6장 집행의 경합 제2절 배당요구 이하 참조), 이와 같이 압류 또는 가압류 등과 전혀 다른 집행방법으로서, 명문으로 「배당요구」란 제목하에 배당요구채권자의 집행절차 가입방법만을 규정한 위 제247조가, 압류 또는 가압류에도 적용된다고 해석하는 것은 타당하지 못한

183) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 422도 이러한 견지에서 “배당요구의 종기(민집 제247조 제1항) 이후에 후행의 압류가 이루어진 때에는 그 압류채권자는 선행압류에 의한 배당절차에 가입하지 못하므로 압류의 경합은 생기지 않는다.”라고 설명하고 있다.

것이다.¹⁸⁴⁾

둘째로, 앞서 본 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 甲이 압류하였다는 것을 다시 예로 들 경우, 이때에 제3채무자인 甲이 제248조 제1항에 따라 채무액을 공탁하면 그로 인해 여러 가지 법률효과가 발생하게 되지만, 우선 위 공탁으로 인하여 제3채무자에게 생기는 법률효과를 본다면, 위와 같은 공탁이 있게 되면 앞서 보았듯이 제3채무자인 丙의 乙에 대한 채무는 소멸하게 된다(피압류채권의 소멸).¹⁸⁵⁾

이는 압류의 기본적인 가장 중요한 효력인 지급금지효력을 위반하지 않고도 실제 변제의 효력을 가져오게 하고 있으며, 이로써 제3채무자는 자신의 채무자에 대한 채무를 면함과 동시에 자신의 의사와 관계없이 얽혀진 채권자와 채무자 사이의 법률관계로부터 벗어날 수 있게 되는 것이다.

3) 이와 같이 피압류채권이 소멸한 상황에서 다른 채권자 丁이 乙에 대한 채권을 가지고 乙이 丙에 대하여 가지는 위 피압류채권을 다시 압류했다고 가정해보자. 丁의 압류의 효력은 어떻게 될 것인가.

丁의 압류명령은 공탁에 의해 이미 피압류채권이 소멸한 채권에 대해 발부된 것이고, 이와 같이 피압류채권이 존재하지 않는 채권에 대하여 발부된 압류명령은 실체 상 그 효력이 생기지 않는다는 의미에서 무효라고 해석되고 있다.¹⁸⁶⁾

그런데 적어도 배당등 절차에 가입하여 배당을 받으려면 압류 또는 가압류가 유효해야 할 것인바, 이러한 효력이 없는 압류명령을 발부받은 丁은 무효인 압류를 한 자이므로 그를 이후의 배당등 절차에 가입시키는 등으로 권리행사의 기회를 줄 수가 없는 것이다.

4) 바로 여기에서 압류 또는 가압류의 경우 배당가입차단효의 발생시기에 관한 결론이 나오게 된다. 즉 압류 또는 가압류채권자의 경우 압류된 채권에 대해 제3채무자가 제248조에 따라 공탁할 때까지 압류 또는 가압류 집행을 하지 않으면 당해 집행법원이 행하는 배당등 절차에 가입할 수 없다는 것이고, 따라서 압류 또는 가압류채권자의 경우 배당가입의 차단효는 제3채무자에 의한 (집행)공탁시에 발생한다고 보

184) 이는 부동산경매에 있어서 경매개시결정에 의한 이중압류와 단지 배당요구만 하는 것이 서로 다르다는 것을 생각해보아도 명백한 것이다. 이 경우도 전자에 대해 선행 경매에 대한 배당요구의 효력을 인정하고 있지만, 이 역시 그 자체 배당요구가 아닌 압류의 신청이므로 강제집행을 위한 요건 등 경매신청에 필요한 요건을 모두 갖추어야 하는 것이다.

185) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013다207774 판결; 대법원 2019. 1. 31. 선고 2015다26009 판결

186) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 197.

아야 하는 것이다.

마. 다음으로, 민사집행법 제247조가 규정하는 배당요구채권자의 경우에 관하여 보기로 한다(이는 예컨대, 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 甲이 압류한 경우 乙의 다른 채권자인 丁은 언제까지 배당요구의 방법으로 위 절차에 참가하여 배당을 받을 수 있는지의 문제이다).

1) 배당요구란, 먼저 강제집행에 착수한 채권자가 있는 경우에 다른 채권자가 그 강제집행절차에서 동일한 재산으로부터 평등한 비율로 변제를 받으려고 하는 일종의 집행행위(집행신청)를 말한다(제6장 집행의 경합 중 제2절 배당요구 참조).

이러한 배당요구는 독립적으로 강제집행을 수행하겠다는 것이 아니라 다른 채권자의 강제집행절차에 “편승”한다는 점에서 부종적(附從的)인 성질을 가지고 있고, 또 배당요구는 원칙적으로 독자적인 절차수행의 권능이 없으며, 집행법상의 구속을 발생 시키기도 않기 때문에 그 요건도 압류 등 신청의 요건보다도 완화되어 있을 뿐 아니라 집행개시요건의 구비도 필요하지 않다고 해석되고 있다.

그리하여, 이러한 성질 때문에 배당요구는 그 기초가 된 압류가 취소되거나 압류채권자가 신청을 취하한 때에는 그 효력을 상실하게 된다.¹⁸⁷⁾

2) 여기서 잠시 부동산집행의 경우를 보기로 한다. 부동산집행의 경우에는 언제까지 배당요구를 할 수 있는 것인가.

현재의 법규정(민집 제84조, 집행법원이 배당요구의 종기를 결정하여 그때까지 하도록 규정하고 있음)을 떠나 순전히 법이론적으로만 본다면 압류가 아직 효력을 가지고 있는 대금납부시까지 가능하다고 보아야 할 것이다. 이는 대금납부 전이라면 경매개시결정에 의한 압류는 여전히 효력을 가지고 있으므로 그 압류의 유효한 존재를 전제로 하는 배당요구는 대금납부 전에는 이를 할 수 있다는 것이다(개별상대효설). 하지만 대금납부를 하게 되면 그 납부금은 법원보관금으로서 배당재단을 이루고, 개시결정에 의한 압류는 그 목적을 달성하고 소멸하게 되며, 압류채권자는 그 지위가 배당을 받을 채권자로 바뀌게 된다. 그리하여 대금납부 후에는 그 압류가 유효함을 이유로 하는 취하나 또는 취소를 할 수가 없게 되고, 설사 그러한 취하 등을 한다고 해도 이는 배당수령권을 포기하는 의사표시가 될 뿐 압류의 효력을 소급적으로 복멸 시키지는 못하게 되며, 또한 대금납부 이후에는 법이론적으로도 그 압류가 유효하게 존재하지 않으므로 이를 전제로 하는 배당요구 또한 할 수 없게 된다(다만 우리 집행

187) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 432.

법은 이미 알고 있듯이 구 민소법하에서는 낙찰허가시까지 배당요구를 가능하게 하다가 현행 민사집행법은 이를 더 앞당겨서 매각이전으로 결정된 배당요구종기까지만 배당요구를 할 수 있도록 하고 있다).

3) 이제 채권집행에 돌아와서 보면, 제3채무자가 민사집행법 제248조에 따라 행하는 공탁은 위 부동산집행에서의 대금납부와 거의 같은 성격을 가지고 있다. 그 공탁이 이루어지면 그 공탁금은 채권배당에 있어서의 배당재단을 이루게 되는데, 다만 그 공탁금은 공탁소에 맡겨지므로 그것이 배당재단을 이루게 되었다는 사실을 집행법원이 인식할 수 있도록 하기 위해서 사유신고란 절차(물론 이 경우 사유신고는 이러한 인식의 목적 이외에도 집행법원으로 하여금 권리자를 확정시키는 절차를 진행해달라는 요청의 의미도 포함하고 있기는 하다)를 두고 있으며, 사유신고 뒤에도 집행법원이 이를 관리하기는 하지만 여전히 공탁소에 이를 맡겨서 관리하게 된다. 또 이후 권리자가 확정된 이후에도 출급명령이 아니라 공탁관에 대해 지급위탁하는 방법으로 채권자에게 공탁금을 지급하게 되어 있다.

4) 그리고 이와 같이 채권집행에서 민사집행법 제248조에 따른 제3채무자의 공탁이 있게 되면 앞서 본 부동산집행에 있어서의 대금납부의 경우와 같이 압류명령은 목적을 달성하여 그 존재의의를 잃고 장래에 향하여 소멸하게 된다.¹⁸⁸⁾

5) 또한 압류채권자는 공탁에 의해 개시된 배당등 절차에서 배당등을 받을 수 있는 채권자로 그 지위가 바뀌게 되는 것이어서 이 경우도 압류채권자는 당해 압류명령을 취하하거나 취소할 수 없게 되고, 설령 제3채무자가(집행)공탁한 이후에 압류명령을 취하하였더라도 이는 단지 배당수령권의 포기라고 해석되는 것일 뿐 압류 자체의 효력에 영향을 주지 않는다.¹⁸⁹⁾ 나아가 공탁 이후 위 압류명령이 취소되더라도 그 때문에 이미 발생한 위 압류명령의 효력이나 또는 공탁으로 인해 생긴 배당가입의 차단효가 소급적으로 복멸(覆滅)되는 것이 아니며, 오히려 그 효과는 다른 채권자들과의 사이에서 의연히 남아있게 된다고 보아야 한다.¹⁹⁰⁾

188) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 786.

189) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355-356.; 吉野衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 830.

190) 吉野衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 830. 참조; 이렇게 볼 경우, 압류명령의 처분금지효에 대한 절차상대효설(이 설은 최초 압류명령에 의한 처분금지의 효력이 그 집행절차에 참여하는 다른 채권자를 위해서도 발생하는 것, 즉 최초의 압류채권자는 그 뒤에 가입해 올 다른 채권자를 위해서도 압류한 것으로 생각하여 이 경우 최초 압류명령 이후의 양수인의 권리는 전 채권자와의 관계에서 무시되는 것으로 해석하므로 채권양도 이후의 다른 채권자에 의한 배당요구가 인정될 수 있다. 다만 선행 압류 후에 피압류채권에 대하여 다른 채권자가 다시 압류를 행한 경우 후행 압류채권자는 선행 압류에 의한 처분금지효력을 원용할 수 있는 입장은 아니고 따라서 선행 압류 후

6) 이러한 현상은 전부명령이 확정된 경우에도 비슷하게 나타나게 된다. 즉 위의 예에서 압류채권자가 전부명령을 받아 그 전부명령이 확정되게 되면 압류명령은 목적을 달성하여 소멸하게 되기 때문에 전부명령 확정 후에는 전부명령뿐만 아니라 압류명령 자체도 취하 또는 취소할 수 없으며, 위 압류명령이 유효함을 전제로 하는 배당요구도 할 수 없게 된다.¹⁹¹⁾ 그리고 저당권부채권을 압류한 채권자가 나중에 전부명령을 받아 그것이 확정되게 되면 당해 저당권에 대한 이전등기를 신청할 수 있는데, 이때에 법원은 그 이전등기촉탁을 하면서 동시에 이미 행해진 압류등기의 말소촉탁도 하게 되는데,¹⁹²⁾ 이 또한 전부명령이 확정되면 압류명령이 그 목적을 달성하고 소멸하게 되기 때문이다.

7) 그러므로 결론적으로 민사집행법 제247조가 규정하는 배당요구는 압류의 효력이 유효하게 존재하고 있을 때에 가능하다고 보아야 하는 것이다.

8) 그런데 우리 민사집행법은 위 제3채무자의 공탁 후 사유신고시까지 배당요구가 가능하다고 규정하고 있는바, 이는 마치 부동산집행의 경우라면 대금납부 이후에도 다른 채권자에 의한 배당요구가 가능하다고 하는 것과 같기 때문에 이론상으로 보면 적절한 입법례는 아니라고 생각된다(우리 통설, 판례가 취하는 개별상대효설의 입장에서 보아도 타당하지 않다).

9) 하지만 법이론을 떠나 입법적으로 그와 같이 규정하고 있으니, 그에 맞추어 해석론을 전개할 수밖에 없을 것이다(다만 현재 채권집행실무의 경우 민사집행법 제247조에 따른 배당요구는 거의 없는 점, 제3채무자의 공탁과 그 사유신고는 거의 동시에 이루어지는 점 등에 비추어 생각하면 위 규정이 비록 법이론과 약간 괴리가 있

에 피압류채권에 대해 변제, 면제, 채권양도 등의 사유가 생겨 후행 압류시점에서 볼 때 당해 채권이 채무자의 재산에 귀속되어 있지 아니한 경우에는 후행 압류는 목적물의 흠결로 인해 무효가 된다. 이러한 채권양도 등 이후의 다른 압류, 가압류 등에 대하여 배당요구의 효력을 인정할 것인가에 대하여는 견해가 나뉘고 있다)에 의하면 여전히 선행 압류 이후의 채권양도는 효력을 발휘하지 못하고, 다만 채권양도 이후에 가압류 또는 압류채권자가 있으면 그러한 자들을 위해 배당등 절차를 실시하는 것으로 될 것이나, 개별상대효설(우리나라 통설, 판례의 입장인 이 설에 의하면 가압류 이후의 양수인은 선행하는 가압류채권자에게는 대항할 수 없으나, 그 밖의 다른 후행하는 채권자와의 관계에서는 선행 압류에 의한 처분제한의 효과에 제한받지 않고 양도로서 그 다른 채권자에게 대항할 수 있다고 본다. 따라서 이 설에 의하면 채권양도 이후의 압류, 가압류는 효력이 없고, 그에 대해 배당요구의 효력도 인정할 여지가 없으며, 다른 채권자가 선행 압류에 대해 배당요구할 수도 없게 된다)에 의하면 위와 같은 위 채권양도도 여전히 그 효력을 발휘하지 못하고 또한 채권양도 이후의 가압류 또는 압류채권자 역시 위 채권양도로 인해 효력이 없는 이상 결국 위 공탁으로 인한 채무액은 채무자에게 환급되는 결과가 될 수밖에 없다.

191) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 407.

192) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 407.

다 하더라도 실무에 있어서 실제로 문제가 생길 여지는 그리 많지 않을 것이다).

바. 이상의 논의에 비추어 보면, 우리 집행법의 경우 채권집행에 있어서 배당가입의 차단효의 발생시기는 압류 또는 가압류의 경우에는 제3채무자가 공탁한 때, 그리고 배당요구의 경우에는 제3채무자가 공탁 후 사유신고를 한 때(민집 제247조)라고 보아야 할 것인데, 이것은 배당가입차단효 발생시기를 제3채무자의 공탁시로 동일하게 규정하고 있는 일본 집행법과 다른 점이기도 한 것이다.

다만 제3채무자의 공탁 이전에 압류명령의 신청을 하였으나 제3채무자가 공탁한 이후에 그 압류명령이 제3채무자에게 송달된 경우(위에서 본 이유대로 압류명령으로서는 효력이 없음) 또는 제3채무자 공탁 이후 사유신고 이전(민집 제247조 제1항 제1호에 따른 배당요구의 종기 이전)에 압류명령의 신청을 한 경우 등에는 위와 같은 압류명령에 대하여 무효행위의 전환 이론에 따라 배당요구로서의 효력을 인정할 수 있으므로 위 압류채권자는 압류채권자로서가 아니라 배당요구채권자로서 당해 배당등에 가입할 수 있는 여지가 있어서 다투어지고 있는바, 이에 대하여는 이미 제6장 집행의 경합 제2절 V. 1. 나. 2)에서 자세히 다루었다.

사. 이제 이에서 더 나아가 가압류된 채권의 배당가입의 차단효에 관하여 살펴보기로 하자(이는 예컨대, 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 乙의 채권자 甲이 가압류집행한 경우 乙의 다른 채권자 丁은 언제까지 압류집행을 해야만 당해 배당등 절차에 참여할 수 있는지 여부에 관한 문제이다).

1) 이는 예컨대, 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 甲이 가압류한 경우에 제3채무자인 丙이 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따라 집행공탁을 하여 채무를 면한 경우에 압류된 채권의 경우와 같이 그 공탁시에 배당가입의 차단효가 발생한다고 볼 것인가에 관한 문제이다.

2) 그러나 가압류된 채권에 대해 가압류집행을 원인으로 하는 공탁은 원래의 채권자인 가압류채무자를 피공탁자로 하는 일종의 변제공탁일 뿐이고, 그 가압류채권자가 가지는 공탁금출급청구권 위에 가압류집행의 효력이 이행하는 것이라고 보고 있으므로(민집 제297조), 그 공탁금으로부터 배당등을 받을 수 있는 채권자의 범위를 확정하는 효과를 가지지 않고 배당등 절차를 개시하는 사유도 되지 못하기 때문에 제3채무자의 공탁에 의해서는 배당가입차단효가 발생하지 않는다(이는 단지 제3채무자가 일반의 제3자로부터 공탁관으로 바뀐 채 가압류의 효력이 채무자가 가지는 공탁금출급청구권에 대해 미치는 것에 불과하고, 또 민사집행법 제291조에 의하여 제248조

제1항이 준용된다고 하더라도 이는 단지 공탁의 근거를 부여하는 것일 뿐, 그 조항에 따른 권리공탁과 같은 성질의 공탁이 이루어지는 것을 뜻하는 것은 아니라는 것이다.¹⁹³⁾

3) 따라서 다른 채권자들도 나아가 채무자가 가지는 위 공탁금출급청구권에 대하여 압류 또는 가압류의 집행을 하는 것이 가능하고, 당해 가압류채권자도 본집행으로서의 압류를 하는 것이 또한 가능하다.

4) 그러면, 이와 같이 가압류채권이 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따라 집행공탁이 된 경우 어느 때에 배당가입차단효가 발생한다고 보아야 할까.

이 경우 배당가입의 차단효는 가압류의 집행을 원인으로 하여 제3채무자가 공탁을 한 후, 가압류채권자 또는 다른 채권자가 공탁관을 제3채무자로 하여 채무자가 가지는 출급청구권에 대하여 압류의 집행을 한 때에 발생하게 된다고 보아야 할 것이다.¹⁹⁴⁾ ¹⁹⁵⁾

이것은 채무자가 가지는 출급청구권이 압류된 것에 의하여 채무자가 가지는 출급청구권 위에 가압류의 효력이 미치고 있었던 공탁이 - 가압류채권의 본집행으로서의 압류이든지 혹은 다른 채권자에 의한 압류이든지에 불구하고 - 최초의 압류명령이 제3채무자인 공탁관에게 송달된 시점에 본래의 민사집행법 제248조에 의한 집행공탁으로 전화(轉化)된다고 해석되고 있기 때문이다.¹⁹⁶⁾

5) 따라서 최초의 압류명령의 송달시에 배당가입차단효가 생기므로 그 후의 압류 또는 가압류의 집행채권자는 배당등을 받을 수 있는 채권자로서의 지위를 취득할 수 없다.

6) 그리고 위 가운데 가압류 집행을 원인으로 하여 제3채무자가 공탁한 후 채무자가 가지는 출급청구권에 대하여 다른 채권자가 압류를 하여 이것이 압류의 경합에 해당한 때에는 공탁관은 압류의 경합을 이유로 공탁한 후 집행법원에 대해 사유신고

193) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 497.; 대법원 2006. 3. 10. 선고 2005다15765 판결; 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결 등

194) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 228.

195) 대법원 2006. 3. 10. 선고 2005다15765 판결 【판결요지】채권 가압류를 이유로 한 제3채무자의 공탁은 압류를 이유로 한 제3채무자의 공탁과 달리 그 공탁금으로부터 배당을 받을 수 있는 채권자의 범위를 확정하는 효력이 없고, 가압류의 제3채무자가 공탁을 하고 공탁사유를 법원에 신고하더라도 배당절차를 실시할 수 없으며, 공탁금에 대한 채무자의 출급청구권에 대하여 압류 및 공탁사유신고가 있을 때 비로소 배당절차를 실시할 수 있다고 할 것이다.

196) 稻葉威雄, “民事執行法における供託(二)”, 金融法務事情 932号, 4-5.; 佐藤修市, “民事執行法等における第3債務者の供託(上)”, NBL 220号, 30.

를 해야 할 것이지만,¹⁹⁷⁾ 이 경우에 있어서는 공탁해야 할 금액이 이미 공탁되어 있기 때문에 현실적으로 다시 공탁절차를 취하지 않고, 다만 공탁의무가 발생한 시점에 공탁한 것으로 간주되고 있다.¹⁹⁸⁾ 따라서 이 경우 공탁관은 압류명령을 발한 집행법원에 사유신고만 하면 될 것이다.

그렇지 않고 가압류집행을 원인으로 하는 공탁 후 채무자가 가지는 출급청구권에 대하여 당해 가압류채권자가 본집행으로서의 압류를 한 때에는, 채무자가 가지는 출급청구권 위에 집행의 효력이 미치고 있던 공탁은, 위에서 보듯이 본집행을 위한 압류명령이 제3채무자인 공탁관에게 송달됨과 동시에 본래 민사집행법 제248조 제1항에 의한 공탁으로 전화(轉化)한다고 해석되고, 이와 같이 해석하는 것은 본집행을 위한 압류에 의해 배당가입차단효를 인정하는 것이 타당하기 때문이다.

7) 이 경우 제3채무자인 공탁관이 본집행으로서의 압류인가 아닌가를 판단하기 위해서는 당해 압류명령의 청구채권과 공탁서의 「공탁원인인 사실」란에 기재된 가압류의 피보전권리를 비교해야 할 것인데, 일반적으로 공탁서에는 가압류의 청구채권의 내용이 기재되어 있지 않아 그 동일성을 인정하는 것이 곤란하고,¹⁹⁹⁾ 또 본집행의 이행만으로는 집행법원이 배당등 절차의 개시 가능 여부를 인식하기 어려우므로 원칙적으로 집행법원에 대해 사유신고가 되어야 할 것이다.²⁰⁰⁾

아. 채무액을 공탁한 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 그 사유를 법원에 신고하면 배당절차가 개시되는 것이 원칙이지만 법원이 사유신고서를 접수한 결과 배당절차에 의할 것이 아니라고 판단될 경우 그 신고서를 불수리(각하)하는 결정을 할 수 있고, 이 경우에는 배당절차가 개시되는 것이 아니므로 그 사유신고에는 새로운 권리자의 배당가입을 차단하는 효력이 없다.²⁰¹⁾

자. 민사집행법 제247조 제1항 제1호가 압류채권자 이외의 채권자가 배당요구의 방법으로 채권에 대한 강제집행절차에 참가하여 압류채권자와 평등하게 자신의 채권의 변제를 받는 것을 허용하면서도, 다른 한편으로 그 배당요구의 종기를 제3채무자

197) 대법원 행정예규 제542호 「공탁공무원의 사유신고에 관한 업무처리지침」 참조

198) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 229.

199) 立花宣男, “執行供託の理論と實務”, 224-225, [東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 230.에서 재인용]

200) 앞서 본 대법원 2006. 3. 10. 선고 2005다15765 판결 참조

201) 대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다1766 판결. 다만 그렇더라도 이 경우 공탁 자체의 효력에는 영향이 없다.

의 공탁사유 신고시까지로 제한하고 있는 이유는 제3채무자가 채무액을 공탁하고 그 사유 신고를 마치면 배당할 금액이 판명되어 배당절차를 개시할 수 있는 만큼 늦어도 그 때까지는 배당요구가 마쳐져야 배당절차의 혼란과 지연을 막을 수 있다고 본 때문이다. 민사집행법 제247조 제1항에 의한 배당가입차단효는 배당을 전제로 한 집행공탁에 대하여만 발생하고, 집행공탁과 변제공탁이 혼합된 소위 혼합공탁의 경우 변제공탁에 해당하는 부분에 대하여는 제3채무자의 공탁사유신고에 의한 배당가입차단효가 발생할 여지가 없다. 따라서 제3채무자가 혼합공탁을 하고 그 공탁사유신고를 한 후에 채무자의 공탁금출급청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 받은 채권자는, 집행공탁에 해당하는 부분에 대하여는 배당가입차단효로 인하여 적법한 배당요구를 하였다고 볼 수 없지만 변제공탁에 해당하는 부분에 대하여는 적법한 배당요구를 하였다고 보아야 하므로 집행공탁에 해당하는 부분으로부터 배당받은 사람에 대하여는 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 없고, 변제공탁에 해당하는 부분으로부터 배당받은 사람에 대하여는 배당이의의 소를 제기할 원고적격이 있다.²⁰²⁾

X. 가압류 및 압류채권의 청구금액 특정 문제에 관하여

1. 예컨대, 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 대여금채권에 관하여 甲의 채권자 丙이 청구금액을 “500만 원 및 이에 대한 2018. 5. 10부터 완제일까지 연 25%의 비율에 의한 금원”이라고 기재하여 채권가압류를 청구한 경우와 같이 가압류채권자가 청구금액에 장래의 이자 또는 지연손해금을 포함하여 청구하는 것에 관하여, 과거에는 그 종기가 확정되지 아니하여 압류의 경합 여부를 판단하기가 곤란하고, 따라서 제3채무자의 지위가 불안정해진다는 이유로 압류신청시까지의 원리금만을 청구금액으로 삼아 가압류를 하도록 하는 것이 실무의 관례였다.

그러나 민사집행법은 제291조, 제248조 제1항에서 압류의 경합이 없이 가압류만 집행된 경우라도 제3채무자에게 집행공탁할 수 있는 권리를 인정함으로써 이러한 문제점을 해결하였으므로 이제는 채권가압류의 경우에 위와 같이 청구금액에 장래의 이자 또는 지연손해금을 포함하여 구하는 것도 가능해졌다 할 것이다.²⁰³⁾

2. 반면 채권압류에 있어서는 집행권원에서 완제일까지의 이자·지연손해금 등의

202) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결

203) 위 법원실무제요 민사집행(IV), 119.

부대청구가 인용되어 있고 이를 원금에 덧붙여 청구하는 때에는 그 뜻을 명백히 하여야 하는바, 실무에서는 압류명령신청의 청구금액 중 지연손해금을 위와 같이 완제일까지라고 하여 구할 경우 제3채무자의 입장에서 볼 때 그 지급이 금지되는 범위가 분명하지 않다는 등의 이유로 신청 당시까지의 구체적인 금액을 계산하여 확정액으로 표시하도록 하고 있다.²⁰⁴⁾ 즉 일부청구가 통례인 것이다.

이에 관해서는 압류명령에 있어서 집행채권의 범위가 확정적이지 않으면 제3채무자의 부담이 증가하고 타당성을 결하는 경우가 많은바, 이는 압류명령이 발하여진 경우 채권자는 추심명령을 얻어 다른 경합하는 채권자가 없는 한 피압류채권으로부터 자기 채권의 한도(집행채권 및 집행비용)에서 추심하는 것이 인정되어 있지만, 이러한 때에 제3채무자에게 부대채권액을 계산하도록 요구하는 것은 적절하지 않기 때문에 위 청구금액을 확정하도록 하는 것이 실무상 오랜 관행이 되어 왔다고 설명하는 견해도 있다.²⁰⁵⁾ ²⁰⁶⁾

3. 어쨌든, 실무가 가압류의 경우에는 완제일까지의 지연손해금을 청구해도 이를 인정하는 한편 압류의 경우에는 이를 압류신청시까지 확정시키도록 하는 것으로 인하여, 압류채권이 추심단계에서 임의지급되지 않고 배당절차로까지 나아간 경우에는 완제일까지 가압류를 해놓은 가압류권자가 압류권자보다 유리해지는 경우가 종종 생기는데,²⁰⁷⁾ 압류채권자로서는 가압류권자와 달리 집행권원을 가지고 있으므로 다른 압류와의 경합 등으로 추심이 어려워질 경우에는 배당을 예상하여 나중에 더 발생한 이자 또는 지연손해금 등에 대하여는 추가압류하거나 배당요구의 방법을 사용함으로써 혹여 생길 수도 있는 불리함이 없도록 해야 할 것이다.²⁰⁸⁾

204) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 309-310.; 예컨대, “금 1,000만 원(대여금), 금 20만 원(위금원에대한 2018. 5. 8.부터 2018. 8. 8.까지(신청시)까지의 연 %의 이자 및 지연손해금), 합계 금 1,020만 원”과 같이 표시한다.

205) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 113-114.

206) 그러나 압류명령의 경우에도 압류신청시가 아니라 위와 같이 완제시까지의 이자 및 지연손해금을 청구할 수 있는지 여부에 관하여는 여전히 논란이 되고 있고, 이를 인정하는 듯한 판례도 있기는 하나(대법원 1999. 12. 10. 선고 99다36860 판결 참조), 이 판례가 이에 대하여 직접적으로 판단하고 있는 것은 아니라고 본다.

207) 그러나 다른 한편, 이와 같은 경우에도 가압류채권자가 최종적으로 그 채권액을 지급받기 위해서는 그에 상응하는 집행권원을 받아와야 가능하다는 점에서 본다면 이 경우 반드시 가압류채권자가 압류채권자에 비해 유리하다고만 할 수는 없다고 생각된다.

208) 한편 이와 같이 부대채권의 종기를 압류명령 신청일까지로 하는 실무와 관련하여, 채권자가 후일 배당절차 등에서 부대채권의 종기를 압류명령 신청일 후로 기재한 채권계산서를 제출한 경우 이를 인정할 수 있는지 여부에 대하여 논의가 진행 중인 바, 이를 소극적으로 보는 견해와 적극적으로 보는 견해가 대립하고 있다[이에 대하여는 제10장 배당등절차 제6절 배당을 받을 채권자Ⅱ, 1. 가. 3) 참조].

다만 실무의 일부 입장 중에서는 여전히 압류의 경합 등을 쉽게 판단하기 위한 의도로 가압류신청시까지 또는 장래의 일정시점까지의 지연손해금을 계산하여 확정금액으로 신청하도록 유도하고 있기도 하다(심지어 장래 지연손해금 부분을 기각하는 실무례도 있어 보인다).

그러나 채권가압류에 있어서 지연손해금을 일정시점까지 확정하여 구하는 것과 이를 확정하지 않은 채 그냥 완제시까지 구하는 것의 배당에 이른 시점에서의 차이는 후자가 보다 그 채권자에게 유리한 점이 있으므로 제3채무자의 권리공탁이 인정된 자금의 민사집행법하에서는 지연손해금을 완제시까지 구하는 채권자의 청구를 실무가 임의대로 거절해서는 아니된다고 본다.

또한 일부 실무에서는 청구금액 중 이자 등 부분을 완제시까지로 할 경우 나중에 해방금액을 정하기 어렵다는 이유를 들어 가압류의 경우 청구금액을 신청시까지 확정하게 하고 그렇지 않을 경우 신청시 이후의 이자 등을 기각하는 사례가 있어 보이나, 그와 같이 채권자의 권리를 제한함으로써 일부 기각할 법적 근거가 없고(위에서 보듯이 법원이 채권자에게 확정금액으로 신청할 것을 권유 내지 유도할 수는 있으나, 이에 응하지 않았다고 해서 그 신청을 기각할 근거는 없다는 것이다), 나아가 민사집행법 제282조, 209) 제299조²¹⁰⁾ 등이 “가압류명령에 정한 금액”이라고 규정할 뿐 해방금액이 청구금액과 동일한 금액일 것을 요하고 있지 않으므로 이 문제는 가압류명령시 따로 해방금액을 정함으로써 해결하여야 하는 것이지 그것 때문에 채권자의 권리를 제한해서는 안된다고 볼 것이다.

그리고 또 다른 실무례는 가압류의 청구금액에 완제일까지 지연손해금등을 인정한다면 그 이후에 된 압류 및 전부명령과의 관계에서 제3채무자가 가압류에 저촉되지 않은 유효한 전부금액(轉付金額)을 산정하기 어려우므로 신청시까지로 특정된 금액만을 인정해야 한다고도 주장하고 있으나, 민사집행법 제248조 제1항이 신설되어 압류가 경합하지 않은 경우 혹은 가압류만 있는 경우에도 제3채무자의 집행공탁을 인정하고 있는 현행법하에서 이는 문제가 되지 않는 것이다. 제3채무자는 이 경우 압류의 경합 여부를 묻지 않고 위 제248조 제1항에 따라 공탁함으로써 채무를 면할 수 있기

209) 민사집행법 제282조 [가압류해방금액] 가압류명령에는 가압류의 집행을 정지시키거나 집행한 가압류를 취소시키기 위하여 채무자가 공탁할 금액을 적어야 한다.

210) 민사집행법 제299조 [가압류집행의 취소] ① 가압류명령에 정한 금액을 공탁한 때에는 법원은 집행한 가압류를 취소하여야 한다. ② 제1항의 재판은 변론 없이 할 수 있다. ③ 제1항의 취소결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다. ④ 제1항의 취소결정에 대하여는 제17조 제2항의 규정을 준용하지 아니한다.

때문이다.²¹¹⁾ 따라서 위와 같은 실무례는 어느 이유에서도 정당하다고 보기 어렵다.

채권자는 자신이 채무자와 약정한 채권 모두를 보전처분에 의해 보전할 권리가 있는 것이고, 이를 법원의 사정 또는 형편에 따라 임의로 제한해서는 안된다 할 것이다.

211) 즉 이는 민사집행법 제248조의 입법취지 중 한가지 예에 해당하는 것일 뿐이다.

제3절 공탁서에 대하여

I. 의의

공탁서란, 법원에 대하여 공탁하려고 하는 자가 제출해야 하는 법정서식의 서면으로서, 공탁자 및 피공탁자의 주소·성명, 공탁물, 공탁원인사실, 법령조항 등을 기재한 문서를 말한다(공탁규칙 제20조 제1항 참조).

따라서 공탁신청은 절차의 안정성과 공탁관의 형식심사라는 두 가지 요청에서 위와 같은 일정한 공탁서를 제출하게 하는 요식행위인 것이다.²¹²⁾

II. 공탁의 수리 또는 불수리

1. 공탁서의 제출 등

제3채무자는 집행공탁에 의한 사유신고를 할 경우 이에 공탁서를 함께 첨부하여야 한다(민집규 제172조 제1항, 제2항).

이 공탁서는 제3채무자가 공탁할 때에 공탁소로부터 교부된 것인데, 이는 집행의 목적물이 공탁소에 공탁되어 있음을 증명하는 것이므로 집행법원은 이에 의해서 그 사실을 확인할 수 있게 된다.

제3채무자가 공탁서를 분실하여 제출할 수 없는 경우에는 어떻게 하여야 하는가.

생각건대 이 경우에는 다시 공탁소로부터 공탁서를 교부받을 수는 없으므로 당해 채무액을 공탁한 공탁소에 공탁증명신청을 하고, 이에 따라 공탁소로부터 ㉠ 공탁번호 ㉡ 공탁일시 ㉢ 공탁원인 ㉣ 법령조항 등이 기재된 공탁증명서를 발행받아 이를 공탁서에 대신하여 첨부한 후 사유신고할 수 있다고 해석해야 될 것이다(공탁규칙 제59조 제1항 내지 제3항 참조).

그런데 실무상 제3채무자들이 공탁서를 첨부하여 사유신고를 하고 나면, 자신의 수중에 공탁 후 사유신고를 하였음을 증명하는 서면이 남아 있지 않음을 불안하게 여겨 공탁서원본이 아닌 사본만을 집행법원에 제출하고 공탁서원본(이 원본에는 공탁금액을 지급하였음을 증명하는 금융기관의 날인이 되어 있다)은 자신이 보관하는 경우

212) 김인수, 공탁법강의, 秀林(2000), 35.

가 있고, 집행법원에서도 이러한 사본만을 받아서 기록에 첨부하는 사례가 있는 것으로 보인다. 그러나 이러한 실무의 처리례는 위 민사집행규칙에 반하는 것이어서 적법하지 않으므로 시정되어야 할 것이며, 만일 제3채무자가 위와 같이 사유신고 등을 하였음을 증명하는 서면을 요구해오면 오히려 공탁서의 사본에 집행법원이 접수인을 찍어서 이를 제3채무자에게 교부해주고, 공탁서원본은 이를 사유신고서와 함께 교부받아 기록에 철하여야 할 것이다.

그리고 민사집행법 제248조 제4항 단서에 따라 압류채권자 등 이해관계인이 제3채무자를 대신하여 사유신고를 할 경우에는 공탁서를 첨부하지 않아도 된다.

2. 공탁의 수리·불수리

공탁관은 당사자가 제출한 공탁서를 조사한 결과, 적법한 공탁이라고 인정되는 경우에는 공탁서에 공탁을 수리한다는 취지와 공탁번호(공탁번호는 개개의 공탁을 특정하기 위해 각 공탁서에 연도, 부호문자와 진행번호에 의해 부여하고 있다), 공탁물을 납입기일까지 지정된 공탁물보관자에게 납입하여야 한다는 취지, 그 기일까지 공탁물을 납입하지 않을 경우에는 수리결정의 효력이 상실된다는 취지를 기재하여 기명·날인하고 공탁물납입서 및 공탁서 1통을 공탁자에게 교부하여 공탁물을 공탁물보관자에게 납입케 한다(위 공탁규칙 제25조 제1항).

그리고 부적법한 공탁이라고 인정하는 경우에는 공탁서에 공탁물불수리의 취지를 기재하여 기명·날인하고 공탁서 1통과 첨부서류를 공탁자에게 반환하며 서면으로 써 그 취지를 공탁자에게 통지하여야 한다(위 공탁규칙 제43조 제1항, 제2항).

이러한 공탁수리 결정에는 위와 같이 납입기일까지 공탁물을 납입하지 않을 경우에는 수리결정의 효력이 상실된다는 취지가 기재되어 있으므로 공탁자가 납입기일까지 공탁물을 납입하지 않을 때에는 그 수리결정은 신청인에 대한 납입최고 등 절차 없이 당연히 실효되며, 수리결정이 실효된 때에는 공탁관은 그 취지를 원표에 기재하여야 한다(위 공탁규칙 제25조 제2항, 제3항). 납입기일 이후에 공탁물이 납입된 경우에는 그 공탁은 무효이므로 착오로 인한 공탁에 준하여 회수할 수 있을 것이다.²¹³⁾

공탁관의 처분에 대하여 불복이 있는 때에는 공탁법이 정한 바에 따라 이의신청과 항고를 할 수 있고, 공탁관에 대하여 공탁법이 정한 절차에 의하여 공탁금지급청구를 하지 아니하고 직접 민사소송으로써 국가를 상대로 공탁금지급청구를 할 수는 없다.²¹⁴⁾

213) 김인수(주211), 55.

214) 대법원 1991. 7. 12. 선고 91다15447 판결; 대법원 2013. 7. 25. 선고 2012다204815 판결

Ⅲ. 공탁서의 정정

1. 의의

공탁은 공탁서에 기재된 공탁원인인 사실을 기초로 하여 채권의 소멸이라는 실제적 효과를 발생시키는 것이고, 이 점에 있어서는 집행공탁도 예외는 아니다.

그런데 집행공탁을 하는 제3채무자는 일반적으로 공탁 등에 관하여 전문지식이 없는 경우가 많으므로 오해나 간과에 의해서 공탁을 잘못하는 수가 종종 발생하게 되고, 이러한 때에는 공탁서를 정정할 필요가 있게 되지만, 그렇다고 하더라도 일단 공탁이 된 이상 그 기초가 되는 사실을 특정하는 공탁서 기재의 변경을 인정하는 것은 실체관계에 영향을 줄 수도 있기 때문에 모든 경우에 공탁서의 정정이 허용된다고 말하기는 어렵다.

그래서 공탁규칙 제30조 제1항은 “공탁신청이 수리된 후에 공탁서의 착오기재를 발견한 공탁자는 공탁의 「동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서」 공탁서의 정정을 신청할 수 있다.”라고 규정하고, 다시 제4항은 “공탁관이 공탁서정정신청을 수리한 때에는 공탁서정정신청서에 수리한다는 취지를 기재하고 기명날인한 후...”라고 규정하여, 그 정정의 허용범위에 제한을 가함과 동시에, 그 정정의 허부 판단을 공탁관에게 맡기고 있다.

2. 정정을 인정할 수 있는 요건

위와 같이 공탁서 정정의 허용 여부에 대해서는 공탁관에게 그 판단을 맡기고 있지만, 이러한 공탁서의 정정이 인정되려면 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

가. 첫째로, 공탁서 기재 사항에 대하여 명백한 오기(誤記)가 있어야 하는바, 잘못 기재된 것과 그 잘못이 명백하다는 것이 필요하다.

다만 이 경우의 오기(誤記)는 계산의 잘못이나 글자 기재의 잘못과 같은 기재 자체로부터 객관적으로 인식될 수 있는 경우에 한정하지 않고, 공탁의 전체 취지로 보아 공탁자의 의사와 공탁서에 표현된 것과의 사이에 명확한 불일치가 있는 경우도 포함한다 할 것이다.²¹⁵⁾

215) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 274.

나. 둘째로, 정정 전의 공탁서의 기재와 정정 후의 기재 사이에 동일성이 존재해야 한다.

공탁서의 정정은 실체관계에 영향을 미칠 가능성이 있고, 그 정정에 대하여 이해관계로 인한 불복신청의 기회가 부여되어 있지 않기 때문에, 그 허용범위에 관해서는 공탁서 기재의 동일성이라는 제한이 가해진다.

동일성 유무의 인정은 선례의 집적에 의해 형성된 공탁실무에 기초하여 공탁관이 판단하게 될 것이다.

다. 셋째로, 공탁서 기재의 오류가 공탁수리 전에 존재하고, 공탁수리 후에 그 오류가 발견된 경우이어야 한다.

공탁 후의 사정의 변경에 의해 공탁서 기재가 객관적 사실과 합치하지 않게 된 경우에는 본래 공탁서의 기재에 잘못이 있었던 것은 아니기 때문에 공탁서의 정정절차는 아니고, 다른 사정변경을 증명하는 절차에 의해야 할 것이다.

또한 공탁수리 전에 공탁서의 오류가 발견되었으면 공탁자가 임의로 정정을 하면 되는 것이므로(위 공탁규칙 제12조 제2항, 제3항), 이 경우는 여기서 말하는 공탁서 정정의 문제는 생기지 아니한다.

라. 넷째로, 공탁자로부터의 신청이 있어야 한다. 즉 공탁서 정정은 그 공탁서의 작성자인 공탁자 자신의 신청이 있는 경우에만 허용되는 것이다.

3. 실무상 정정을 인정할 것인지 여부가 문제되는 경우

가. 사건번호, 당사자 표시, 공탁원인 등의 오기

압류명령의 사건번호, 채권자·채무자 등의 당사자 명칭, 주소 등의 기재 등의 오기에 관하여는 공탁서의 정정이 일반적으로 가능하다고 생각되지만, 이 경우에 피공탁자의 기재, 공탁한 채무의 특정, 전제사실을 긍정하는 것에서 부정하는 것으로 기재하는 것 등은 공탁의 동일성을 넘어서는 것으로서 그 정정이 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다.²¹⁶⁾

예를 들어, 혼합공탁에 있어서 피공탁자가 ‘甲 또는 乙’로 되어 있는 데, 이를 ‘甲’ 1인으로 정정한다든지 혹은 그 역으로 피공탁자를 임의로 추가하는 등의 정정은 허용되지 아니한다.

216) 김인수(주211), 186. 이하

나. 경합하는 압류명령의 탈루(脫漏)

이는, 실무상 잘 나타나는 사례이다. 공탁서와 사유신고의 어딘가 한 곳에 탈루(脫漏)가 있는 경우와 양자 모두에 이러한 탈루(脫漏)가 있는 경우가 있는바, 이 경우 공탁서의 정정은 공탁실무상 허용될 수 있다고 생각한다.²¹⁷⁾

제3채무자가 공탁서에 경합하는 압류명령 중 일부를 누락하였고 그에 따라 당해 채권자가 배당절차에서 배당을 받지 못하게 된 경우, 압류채권자가 그 배당을 받지 못한 금액 상당의 손해가 현실적으로 발생하였다는 점을 증명하면 제3채무자에게 손해배상책임이 인정될 수도 있다.²¹⁸⁾

다. 법령조항의 오기(誤記)

예컨대, 압류명령의 경합에 의해 의무공탁을 하였음에도 불구하고 권리공탁 조항을 법령조항으로 한 경우[또는 그 역(逆)의 경우]가 있을 수 있는데, 이 경우도 실제 관계에 커다란 영향을 주지 않는 것으로 보아 정정을 인정할 수 있을 것이다.

라. 공탁금액의 오기(誤記, 일부공탁)

원칙적으로 공탁금액은 공탁요건에 관한 것이므로 그 정정신청은 허용되지 않는다.²¹⁹⁾

그리고 채권 전액이 압류되어졌음에도 불구하고 그 일부를 공탁한 경우, 그 공탁을 전액 공탁으로 정정하는 것은 허용되지 않는다.

다만 이 경우 추가공탁을 하는 것이 가능한가 아닌가에 관하여 논의가 있으나,

217) 渡部房男, “重複押留えの一部の記載お脱漏した場合の供託書の訂正の可否について”, NBL383号, 41.

218) 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003다58959 판결【판결요지】불법행위로 인한 손해배상청구권은 현실적으로 손해가 발생한 때에 성립하는 것이고, 현실적으로 손해가 발생하였는지 여부는 사회통념에 비추어 객관적이고 합리적으로 판단하여야 하는 것인바, 제3채무자가 채권에 대한 가압류가 있음을 이유로 변제공탁을 하면서 공탁원인사실에 가압류채권자의 가압류에 관한 기재를 누락함으로 인하여 그 후 이루어진 공탁금에 대한 배당절차에서 가압류채권자가 배당을 받지 못하였다고 하더라도, 가압류채권자로서는 채무자의 다른 재산에 대하여 강제집행을 하거나, 배당절차에서 과다배당을 받게 된 자들을 상대로 부당이득반환청구를 함으로써 채권의 만족을 얻을 수 있는 것이므로 제3채무자의 위와 같은 잘못으로 말미암아 채권의 만족을 받는 것이 곤란해졌다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공탁원인사실에 가압류에 관한 기재가 누락되어 가압류채권자가 배당을 받지 못하게 되었다는 사유만으로 가압류채권자에게 그 배당을 받지 못한 금액 상당의 손해가 현실적으로 발생하였다고 할 수 없고, 그러한 손해가 현실적으로 발생하였다는 점에 대하여는 피해자인 가압류채권자가 이를 증명하여야 한다.

219) 법정질의회답(1982. 12. 22. 제423호)

공탁무효에 의해 회수하고 다시 전액 공탁을 시키는 것은 제3채무자에게 큰 부담을 지우는 것이기 때문에 일부공탁을 유효로 하고 추가공탁을 인정하는 경우(예를 들어, 부족액이 근소한 경우)도 있다.

이와 같이 일부공탁이 유효로 되는 경우에는 최초 집행공탁시에 공탁금 전액에 대해 배당가입차단효가 생기는 것으로 해석해야 한다.²²⁰⁾

마. 공탁원인의 탈루(脫漏)

압류명령 송달되기 전에 채권양도의 통지가 있고, 이 양도의 유효성에 의문이 있는 경우, 공탁실무상 변제공탁과 집행공탁을 합하여 혼합공탁을 하는 것이 인정되고 있다. 그런데도 제3채무자가 집행공탁만을 하여 사유신고서를 제출하는 경우가 있다(채권양도의 유효성에 의문이 없으면, 제3채무자는 변제공탁만을 해야 할 것이기 때문에, 공탁금을 회수할 필요가 있다).

이 경우 집행공탁을 혼합공탁으로 하는 공탁서 정정은, 공탁의 성질이 실질적으로 다른 이상 인정될 수 없다고 본다.

바. 그 밖의 경우

그 밖에, 건물 차임의 공탁 후에 그 차임에는 대지 차임도 포함되어었는데, 이를 기재하지 않았다 하여 임차목적물인 대지를 추가하는 것, 공탁서에 “지급기일 정함 없음”이라 기재하여 선급약정에 기한 차임의 공탁을 한 후 그 지급일에 관해서 오기하였다 하여 그 지급일을 특정하는 등의 정정신청은 동일성의 범위를 넘어서는 것이므로 허용될 수 없다 할 것이다.²²¹⁾

4. 공탁서정정의 절차

공탁서의 정정은, 공탁서정정신청서 2통과 정정사유를 소명하는 서면을 제출하여야 한다(위 공탁규칙 제27조의2 제2항).

정정신청서가 수리되면 공탁관은 그 신청서에 수리한다는 취지를 기재하고 기명·날인한 후 그 신청서 1통을 신청인에게 교부하고, 원표의 기재를 정정하여야 한다(위 공탁규칙 제27조의2 제4항).

이때에 공탁정정의 범위에 관하여 공탁 기재의 동일성을 해하지 않는다는 한

220) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 281.

221) 김인수(주211), 187.

정이 가해져서 그 실체관계에 영향이 없기 때문에, 변제공탁의 경우의 피공탁자와 같은 이해관계인에게 공탁서정정통지서를 송달할 필요는 없다 할 것이다.

공탁자는 위와 같이 집행공탁을 정정하여 공탁소로부터 그 정정의 취지가 기재된 신청서를 교부받으면, 이를 공탁서 및 사유신고서를 제출한 집행법원에 제출할 필요가 있고, 집행법원 또한 공탁서와 함께 보관하여 그 이후의 절차에 이용하여야 할 것이다.

5. 공탁서정정의 효과

가. 공탁서정정이 수리되면, 수리의 취지가 기재된 공탁서정정신청서는 공탁서의 일부로 보게 되므로(위 공탁규칙 제27조의2 제5항), 공탁시에 소급하여 그와 같이 정정된 기재가 있었던 것으로 된다고 보아야 할 것이다.²²²⁾

나. 그러나 현재 변제공탁에 있어서 공탁서 정정에 관한 우리 대법원의 입장은 불소급설을 취하고 있다.

즉 이러한 대법원의 견해 중 대표적인 것은 대법원 1986. 8. 19. 선고 85누 280 판결이라 할 것인데,²²³⁾ 이에서 “변제공탁의 경우 채권자가 반대급부 또는 기타 조건의 이행을 할 의무가 없음에도 불구하고 채무자가 이를 조건으로 공탁한 때에는 채권자가 이를 수락하지 않는 한 그 변제공탁은 효력이 없으며 그 뒤 채무자의 공탁에 붙인 조건의 철회 정정청구에 따라 공탁관으로부터 위 정정청구의 인가결정이 있었다 하더라도 그 변제공탁은 인가결정시부터 반대급부조건이 없는 변제공탁으로서의 효력을 갖는 것으로서 그 효력이 당초의 변제공탁시로 소급하는 것은 아니다.”라고 함으로써 공탁서 정정의 효과가 소급하지 않는다고 판시하고 있다.

다. 이러한 대법원의 견해에 대해서는, “① 공탁서의 정정은 공탁 당시부터 존재 하던 착오사유를 후일에 이르러서 당초에 소급하여 제거하려는 절차이지, 정정신청시에 새로 발생한 착오사실을 제거하려는 절차가 아니고, 부당한 반대급부조건을 붙인 변제공탁의 경우에는 공탁 당시부터 이미 그와 같은 조건을 붙일 수 없었던 것을 착오로 붙인 것이어서 이를 철회하여 제거하기 위한 정정절차이므로 그것이 인가되면 공탁 당시부터 부당조건이 없는 것으로 된다고 보아야 함이 당연하다. ② 공탁서의 정정은 공탁서라고 하는 공문서에 표현상의 오류가 명백한 경우에 하는 것인 점에서, 같은 공문

222) 법정질의회답(1995. 6. 14. 제3302-290호)

223) 그 외에 대법원 1968. 11. 19. 선고 68다1570 판결; 대법원 1974. 5. 14. 선고 74다166 판결; 대법원 1971. 6. 30. 선고 71다874 판결 등도 동일한 취지이다.

서인 판결서에 같은 오류가 명백한 경우에 하는 판결결정(민소법 제211조)과 유사하고, 이 경정결정은 판결과 일체가 되어 경정결정 자체의 효력과는 달리 판결선고시에 소급하여 그 효력이 발생하며, 그리하여 처음부터 경정된 내용대로의 판결이 선고된 것과 같이 되는 것인바,²²⁴⁾ 같은 공문서 정정의 효력을 전자에 한해서만 소급효를 인정하지 아니할 특별한 이유를 발견하기 어려우므로 양자의 정정 또는 경정의 효력은 모두 공탁수리 또는 판결선고 당시로 소급한다고 봄이 상당하다. ③ 공탁규칙 제30조 제5항은 “수리의 취지가 기재된 공탁서정정신청서는 공탁서의 일부로 본다.”라고 규정하고 있는 바, 여기서 「공탁서의 일부로 본다」라 함은 가령 공탁서 중 반대급부조건 표시란에 기재하였던 부당조건을 삭제하여 없는 것으로 한 정정신청서라면 그것이 본래의 공탁서의 반대급부조건 표시란을 대신한다는 뜻이므로 위 공탁서는 정정 결과 반대급부 표시란이 공란으로 되는 것이어서 위 정정의 효력은 결국 이 규정에 의하여 결론적으로 소급효를 인정한 것으로 된다. ④ 공탁서의 정정은 수리된 공탁서 중의 일부분에 공탁자의 의사에 합치하지 아니하는 착오부분이 존재함을 발견하여 공탁자가 그 부분을 취소·철회하는 것으로서, 마치 민법 제109조에 따른 착오의사표시의 취소와 유사한 것이라 할 것이고, 다만 다른 점은 그것이 공문서가 된 후에 발견한 관계로 이를 취급하는 공탁관의 승인을 받아서 취소한다는 점 뿐인바, 의사표시를 철회·취소하면 그와 같은 의사표시는 당초부터 없었던 것으로 됨은 또한 당연하다. ⑤ 위 판례에 따르면 공탁서 정정에 의하여 부당반대급부조건을 취소·철회한 경우에 그 정정시까지의 변제공탁은 무효였다가 정정으로 무효였던 변제공탁이 유효한 것으로 전환한다고 보거나 또는 정정시에 정정한 대로 새로운 변제공탁이 성립된 것으로 보게 될 것이나, 부당조건부 변제공탁은 착오의사표시라고 하는 하자가 내재한 공탁으로서 이 하자를 제거하면 당초부터 하자가 없는 완전한 변제공탁이 된다고 보는 것이 위 공탁법규의 입법취지에도 부합한다 할 것이다. “라는 등의 많은 논거를 들어 이를 비판한 후 소급설을 취하는 견해가 있고,²²⁵⁾ 이러한 소급설은 앞서 본 우리 공탁규칙 제30조 제1항이 공탁서 정정에 있어서 「동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서」란 요건을 고수하고 있는 점에 비추어 상당히 합리적인 견해라고 생각된다.

224) 대법원 1962. 1. 25. 선고 4294민재항674 판결 참조

225) 남기정, 앞의 실무공탁요론, 268-271.

제4절 사유신고

(민집 제248조 제4항, 제236조 제2항)

I. 의의

압류명령이 제3채무자에게 송달되면 채권압류의 효력이 발생하고, 제3채무자는 본래의 채권자인 집행채무자에 대한 지급이 금지된다(민집 제227조 제1항, 제3항). 그 결과, 제3채무자는 압류채권자의 추심권 행사에 응하여 지급하든가 혹은 공탁해야만 채무를 면하게 되는 것이다.

위 공탁에는 이미 본 것처럼 권리공탁과 의무공탁이 있지만, 제3채무자는 어느 공탁을 한 경우에도 그 사유를 집행법원에 신고해야 한다(민집 제248조 제4항).

집행법원은 제도상 이 신고에 의해서 공탁사실을 알게 된다. 역으로 말하면, 이 신고가 없으면 집행법원은 공탁사실을 알 방법이 없는 것이다.

이러한 신고를 제3채무자의 사유신고라 하고, 이러한 사유신고가 있을 때에 비로소 배당요구의 종기에 이르게 된다(민집 제247조 제1항 제1호).

그리고 민사집행법 제252조 제2호는 제3채무자가 같은 법 제248조의 규정에 따라 공탁한 때에 배당절차가 개시된다고 규정하고 있지만, 제3채무자가 공탁하였다 하더라도 그 사실을 집행법원에 사유신고하지 않는 한 집행법원이 이를 알 수 있는 방법이 없으므로 실제상 제3채무자가 위와 같이 사유신고를 해야만 배당절차를 개시할 수 있게 된다고 보아야 할 것이다.

또한 추심채권자는 제3채무자로부터 추심한 금액을 집행법원에 신고하여야 하고, 그 신고 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 하는바(민집 제236조 제1항, 제2항), 이를 가리켜 추심채권자의 사유신고라고 할 수 있지만, 이에 관해서는 앞에서 본 바 있으므로 여기에서는 제3채무자의 사유신고를 중심으로 논의해 가기로 한다.

II. 사유신고의 방식, 내용, 제출 법원 등

1. 일반 제3채무자인 경우

가. 사유신고서의 제출 내용 등

- 1) 사유신고서에는 위와 같이 사건 및 당사자의 표시, 공탁사유와 공탁한 금액